



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.010505/2018-49 (RJ2018/7872).

Data do julgamento: 14/12/2021

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusados: Alexandre Silveira Dias

Arnaldo Curiati

Cláudio Chonchol Bahbout

José Seripieri Filho

Nilton Molina

Raul Rosenthal Ladeira de Matos

Wilson Olivier

Ementa: Responsabilidades de administradores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152, *caput*, 154, *caput*, e 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu, por **unanimidade**:

1) Absolver Alexandre Silveira Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio Chonchol Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal Ladeira de Matos e Wilson Olivieri, na qualidade de conselheiros de administração da Qualicorp, das acusações de:

a) suposta celebração do Contrato em condições não equitativas, em infração ao art. 154, *caput*, da Lei 6.404/76.

b) suposta aprovação de pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos administradores aprovado em assembleia geral ordinária em infração ao art. 152, *caput*, c/c 154, *caput*, da Lei nº 6.404/76.

2) Absolver José Seripieri Filho, na qualidade de Diretor-Presidente e conselheiro de administração da Qualicorp, da acusação de suposta celebração do Contrato em condições não equitativas, em infração ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/76.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou o voto da Diretora Relatora, mas apresentou manifestação de voto para expor considerações adicionais em negociações envolvendo contratações com partes relacionadas.

O Diretor Alexandre Rangel concordou com as conclusões do voto da Diretora Relatora, mas divergiu em alguns pontos da fundamentação utilizada para propor a absolvição dos acusados.

Presentes os advogados Fabio Teixeira Ozi, representando Raul Rosenthal Ladeira de Matos; Otavio Yazbek, representando José Seripieri Filho; Daniel Kalansky Ponczek, representando Claudio Chonchol Bahbout e Wilson Olivieri; e Julian Fonseca Peña Chediak, representando Arnaldo Curiati, Alexandre Silveira Dias e Nilton Molina.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Fernando Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 19/01/2022, às 09:32, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 19/01/2022, às 10:11, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 24/01/2022, às 17:53, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 15:56, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1415460** e o código CRC **8DCCFA8F**.



This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1415460** and the "Código CRC" **8DCCFA8F**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/7872

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.010505/2018-49)

Reg. Col. 1455/19

Acusados: Alexandre Silveira Dias
Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri

Assunto: Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações aos arts. 152, *caput*, 154, *caput*, e 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar responsabilidade de administradores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia” ou “Qualicorp”), por alegadas irregularidades relativas à aprovação e à celebração de contrato entre partes relacionadas, envolvendo, de um lado, a Qualicorp e, de outro, José Seripieri Filho (“José Seripieri”), acionista fundador e, à época, administrador da Companhia.
2. O contrato foi objeto de análise no âmbito do Processo Administrativo nº 19957.009147/2018-21, instaurado em razão da Supervisão Baseada em Risco realizada pela CVM, tendo o mencionado processo sido concluído em 26.11.2018, com a instauração desse PAS.
3. Foram acusados (i) na qualidade de conselheiros de administração, Alexandre Silveira Dias (“Alexandre Dias”), Arnaldo Curiati (“Arnaldo Curiati”), Cláudio Chonchol Bahbout (“Cláudio Bahbout”), Nilton Molina (“Nilton Molina”), Raul Rosenthal Ladeira de Matos (“Raul Rosenthal”) e Wilson Olivieri (“Wilson Olivieri”) e, em conjunto com os demais, “Conselheiros”), por violação (A) ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”); e (B) ao art. 152, *caput* c/c 154, *caput*, da LSA; e (ii) José Seripieri (em conjunto com os Conselheiros, “Acusados”), por infração ao art. 156, §1º, também da LSA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. O CONTRATO DE NÃO ALIENAÇÃO E NÃO COMPETIÇÃO

4. Em 01.10.2018, a Qualicorp publicou fato relevante¹ informando o mercado sobre a celebração, em 28.09.2018, de Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios (“Contrato”), entre a Qualicorp e José Seripieri, Diretor-Presidente, conselheiro de administração e acionista fundador da Companhia², à época titular de participação societária relevante³, aprovado de forma unânime pelo Conselho de Administração (“CA”).

5. O Contrato⁴ previa o pagamento de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) para José Seripieri, em contrapartida a obrigações de (i) não competir com os negócios da Companhia, (ii) não alienar determinada quantidade de ações de emissão da Companhia de sua propriedade (“Lock-up”)⁵; e (iii) não solicitar qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou qualquer pessoa a deixar seu emprego ou deixar de prestar serviços para a Companhia.

6. O prazo de vigência das obrigações era de seis anos, extensível, no caso da obrigação de não competição, por mais dois anos, a exclusivo critério da Companhia, mediante o pagamento de indenização adicional⁶ a José Seripieri. Em caso de descumprimento das obrigações assumidas por José Seripieri, o Contrato previa aplicação de multa, a ser paga em favor da Companhia, de até 150% do valor da indenização recebida.

7. As discussões que culminaram na celebração do Contrato tiveram início após a comunicação de José Seripieri, ao Conselho de Administração, de sua intenção de deixar a administração da Qualicorp, na reunião do CA (“RCA”) de 14.03.2018⁷.

8. Diante da manifestação de José Seripieri aos demais membros do CA sobre a sua intenção de deixar a Companhia, iniciaram-se trabalhos e estudos direcionados à celebração de acordo de não competição.

¹ Doc. SEI 0640190, p. 2.

² Na mesma data, foi publicado Comunicado ao Mercado sobre Transação entre Partes Relacionadas, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, descrevendo os principais termos e condições do Contrato (Doc. SEI 0640190, pp. 3-5).

³ Como informado no fato relevante, José Seripieri era detentor indireto de cerca de 15% (quinze por cento) do capital social total da Companhia.

⁴ Doc. SEI 0640190, pp. 44-57.

⁵ O Lock-up abrangia, na data de celebração do Contrato, 13.652.913 ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações Restritas”), quantidade essa sujeita a ajustes ao longo do tempo, a fim de que a quantidade de ações correspondesse a valor de mercado equivalente a até 150% do valor da indenização, ou seja, até R\$ 225.000.000,00.

⁶ A cláusula 6.4 do Contrato previa que a Companhia teria o direito, até o 5º aniversário do Contrato, de exigir a extensão do seu prazo de vigência por mais dois anos, mediante o pagamento de nova indenização a José Seripieri. O valor da nova indenização era calculado de acordo com a data em que a Companhia exercesse a opção de extensão da vigência do Contrato, aumentando à medida em que a data do exercício da opção se aproximasse do prazo final para exercício da opção, sendo: (i) D+0 a D+24 meses: R\$ 31.250.000,00; (ii) D+24 meses e 1 dia a D+48 meses: R\$ 37.500.000,00; e (iii) D+48 meses e 1 dia a D+60 meses: R\$ 50.000.000,00. Os referidos valores seriam corrigidos pela variação do INPC.

⁷ Doc. SEI 0640190, p. 445.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

9. Para dar suporte a esses trabalhos e estudos sobre os impactos da saída de José Seripieri, foram contratadas as consultorias especializadas Spencer Stuart Consultores Gerenciais Ltda. (“Spencer Stuart”) e Mercer Human Resource Consulting (“Mercer” e, em conjunto com Spencer Stuart, “Consultorias”), respectivamente, em 20 e 30.04.2018⁸.
10. Em agosto de 2018, José Seripieri informou ao CA sua intenção de permanecer na gestão da Companhia. Nesse contexto, o CA determinou às Consultorias a revisão de seus trabalhos para que a análise fosse feita na perspectiva de continuidade de José Seripieri na gestão da Qualicorp⁹. Os relatórios finais das Consultorias foram apresentados à Companhia em setembro de 2018¹⁰.
11. O processo decisório cuja conclusão foi divulgada por meio do fato relevante de 01.10.2018 foi conduzido pelo CA, sem a participação ou intervenção de José Seripieri¹¹.
12. A RCA que aprovou os termos do Contrato teve início em 12.09.2018 e foi suspensa até o dia 25.09.2018, quando o CA aprovou o Contrato, que foi então celebrado em 28.09.2018.
13. Na mesma data, a Companhia e José Seripieri firmaram o Contrato de Diretor Estatutário (“Contrato de Diretor Estatutário”)¹², com o objetivo de regular as condições de exercício do cargo de Diretor-Presidente da Companhia e o valor de sua remuneração, tendo pactuado remuneração anual de R\$ 24 milhões, condicionada à aprovação da assembleia geral a cada exercício social, tomando por base estudo apresentado pela consultoria especializada McKinsey & Company (“McKinsey”) em março de 2017.
14. Após a divulgação da celebração do Contrato, por meio do referido fato relevante de 01.10.2018, as ações de emissão da Companhia sofreram uma forte queda (de 29,37% em relação ao preço de encerramento do dia anterior), ante uma desvalorização de 0,91% do índice Ibovespa¹³.
15. Nesse cenário, foram apresentadas reclamações à CVM¹⁴⁻¹⁵ e houve repercussão na mídia

⁸ Doc. SEI 0640190, p. 429.

⁹ Doc. SEI 0640190, p. 33.

¹⁰ Doc. SEI 0640190, pp. 67-84.

¹¹ Doc. SEI 0640190, p. 4.

¹² Doc. SEI 0640190, pp. 59-64.

¹³ Como informado no TA, “as ações abriram cotadas a R\$13,49, uma queda de 18,14% em relação ao fechamento anterior. Ao fim do dia, as ações estavam cotadas a R\$11,64; queda de 29,37% em relação ao fechamento anterior. Para fins de contextualização, nesse dia, o índice Ibovespa registrou desvalorização de 0,91%”, refletindo uma “perda de valor de mercado” de aproximadamente R\$ 1,370 bilhão (Doc. SEI 0659008, p. 3).

¹⁴ Doc. SEI 0640190, pp. 387-396. Destaque-se a reclamação apresentada, em 02.10.2018, por acionista detentora de aproximadamente 9% das ações ordinárias emitidas pela Companhia, que também encaminhou à Companhia duas notificações extrajudiciais em 01 e 02.10.2018 (Doc. SEI 0640190, pp. 398-418), por meio das quais impugnou a celebração do Contrato, em síntese, por considerar que a operação não teria observado o melhor interesse da Companhia, apontando que “José Seripieri já possui um dever de lealdade e não competição para com a Companhia inerente à sua posição e dela indissociável, eis que ostenta a qualidade de membro da administração” (p. 405).

¹⁵ Registre-se que, em 15.10.2018, houve desistência quanto à referida reclamação (Doc. SEI 0640190, p. 420).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

com notícias sobre reações negativas de participantes do mercado¹⁶.

16. Diante dessas repercussões, a Companhia divulgou, em 02.10.2018, Comunicado ao Mercado, com esclarecimentos acerca do Contrato¹⁷. Em 07.10.2018, a Qualicorp publicou novo aviso de fato relevante¹⁸, complementado em 10.10.2018¹⁹, comunicando (i) medidas de governança corporativa para implementação pela Companhia em transações com partes relacionadas, dentre as quais, a alteração do Estatuto Social da Companhia (“Estatuto”) para prever a submissão dessas transações à aprovação da assembleia geral e a criação do Comitê de Governança Corporativa; e (ii) o recebimento de comunicação de José Seripieri por meio da qual ele (a) renunciou à totalidade da remuneração variável a que teria direito como diretor presidente para o exercício social de 2018, no valor máximo de R\$ 7,2 milhões, e (b) assumiu a obrigação de investir na Companhia o valor recebido a título de indenização no âmbito do Contrato.

17. No primeiro pregão subsequente à divulgação dessas informações, do dia 08.10.2018, a cotação das ações de emissão da Companhia encerrou com alta de 5,77% em relação ao fechamento anterior, contra uma valorização de 4,57% do Ibovespa.

III. ACUSAÇÃO

18. A partir da análise das informações e documentos apresentados pela Companhia e pelos Acusados na fase instrutória, a SEP reputou terem ocorrido irregularidades relacionadas à aprovação e à celebração do Contrato, bem como em relação à inobservância do montante global de remuneração dos administradores aprovado em assembleia geral de acionistas. As acusações formuladas pela SEP podem ser divididas em duas vertentes.

19. A primeira contém acusação que diz respeito à alegada celebração do Contrato em condições não equitativas, em benefício de José Seripieri, em desfavor da Companhia. A SEP acusou os Conselheiros de violação ao art. 154, *caput*²⁰⁻²¹, da Lei nº 6.404/1976, por terem aprovado a celebração do Contrato em tais condições. No contexto, tendo em vista não ter

¹⁶ Vide, por exemplo, publicação do jornal Valor Econômico de 02.10.2018:

<https://www.valor.com.br/empresas/5897533/caso-qualicorp-indigna-especialistas>.

¹⁷ Doc. SEI 0640190, pp. 12-13. No referido Comunicado, a Companhia reiterou as informações prestadas por meio do Comunicado ao Mercado sobre Transação entre Partes Relacionadas de 01.10.2018.

¹⁸ Doc. SEI 0640190, pp. 19-20.

¹⁹ Doc. SEI 0640190, pp. 26-28.

²⁰ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

²¹ Após a requisição de informações à Companhia, aos Acusados e às demais pessoas envolvidas, a SEP apresentou, em 26.11.2018, TA por meio do qual os referidos conselheiros foram acusados do descumprimento ao disposto no § 1º do art. 154 da LSA, que dispõe que: “O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.” Contudo, em resposta à manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, a área técnica alterou o TA, sugerindo a responsabilização dos acusados por infração ao disposto no *caput*.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

participado do processo decisório de aprovação do negócio, a acusação formulada contra José Seripieri foi de infração ao art. 156, §1º²², da LSA, por ter celebrado o Contrato, em condições reputadas não equitativas, em desfavor da Qualicorp.

20. A segunda vertente se refere à acusação relativa à aprovação do Contrato prevendo o pagamento de benefício financeiro (efetuado logo em seguida à assinatura do Contrato) em valor superior ao montante global de remuneração dos administradores aprovado na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) de 27.04.2018, em alegado descumprimento ao art. 152, *caput*²³ c/c art. 154, *caput*, ambos da LSA, posta em face apenas dos Conselheiros, que participaram do processo decisório de aprovação do Contrato, não alcançando, assim, José Seripieri.

21. Os fundamentos adotados pela Acusação encontram-se resumidos a seguir.

O padrão de revisão das condutas

22. Ao ver da Acusação, as decisões negociais tomadas não eram desinteressadas, pois “*capazes de beneficiar singularmente uma parte relacionada que figura como diretor presidente, membro do conselho de administração, fundador e principal acionista da companhia*”²⁴. Dessa forma, entendeu que o padrão de revisão apropriado para a aferição das responsabilidades seria o teste da justiça integral (*entire fairness*) e não a regra da decisão negocial (*business judgment rule*).

23. Sob esse prisma, aduziu que (i) o Contrato deveria refletir preços e condições justas (aspecto material) e (ii) o procedimento decisório em relação à aprovação do Contrato deveria ter garantido a tomada de decisão no interesse da Companhia (aspecto procedimental), o que, na visão da Acusação, não ocorreu.

Aspecto material

24. Quanto ao aspecto material, a SEP sustentou que o preço acordado no Contrato foi excessivo, uma vez que José Seripieri, como administrador da Qualicorp, já estava sujeito ao dever de não concorrer com a Companhia, nos termos do art. 155, inciso I²⁵, da LSA, de forma que o

²² Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.

²³ Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

²⁴ Doc. SEI 0659008, p. 5.

²⁵ Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dispêndio de recursos para essa finalidade “*aproximou-se de um ato de liberalidade*”²⁶.

25. Reputou, ademais, que o valor atribuído ao Contrato não poderia ter como parâmetro a remuneração anual a que José Seripieri faria jus – fixada em R\$ 24 milhões –, na medida em que “*se José Seripieri desligar-se da Companhia, ela terá de contratar outro diretor presidente – presumivelmente pelos mesmos R\$24 milhões por ano –, que além de abster-se de concorrer com a Qualicorp terá que efetivamente geri-la. E se José Seripieri não se desligar da Qualicorp, estará recebendo em dobro a remuneração que o mercado atribui a um diretor presidente: uma vez por ser diretor presidente e outra por não ser seu concorrente*”.

26. Ainda no tocante ao valor do Contrato, a SEP considerou que o próprio valor da remuneração anual também seria inadequado, já que teria desconsiderado “*evidências objetivas mais recentes e que sinalizavam um valor bastante inferior aos R\$24 milhões usados como referência*”. Consignou, nesse sentido, que, embora o valor da maior remuneração paga pela Qualicorp a membro de sua diretoria nos exercícios de 2015 e 2016 estivesse próximo desse patamar, o mesmo não ocorreu nos exercícios de 2017 (em que o valor da maior remuneração foi de aproximadamente R\$ 8 milhões) e 2018 (em que os acionistas da Companhia aprovaram uma remuneração global de cerca de R\$ 28,5 milhões, para todos os sete conselheiros e três diretores).

27. Questionados, os Acusados informaram que o valor da contraprestação previsto no Contrato não compreendia apenas a obrigação de não competição, mas também a obrigação de Lock-up, para assegurar o alinhamento de interesses com a Companhia em longo prazo²⁷.

28. Quanto a esse ponto, a SEP destacou que “*o valor marginal, para a Qualicorp, da obrigação de José Seripieri não alienar suas ações (...) é muito reduzido, se é que existe*”, pois, como administrador, José Seripieri já estava obrigado a agir no interesse da Qualicorp e a não prejudicar os interesses sociais. Para a Acusação, ainda que o Lock-up permita um alinhamento de longo prazo, tal alinhamento “*por si só não gera benefício econômico à Qualicorp*”.

29. Por fim, na visão da SEP, a expressiva desvalorização no valor das ações que sucedeu a divulgação do negócio²⁸ seria um indicativo de que o benefício do Contrato era inferior ao valor da indenização. Segundo a área técnica, como “*a cotação da ação reflete o valor presente líquido esperado dos fluxos de caixa futuros da companhia (...)*”, “[*s*]e o desembolso de R\$150 milhões pela Qualicorp correspondesse a benefícios esperados que, a valor presente, tivessem esse mesmo montante, o valor da ação deveria permanecer inalterado”.

²⁶ Doc. SEI 0659008, p. 5.

²⁷ Doc. SEI 0640190, pp. 34-35; 451.

²⁸ Segundo informado no TA, em termos de valor de mercado, a perda da Qualicorp naquela ocasião foi de aproximadamente “*R\$1,37 bilhão, equivalente a cerca de 30% de seu valor original*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Aspecto procedimental

30. Em relação ao aspecto procedimental, a SEP reconheceu a existência de “*alguns componentes de um processo adequado*” adotados no caso concreto, que “*robustecem em alguma medida a confiança no processo de tomada de decisão pela Companhia*”, aduzindo que:

- a. há registros de que as discussões se estenderam por prazo compatível com uma efetiva negociação e não com a mera homologação de um negócio cujos termos estivessem previamente acordados;
- b. foram contratados assessores externos, como é praxe em negociações significativas; e
- c. a parte interessada na matéria, José Seripieri, não participou das discussões e deliberações, segundo as atas e comunicados produzidos.²⁹

31. Contudo, reputou ter havido falha no processo decisório tendo em vista que a celebração do Contrato não foi submetida à aprovação da assembleia geral. No entender da Acusação, a previsão no Estatuto que conferia ao CA competência para aprovação do negócio “*não impedi[a] que medidas adicionais fossem estabelecidas*”. Segundo a SEP, a submissão da matéria à assembleia seria não apenas “*uma questão de cautela*”³⁰, mas também impositiva por força do disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/1976.

32. Para fundamentar suas conclusões, a SEP sustentou que o valor pago nos termos do Contrato teria caráter remuneratório, na medida em que representaria um “*incentivo embutido à permanência de José Seripieri na Qualicorp*”, que estaria recebendo uma dupla remuneração – uma delas por ser diretor presidente e a outra por não concorrer com a Companhia.

33. Destacou, nessa linha, que “*todo o contexto em torno do Contrato mostra que ele foi pensado e discutido de modo indissociável da remuneração do diretor presidente*”, pontuando especificamente que:

- a. o Contrato teve seu valor parametrizado pela remuneração individual de um diretor presidente no mercado;
- b. na mesma data em que aprovou o Contrato, o conselho de administração deliberou sobre a remuneração de José Seripieri enquanto diretor estatutário;
- c. a justificativa para o Contrato passa pela necessidade de manter José Seripieri alinhado no longo prazo e considera o conhecimento desse diretor sobre a Companhia e o mercado;
- d. em teleconferência com investidores, foi afirmado que o Contrato havia sido firmado

²⁹ Conforme item 70 do TA. Vale registrar que a efetividade das medidas referidas nos itens “a” e “b” acima foi relativizada pela SEP em razão de seu entendimento no sentido da “*relativa facilidade de se produzirem registros documentais que sugiram uma negociação inexistente de fato*”.

³⁰ Consoante destaca o TA, “*os seguintes fatores justificavam um tratamento mais cauteloso da questão: a. o montante financeiro envolvido; b. a iminência do desembolso financeiro uma vez aprovada a transação, o que deixou pouco espaço para questionamentos entre o anúncio da transação e a produção de seus efeitos; c. a desnecessidade de que a transação fosse aprovada antes de uma data específica e iminente; d. o fato de se tratar de uma parte relacionada cujo histórico na Companhia pode implicar (ou ao menos criar a impressão de) uma ascendência sobre outros órgãos e pessoas da Companhia; e e. o caráter excepcional de um contrato de não competição firmado com um administrador que permanece vinculado à companhia*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

naquele momento porque “[José Seripieri] *é uma pessoa ímpar, que não conseguimos encontrar outro no mercado*” e que o conselho quis mantê-lo “*com a cabeça dentro da Companhia, focado dentro da Companhia, para transformar esse negócio e gerar oportunidade para todos*”;

e. no contexto de seus questionamentos sobre o Contrato, a [...] pleiteou novos estudos e avaliações para que a remuneração do diretor presidente seja mais alinhada com o resultado da Qualicorp; e

f. diante da repercussão sobre o Contrato, José Seripieri renunciou à remuneração variável à qual fazia jus para o exercício corrente.

34. Ressaltou, ainda, que, por meio da reforma promovida pela Lei nº 9.457/1997, teria sido acrescida ao art. 152 da LSA a expressão “benefícios de qualquer natureza”, o que denotaria “*o intuito do legislador de ampliar o escopo original do dispositivo para dar-lhe a conotação mais abrangente possível*”, a compreender todos os pagamentos feitos em favor dos administradores.

35. Acrescentou a SEP que o valor da remuneração aprovado na AGO de 2018 para todos os administradores seria de apenas R\$ 28,5 milhões, limite este que teria sido sobrepujado com a realização de um pagamento em montante cinco vezes superior, de R\$ 150 milhões, a um único administrador, fazendo incidir a necessidade de submissão da matéria à assembleia geral.

Medidas tomadas pela Companhia após a divulgação do Contrato

36. No que se refere às medidas tomadas pela Qualicorp e por José Seripieri após as repercussões advindas com a divulgação da celebração do Contrato, a SEP apresentou as seguintes ressalvas:

a. as melhorias nos processos de governança são todas prospectivas – as partes não se dispuseram a, por exemplo, submeter o Contrato à ratificação da assembleia geral, rescindindo-o e desfazendo seus efeitos em caso de rejeição;

b. algumas medidas se deram aparentemente no contexto de discussões com a [...] e podem atender a anseios legítimos desse acionista – que terá mais influência na discussão de temas similares no futuro –, mas não necessariamente da coletividade dos demais acionistas;

c. a renúncia à remuneração por parte de José Seripieri é de aproximadamente 5% do montante recebido por força do Contrato;

d. o compromisso de investimento do valor de R\$ 150 milhões recebido em ações de emissão da Qualicorp não muda o fato de que José Seripieri teve um acréscimo patrimonial desse montante às despesas da Companhia; e

e. como os termos originais do Contrato permanecem inalterados, José Seripieri pode alienar as ações adquiridas com esse montante de R\$ 150 milhões ao longo dos próximos anos, contanto que mantenha em sua propriedade a quantidade mínima estipulada no acordo.

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

37. Em 20.12.2018, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

parecer³¹ no sentido de que a peça acusatória³² teria atendido ao disposto no art. 11, *caput*³³, da então vigente Deliberação CVM nº 538/2008, mas teria preenchido apenas parcialmente os requisitos constantes do art. 6º do normativo³⁴, especificamente quanto ao disposto no seu inciso IV, que exige a indicação dos dispositivos legais ou regulamentares infringidos.

38. De acordo com a PFE, apesar de as condutas praticadas pelos acusados Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal e Wilson Olivieri terem sido enquadradas no §1º do art. 154 da Lei nº 6.404/1976, ao longo do Termo de Acusação (“TA”) não teria sido demonstrado que esses conselheiros foram eleitos por um grupo ou uma classe de acionistas determinados, pressuposto para a subsunção das condutas ao dispositivo invocado.

39. Ao final, a PFE afirmou que a imputação por infração ao *caput* do art. 154 da LSA se afiguraria mais acertada, sugerindo que a SEP, se assim concordasse, procedesse às adaptações sugeridas, com vistas à perfeita adequação do Termo de Acusação à Deliberação CVM nº 538/2008. Diante de tal manifestação, a área técnica procedeu ao aditamento do TA³⁵, consoante sugerido pela PFE.

V. RESPONSABILIZAÇÃO

40. Pelo exposto, a SEP concluiu pela responsabilização:

- i. dos conselheiros Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal e Wilson Olivieri, por violação:
 - A. ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por terem aprovado a celebração do Contrato em condições não equitativas, representando benefício a José Seripieri em desfavor da Companhia; e
 - B. ao art. 152, *caput* c/c art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/76, por terem aprovado o Contrato prevendo o pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos administradores aprovado na AGO de 27.04.2018; e
- ii. de José Seripieri, por infração ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976, por ter celebrado o Contrato, em condições não equitativas, em desfavor da Qualicorp.

³¹ Doc. SEI 0658050.

³² Doc. SEI 0640252.

³³ Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

³⁴ Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso; e VI – a indicação do rito a ser observado no processo administrativo sancionador.

³⁵ Doc. SEI 0659008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VI. DEFESAS

41. Os conselheiros Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina³⁶ apresentaram defesa conjunta, bem como Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri³⁷. Raul Rosenthal³⁸ e José Seripieri³⁹ apresentaram defesas individuais (todas em conjunto, “Defesas”). Como muitos argumentos de defesa são comuns a diversos defendentes, as alegações trazidas pelos Acusados serão resumidas de forma agrupada. Quando necessárias, serão feitas observações particularizando os Acusados.

Preliminares

42. Foram suscitadas questões preliminares. A primeira delas, arguida por Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri, foi a de que a acusação seria inepta, porque pautada na alegação de que José Seripieri indicara ou elegera os membros do CA, fato não demonstrado pela SEP mesmo após a retificação do TA, como sugerido pela PFE. Alegam os defendentes teriam sido acusados duas vezes por infração ao art. 154, *caput*, da LSA, o que implicaria *bis in idem*.

43. Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri suscitaram preliminar de perda de objeto do presente PAS, na medida em que, com a aprovação das contas e das demonstrações financeiras (“DFs”) relativas ao exercício social de 2018 – nas quais o custo total do Contrato foi registrado e sua natureza e termos gerais devidamente explicitados –, os acionistas da Companhia teriam dado quitação aos Acusados, desonerando-os de suas responsabilidades, nos termos do art. 134, §3º⁴⁰, da Lei nº 6.404/1976. Em sentido semelhante, a defesa conjunta de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina sustentou que a acusação carece de justa causa, uma vez que “*eventuais questões relativas à negociação e celebração do Contrato nos termos em que foi assinado (...) foram devidamente superadas pelo órgão máximo de expressão da vontade da Companhia*” quando as contas dos administradores foram aprovadas.

O padrão de revisão das condutas

44. Os Acusados refutaram a aplicação do critério do teste da justiça integral (*entire fairness*) como padrão de revisão, em substituição à regra da *business judgment rule*, a qual deve ser presumida em observância ao princípio da boa-fé, cabendo àqueles que acusam a prova de falha de dever de diligência ou de que houve atuação ilegal ou fraudulenta. Nesse sentido, ressaltaram não haver indícios de que tenham agido com fraude ou má-fé quanto ao Contrato.

³⁶ Doc SEI 0762194.

³⁷ Doc. SEI 0767247.

³⁸ Doc. SEI 0762203.

³⁹ Doc. SEI 0762230.

⁴⁰ Art. 134. (...) § 3º A aprovação, sem reserva, das demonstrações financeiras e das contas, exonera de responsabilidade os administradores e fiscais, salvo erro, dolo, fraude ou simulação (artigo 286).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

45. Alegaram que o único administrador pessoalmente interessado na celebração do Contrato, José Seripieri, absteve-se integralmente de discutir e votar sobre o assunto, aprovado de forma unânime pelo CA da Companhia, e que a Acusação não indicou nenhum elemento para comprovar a parcialidade dos demais conselheiros – fatores que corroborariam a comprovação de ter sido a decisão negocial desinteressada.

46. A esse respeito, a defesa de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina destacou que os defendentes eram conselheiros independentes, sem qualquer vínculo ou interesse convergente com José Seripieri, e que os demais conselheiros foram eleitos em assembleia geral sem a participação daquele acionista⁴¹. Tal argumento também consta das defesas dos demais acusados⁴². José Seripieri citou jurisprudência norte-americana e da CVM⁴³ no sentido de que a presunção trazida pela *business judgment rule* só seria afastada caso se comprovasse que a maioria dos administradores envolvidos tinha interesse na decisão.

47. Alguns defendentes acentuaram que a alegação de que a decisão seria interessada pelo simples fato de o Contrato ter sido firmado com uma parte relacionada que sequer participou do processo decisório inviabilizaria a realização de negócios entre companhias e suas partes relacionadas e a tomada de decisões no âmbito de companhias abertas.

48. Raul Rosenthal, José Seripieri, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri pontuaram que a própria PFE teria reconhecido a ausência de vínculo dos administradores em relação a José Seripieri em seu Parecer nº 00179/2018/GJU-4/PFE/CVM/PGF/AGU⁴⁴ e que a ausência de demonstração da vinculação persistiu mesmo após o aditamento do TA.

49. Os Acusados também afirmaram que a decisão foi refletida e informada, pois foi precedida por pelo menos 14 reuniões do CA, que se estenderam por um período de aproximadamente oito meses, e contou com a assessoria de três consultorias independentes especializadas, bem como com o parecer de renomado jurista. Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri enfatizaram que a renúncia de L.D.C.G. do cargo de diretor comercial da Qualicorp, em 17.07.2018, com o objetivo de fundar um negócio concorrente, configuraria uma sinalização de que os membros do CA deveriam, em atenção a seus deveres de diligência, atuar no sentido de

⁴¹ AGO realizada no dia 27.04.2018 (Doc. SEI 0762194, pp. 81-91).

⁴² A inexistência de conflito de interesses dos Conselheiros na deliberação e a inaplicabilidade da regra da *entire fairness* foram abalizadas em pareceres jurídicos trazidos aos autos por José Seripieri (Doc. SEI 0762233 e 0762237).

⁴³ Conforme o voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.

⁴⁴ Consoante consignou a PFE, “da leitura do Termo de Acusação, nota-se que não há qualquer menção sobre a qualificação dos membros do Conselho de Administração como eleitos por um grupo ou uma classe de acionistas determinada, no caso, a algum (a) em que José Seripieri esteja enquadrado”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

corrigir a fragilidade identificada, implementando um mecanismo que impedisse José Seripieri de concorrer com a Qualicorp.

50. As defesas de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina e de Raul Rosenthal alegaram que eles tinham o direito de se fiar no assessoramento externo para tomada de decisões (*reliance defense*)⁴⁵. A propósito, citam doutrina e jurisprudência da CVM⁴⁶.

51. Nesse contexto, os Acusados defenderam que os elementos que tipicamente afastariam a aplicação da regra da decisão negocial não estariam presentes no caso, de modo que não caberia ao julgador se imiscuir no mérito da decisão dos administradores. Asseveraram que, à luz dos parâmetros erigidos pela *business judgment rule*, o processo decisório foi informado, refletido e desinteressado, em linha com o interesse da Companhia, de forma que não teria restado caracterizada qualquer violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

52. Ademais, frisaram que, mesmo que se aplicasse o critério da *entire fairness* como padrão de revisão, também estariam ausentes os pressupostos para a sua responsabilização.

53. Ressaltaram, nesse sentido, que (i) o Contrato foi celebrado a preços e condições justos (aspecto material), e que (ii) o processo de negociação do Contrato também foi justo (aspecto procedimental).

Aspecto material

54. No que tange ao aspecto material (*fair price*), as defesas sustentaram que a tese acusatória partiu de um erro de premissa ao assumir que as obrigações previstas no Contrato se confundiriam com os deveres fiduciários do administrador previstos na Lei nº 6.404/1976.

55. Para derrubar essa premissa, os Acusados aduziram que as obrigações convencionais teriam um espectro mais amplo, tanto do ponto de vista temporal, na medida em que subsistiriam mesmo na hipótese de José Seripieri deixar de ser administrador da Qualicorp, quanto objetivo, tendo em vista que o Contrato não compreenderia apenas as obrigações de não competição, abarcando também a obrigação de Lock-up, com vistas a assegurar o alinhamento de interesses com a Companhia em longo prazo. Assim, defendem que não configurava ato de liberalidade.

56. Raul Rosenthal acrescentou que a obrigação de não competição posta no Contrato tinha uma abrangência maior em relação aos preceitos contidos nos arts. 155, I, e 147, §3º⁴⁷, da LSA e

⁴⁵ Em reforço à tese defensiva, fazem referência ao voto do então Diretor Pablo Renteria no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/10276, j. em 11.07.2017.

⁴⁶ PAS CVM nº RJ2014/8013 e PAS CVM nº RJ2015/10276.

⁴⁷ Art. 147. (...) § 3º O conselheiro deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembléia-geral, aquele que: I - ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e II - tiver interesse conflitante com a sociedade. (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apresentou parecer da lavra do Dr. Paulo Cezar Aragão que, entre outros aspectos, sustentou que:

“A hipótese prevista no inciso I do art. 155 – usurpação de oportunidade comercial – pode ser entendida como uma forma de concorrência com a companhia, tal como compreendido na Não Competição. Porém, para que a vedação legal se aplique, é necessário, no mínimo, que: (i) a oportunidade seja de interesse da Companhia; (ii) essa esteja compreendida em seu objeto social; e (iii) a Companhia tenha os recursos para explorar tal oportunidade comercial.

Portanto, não atendidos esses requisitos, o administrador poderia, sem infringir seus deveres para com a Companhia, se apropriar da oportunidade comercial. De forma oposta, contudo, pela Não Competição contratada, a vedação independe da capacidade e do interesse da Companhia para explorar a oportunidade comercial, bastando que esta esteja compreendida no Negócio.

(...) a Não Competição ainda vai muito além da vedação legal do art. 147, §3º, pois inclui o simples investimento passivo em sociedade que atue em qualquer Negócio, ou, ainda, a prestação de serviços ou consultoria. Inclui, também, vedação ao aliciamento de empregados, clientes e fornecedores da Companhia, bem como à contratação que seja prejudicial às relações e negócios já existentes da Companhia e, até mesmo, veda ao Sr. José Seripieri o fornecimento de documentos. Ou seja, a Não Competição veda que o Sr. José Seripieri atue ativa ou passivamente no Negócio, a qualquer título.”⁴⁸

57. Diversos acusados afirmaram que o valor da contraprestação refletia os riscos atrelados à potencial saída de José Seripieri, acionista relevante e principal liderança da Companhia⁴⁹, e à potencial piora nas condições de competição a que a Companhia estaria sujeita⁵⁰. Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina ponderaram que a venda das ações de José Seripieri e seu desalinhamento com a Companhia poderia causar perda muito superior ao valor indenizado.

58. As defesas salientaram também que a definição do valor do Contrato foi baseada em assessoria de consultorias externas especializadas e em precedentes de mercado que utilizam como referência o valor total anual da remuneração de um alto executivo, multiplicado pelo número de

⁴⁸ Doc. SEI 0762204, pp. 69-70; e 73.

⁴⁹ Discorreram sobre a relevância do papel que José Seripieri exercia nos negócios da Companhia, como acionista fundador e executivo chave, destacando suas qualificações técnicas, rede de relacionamentos e reconhecimento no âmbito do mercado de seguros. Algumas defesas apontaram que a Companhia já previa na época dos fatos, em seu Formulário de Referência de 06.06.2018, um fator de risco relacionado às mudanças em sua alta administração, nos seguintes termos: “**Mudanças na nossa alta administração e a incapacidade de atrair pessoal qualificado à sua altura podem afetar adversamente nossos negócios e resultados.** A nossa atividade exige significativa qualificação profissional da nossa alta administração, tanto em relação ao conhecimento do setor de saúde suplementar, relacionamento com Associações Profissionais e/ou Entidades de Classe, como na agilidade e precisão na tomada das decisões, motivação e organização da força de vendas e novas oportunidades de negócio a serem exploradas. A eventual perda dos nossos principais executivos e a nossa incapacidade de atrair e manter profissionais qualificados pode causar um efeito prejudicial relevante sobre os nossos negócios e resultados.” (grifos no original).

⁵⁰ Para corroborar suas alegações, as defesas de Raul Rosenthal, José Seripieri e de Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri fazem referência à saída de L.D.C.G. do cargo de diretor comercial da Qualicorp, em 17.07.2018, com o objetivo de fundar um negócio concorrente, negando a aceitação de acordo de não competição que lhe foi proposto pela Companhia (conforme Doc. SEI 0762203, p. 108).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

anos de duração da obrigação de não competir⁵¹. Com o objetivo de reforçar que a indenização foi contratada dentro dos padrões de mercado, a defesa de José Seripieri apresentou parecer da consultoria Heidrick & Struggles⁵² e alegou, ainda, que a indenização convencionada representava contrapartida a obrigações personalíssimas, cuja precificação era incomparável⁵³.

59. José Seripieri também destacou que a Acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar que as práticas de mercado seriam diferentes daquelas contratadas ou que o Contrato tivesse sido celebrado em bases que não fossem “razoáveis” ou “equitativas”, o que já seria suficiente para a absolvição do defendente da acusação de infração ao §1º do art. 156 da Lei nº 6.404/1976. Para corroborar tal argumento, citou julgado da CVM⁵⁴.

60. Contra-argumentando as conclusões da Acusação de que o valor da remuneração anual de José Seripieri estabelecida no Contrato de Diretor Estatutário, no montante de R\$ 24 milhões, seria elevado, quando comparado à remuneração praticada nos exercícios anteriores, os defendentes aduziram que a sua forma de cálculo foi amparada por estudo produzido pela McKinsey em março de 2017 e era consistente com o valor anual global da remuneração paga ao então diretor-presidente da Qualicorp nos exercícios de 2015 e 2016⁵⁵. José Seripieri também acentuou que o referido valor foi estabelecido pelo Comitê de Remuneração da Companhia, órgão do qual o defendente não fazia parte.

61. Alguns dos Acusados apontaram que os valores pagos a José Seripieri, como Diretor-Presidente, nos exercícios de 2017 e 2018, eram bastante inferiores ao que a Companhia, em linha com o mercado em geral, pagava para seus executivos⁵⁶. De acordo com a defesa de José Seripieri, a remuneração definida em conjunto com a McKinsey em 2017 não teria sido refletida no exercício social de 2018 por conta da incerteza quanto à saída do defendente da Companhia, tendo o defendente, inclusive, optado por abrir mão daquela nova remuneração⁵⁷.

⁵¹ Considerando uma remuneração anual de José Seripieri equivalente a R\$24 milhões, nos termos do Contrato de Diretor Estatutário, e o tempo de não competição acordado no Contrato, correspondente a seis anos, estabeleceu-se, após a atualização monetária, o valor total de R\$ 150 milhões a título de indenização.

⁵² Doc. SEI 0762234.

⁵³ Como respaldado por parecer jurídico da lavra do professor José Alexandre Tavares Guerreiro (Doc. SEI 0762233).

⁵⁴ PAS CVM nº RJ2012/11199, j. em 22.03.2016.

⁵⁵ Consoante informado no item 13.11 do Formulário de Referência da Companhia, as maiores remunerações da diretoria estatutária nos anos de 2015 e 2016 (que, naqueles anos, eram referentes à remuneração global anual de M.C., diretor presidente da Qualicorp à época) eram de, respectivamente, R\$ 27.166.121,90 e R\$ 21.353.406,17.

⁵⁶ Apontam, nesse sentido, que José Seripieri (eleito Diretor-Presidente da Companhia em maio de 2017 – Doc. SEI 0762235), recebera exclusivamente: (i) *pro labore* de cerca de R\$ 120 mil, além de *stock options*, no ano de 2017 (o custo de carregamento destas *stock options* para a Qualicorp teria alcançado aproximadamente R\$ 1,5 milhão); e (ii) *pro labore* de aproximadamente R\$ 250 mil no ano de 2018.

⁵⁷ Nesse sentido, a ata da RCA de 14.03.2018 (Doc. SEI 0762236) aponta que “[o] *conselheiro José Seripieri Filho, atual CEO e Fundador da Companhia, solicitou formalmente a manutenção de sua remuneração no formato e valores anteriores, sem considerar qualquer alteração da sua remuneração atual*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

62. Ainda no tocante ao valor de sua remuneração anual, José Seripieri citou a decisão proferida no PAS CVM nº RJ2011/5211, julgado em 01.07.2015, no sentido de que a decisão quanto à definição das verbas de remuneração, nos termos do art. 152 da LSA, passa por critérios necessariamente subjetivos, razão pela qual não caberia ao órgão regulador “*verificar o cumprimento do mencionado dispositivo com base em uma avaliação própria*”.

63. Raul Rosenthal asseverou que, ao contrário do que afirmou a Acusação, embora a desvalorização no valor das ações que sucedeu a divulgação do negócio possa ser um indicativo da percepção do mercado sobre o Contrato, “*não pode em hipótese alguma ser considerada um critério para determinar se o preço contratado foi ou não justo, e menos ainda para a aferição da legalidade do negócio. E, mesmo que assim o fosse, o preço das ações da Companhia voltou a subir*”⁵⁸. Mencionou que a desistência da reclamação apresentada por acionista da Qualicorp demonstraria o reconhecimento do mercado de que o Contrato atenderia ao melhor interesse da Companhia, argumento também utilizado por Cláudio Bahbout, Wilson Olivieri e José Seripieri.

64. Diante do exposto, as Defesas alegam que a indenização prevista no Contrato foi estabelecida em condições razoáveis e equitativas, no melhor interesse da Companhia, de forma que não implicaria violação aos arts. 154, *caput*, ou 156, § 1º, da Lei nº 6.404/1976.

65. Por fim, a defesa de Raul Rosenthal propugnou que, na eventualidade de sua condenação, deveriam ser levadas em consideração, para a dosimetria da pena, a boa-fé do defendente e a configuração de “erro de proibição”, previsto no art. 21 do Código Penal. Em sentido similar, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri requereram a aplicação das atenuantes previstas no art. 10, I, II e III, da Lei nº 13.506, de 13.11.2017⁵⁹.

Aspecto procedimental

66. Por sua vez, no que se refere ao aspecto procedimental, sustentaram, em síntese, que, além da contratação de assessores externos especializados e do tempo de negociação já ressaltados, outros fatores demonstrariam que o procedimento decisório em relação à aprovação do Contrato garantiu a tomada de decisão no interesse da Companhia (*fair dealing*), como:

- a) a ausência da participação de José Seripieri, na qualidade de interessado no processo, nas discussões e deliberações sobre o assunto;

⁵⁸ Doc. SEI 0762203, p. 43.

⁵⁹ Art. 10. Na aplicação das penalidades estabelecidas neste Capítulo, serão considerados, na medida em que possam ser determinados: I - a gravidade e a duração da infração; II - o grau de lesão ou o perigo de lesão ao Sistema Financeiro Nacional, ao Sistema de Consórcios, ao Sistema de Pagamentos Brasileiro, à instituição ou a terceiros; III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- b) a aprovação do Contrato por unanimidade pelo CA⁶⁰, órgão competente para a aprovação do negócio nos termos do art. 16 do Estatuto⁶¹ vigente à época;
- c) a inexistência de qualquer interesse no negócio por parte dos conselheiros que participaram da deliberação ou de vínculo pessoal que pudesse macular sua imparcialidade;
- d) o fato de que, durante a negociação e elaboração do Contrato, Qualicorp e José Seripieri foram representados por escritórios distintos;
- e) o fato de que os entendimentos das consultorias foram efetivamente utilizados para a tomada de decisão; e
- f) a divulgação ampla e tempestiva dos termos e condições do Contrato ao mercado.

67. Ressaltaram, ainda, que o pagamento feito no âmbito do Contrato teria natureza indenizatória, e não remuneratória, uma vez que a causa de sua realização estaria relacionada com a compensação econômica pela limitação ao exercício de direitos em decorrência de obrigações negativas assumidas por José Seripieri na qualidade de acionista, e não com a remuneração de serviços prestados na qualidade de administrador⁶², como respaldariam os pareceres contábil e jurídico que analisaram a questão⁶³.

68. Nessa linha, Raul Rosenthal destacou que a emissão de relatório de revisão por auditor independente sem ressalvas para as informações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao período findo em 30.09.2018 confirma a forma de contabilização do Contrato como “ativo intangível”, e não como “remuneração”, e, conseqüentemente, a natureza indenizatória do montante pago a José Seripieri.

69. Diversos acusados alegaram que a alteração do art. 152 da Lei nº 6.404/1976 trazida pela

⁶⁰ Como tal órgão era composto por sete membros, a discussão e a votação do Contrato ficaram, assim, a cargo dos outros 6 membros, três dos quais eram membros independentes, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado. Raul Rosenthal destacou (Doc. SEI 0762203, p. 43) que a quantidade de conselheiros independentes à época da celebração do Contrato perfazia o percentual de 43%, superior ao mínimo exigido pelo Regulamento do Novo Mercado (de dois membros ou 20%).

⁶¹ Artigo 16 - Além das atribuições que lhe confere a Lei das Sociedades por Ações, as seguintes matérias deverão ser aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia: (...) (ix) celebração, modificação de qualquer aspecto relevante, cancelamento ou resolução de qualquer acordo, ou, ainda, permitir o vencimento antecipado ou a caducidade de qualquer contrato em valor superior a R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); (...) (xv) qualquer operação (inclusive alocação de despesas) e/ou celebração de quaisquer contratos entre a Companhia e qualquer diretor, conselheiro ou acionista da Companhia (ou pessoa controladora, controlada ou sob controle comum com a Companhia, ou membro da família do diretor, conselheiro ou acionista em questão); (...).

⁶² Nessa linha, Arnaldo Curiati, Alexandre Dias e Nilton Molina observaram que o tratamento tributário dado pela Companhia ao valor pago a José Seripieri foi de indenização, como informado pela Qualicorp na fase investigatória (Doc. SEI 0640190, p. 375).

⁶³ Foram juntados aos autos parecer técnico contábil da lavra dos professores Eliseu Martins e Vinícius Aversari Martins (Doc. SEI 0661457) e parecer legal do jurista Nelson Eizirik (Doc. SEI 0661459).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Lei nº 9.457, de 05.05.1997, para a inclusão da expressão “benefícios de qualquer natureza”, foi realizada com o objetivo de contemplar também a remuneração indireta dos administradores, correspondente aos benefícios a que fazem jus enquanto ocupam o cargo, tais como auxílio refeição e seguro saúde (os chamados “*fringe benefits*”). Porém, ao contrário do constante da tese acusatória, nesse conceito não estariam compreendidos todo e qualquer valor recebido por um administrador, mas apenas aqueles valores diretamente ligados ao exercício do cargo, de forma a não inviabilizar a celebração de negócios jurídicos entre companhias e seus administradores, causando perdas de oportunidade e prejuízos às próprias sociedades.

70. Nesse contexto, vários acusados sustentaram a inaplicabilidade do decidido no PAS CVM nº RJ2008/4857 (“Caso Embrapar”), julgado em 23.08.2011, ao caso ora sob análise, por ambos apresentarem fatos e premissas distintos. Aduziram que, como o precedente discutia o pagamento de um “pacote de benefícios” a administradores no âmbito de plano de retenção nas hipóteses de destituição ou desligamento de suas funções, tal compensação decorria de sua condição de administradores, *status* irrelevante para fins do Contrato objeto do presente processo.

71. Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Nilton Molina, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri acrescentaram que o fato de ter havido a celebração do Contrato de Diretor Estatutário para disciplinar o exercício do cargo de Diretor-Presidente por José Seripieri evidenciaria que a remuneração que lhe fora atribuída na qualidade de administrador teria sido tratada em esfera distinta e própria para o assunto, não se confundindo com o escopo do Contrato. O salário de José Seripieri como administrador teria sido utilizado como base de cálculo do valor de sua indenização “*apenas para que se pudesse avaliar o seu custo de oportunidade no negócio*”⁶⁴, em linha com precedentes de mercado. Tal argumento foi corroborado por Raul Rosenthal, que pontuou, também, que o Contrato de Diretor Estatutário condicionou o pagamento do salário do executivo à aprovação em assembleia geral, nos termos da lei societária⁶⁵⁻⁶⁶.

72. A defesa de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina salientou que submeter a aprovação da matéria à assembleia geral não seria um ato de conservadorismo, como aduziu a Acusação, mas “*um caso de desídia no cumprimento de seus deveres atribuídos pelos acionistas*”

⁶⁴ Doc. SEI 0762194, p. 68.

⁶⁵ Nos termos de sua Cláusula 3, a seguir transcrita: “3.1. Pelo desenvolvimento das atividades de Diretor Presidente da Companhia e pelo cumprimento de todas as obrigações de Diretor previstas neste Contrato, o Diretor fará jus a uma remuneração anual nos termos do Anexo I, ressalvado que a remuneração anual referente ao ano de 2018 será devida somente até o limite de remuneração da administração aprovado pela Assembleia Geral Ordinária de 2018 e a remuneração anual a partir do ano de 2019 estará condicionada à aprovação em Assembleia Geral Ordinária.”.

⁶⁶ Conforme destacado, a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29.04.2019, aprovou, por maioria dos votos dos presentes, limite máximo de remuneração de R\$ 42.765.808,00, montante que considerou o novo valor da remuneração de José Seripieri como Diretor-Presidente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*e de acordo com os limites estabelecidos no Estatuto Social*⁶⁷. Citou decisão proferida no PAS CVM nº RJ2002/1823, em 14.03.2005, no sentido de que “*não há exigência legal ou regulamentar de que o contrato [entre partes relacionadas] deva ser submetido à assembleia geral*”.

73. Em sentido similar, Raul Rosenthal asseverou que o conjunto de elementos disponíveis ao defendente quando da aprovação do Contrato apontava para a legalidade do pagamento de valores a título de indenização e para a desnecessidade de submissão do tema à assembleia geral. Assim, a exigência de conduta diversa afrontaria o princípio da legalidade e o art. 2º, p.ú., inciso XIII, da Lei nº 9.784, de 29.01.1999, que veda a aplicação retroativa de nova interpretação e frisou que estaria albergado pela excludente de “erro de proibição” prevista no art. 21 do Código Penal.

74. Diante dos motivos expostos acima, defenderam que não seria necessário que o valor pago a José Seripieri observasse o limite global da remuneração da administração aprovado pela assembleia geral da Companhia nem levado à deliberação da assembleia geral, razão pela qual não caberia a responsabilização dos Conselheiros por violação ao art. 152 da Lei nº 6.404/1976.

75. Ademais, alguns dos acusados alegaram que a assembleia geral da Companhia aprovou sem reserva as DFs e as contas dos administradores referentes ao exercício social de 2018, exonerando-os, assim, de qualquer responsabilidade conforme preceitua o artigo 134, §3º, da LSA.

76. Nessa linha, argumentaram que os termos do Contrato teriam constado expressamente das notas explicativas das DFs, de modo que a quitação outorgada pelos acionistas não teria apenas caráter geral, mas também específico quanto à realização do negócio. Segundo aduziram, a outorga do *quitus* tinha o condão de ratificar o pagamento realizado. Consequentemente, as acusações formuladas careceriam de justa causa. Em sentido semelhante, Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri defenderam que o presente PAS perdeu seu objeto. José Seripieri acrescentou que a reeleição dos membros do conselho de administração que aprovaram a celebração do Contrato evidenciou a confiança dos acionistas naqueles administradores.

77. Raul Rosenthal observou que as medidas de incremento de governança corporativa tomadas após as repercussões advindas com a divulgação do Contrato demonstrariam preocupação – não obrigatória – com a governança e transparência das decisões da administração. Por fim, em sua defesa, Raul Rosenthal protestou “*pela produção de provas por todos os meios admitidos em Direito*”, mas, posteriormente, não chegou a apresentar qualquer pedido de produção de provas.

VII. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

78. Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Nilton Molina, Cláudio Bahbout, Wilson Olivieri e

⁶⁷ Doc. SEI 0762194, p. 73.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Raul Rosenthal apresentaram propostas de Termo de Compromisso (“TC”) em 19.06.2019⁶⁸, comprometendo-se, cada um deles, a pagar o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

79. Ao analisar as propostas, a PFE⁶⁹ concluiu pela existência de óbice jurídico, com base no art. 11, § 5º, inciso II, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976, em razão da necessidade de indenização à Qualicorp no valor de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais).

80. O Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”)⁷⁰, por sua vez, manifestou-se pela rejeição das propostas, considerando (i) as características que permeavam o caso concreto, notadamente, o ineditismo das questões nele contidas e o fato de José Seripieri, principal beneficiário do Contrato, não ter apresentado proposta de TC; e (ii) o óbice apontado pela PFE.

81. Em 22.10.2019, o Colegiado decidiu⁷¹ pela rejeição das propostas de TC apresentadas, por entender que o caso demandaria um pronunciamento norteador em sede de julgamento.

VIII. DISTRIBUIÇÃO

82. Na reunião do Colegiado de 02.07.2019⁷², fui designada relatora deste PAS.

IX. MANIFESTAÇÃO COMPLEMENTAR

83. Em 15.03.2021, José Seripieri apresentou manifestação complementar⁷³ com esclarecimentos quanto a alguns fatos supervenientes à apresentação de sua defesa.

84. Juntamente com a manifestação, encaminhou parecer jurídico complementar do Professor José Alexandre Tavares Guerreiro, que, em complementação ao parecer de 16.05.2019, analisou as implicações dos fatos supervenientes e concluiu que estes consubstanciariam elementos adicionais de convencimento sobre a equidade e razoabilidade do Contrato.

Resumo dos fatos supervenientes apontados com relação ao Contrato

85. Em 12.11.2019, a Qualicorp divulgou novo fato relevante⁷⁴, comunicando a renúncia de José Seripieri a seus cargos de Diretor-Presidente e conselheiro de administração e membro do comitê de remuneração da Companhia⁷⁵, no contexto da implementação de operação de

⁶⁸ Doc. SEI 0781394, 0781411 e 0781414.

⁶⁹ Conforme manifestação do Procurador-Chefe da PFE na reunião do CTC de 13.08.19 (Doc. SEI 0857965).

⁷⁰ Doc. SEI 0857965.

⁷¹ Doc. SEI 0884053.

⁷² Doc. SEI 0789646.

⁷³ Doc. SEI 1216498.

⁷⁴ Doc. SEI 1216499 (doc. 2).

⁷⁵ Posteriormente à celebração do Contrato, em 28.11.2018, José Seripieri passou a fazer parte do Comitê de Remuneração da Companhia (conforme ata da RCA disponível em: <https://www.rad.cvm.gov.br/ENET/frmExibirArquivoIPEEExterno.aspx?NumeroProtocoloEntrega=655388>).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

reorganização societária⁷⁶⁻⁷⁷.

86. Após a sua saída da administração da Qualicorp, José Seripieri apresentou ao CA proposta de transação com a Companhia (“Transação”), a envolver: (i) a aquisição, por José Seripieri, da integralidade das cotas de emissão da QSaúde Operadora de Planos de Saúde Ltda. (“QSaúde”), controlada da Companhia; e (ii) a celebração de contrato de parceria comercial entre QSaúde e Qualicorp, regulando o direito dessa de comercializar produtos oferecidos pela primeira.

87. Em RCA iniciada em 08.01.2020 e concluída em 13.01.2020, o CA da Companhia, em deliberação unânime, aprovou a Transação e propôs a sua submissão à assembleia geral. A fim de viabilizar a operação, foi proposta a celebração de aditamento ao Contrato (“Aditamento”), especificamente para a concessão de liberação parcial e restrita das obrigações de não competição e não solicitação assumidas por José Seripieri, em relação à atividade de operadora de planos privados de assistência à saúde (exceto na modalidade de administradora de benefícios)⁷⁸⁻⁷⁹.

88. A Transação e o Aditamento⁸⁰ foram aprovados na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) realizada em 30.01.2020.

89. Em 30.04.2020, foi realizada AGO da Companhia, na qual foram aprovadas as DFs e contas da administração referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019⁸¹.

90. Após à celebração do Aditamento, José Seripieri e Qualicorp passaram a divergir sobre o preço de aquisição das cotas da QSaúde, tendo a questão sido levada à arbitragem, mas quanto ao que as partes chegaram a um acordo, conforme noticiado em fato relevante de 01.12.2020⁸².

91. Nos termos do instrumento de transação (“Instrumento de Transação”)⁸³⁻⁸⁴ celebrado na referida data, foram acordadas, dentre outras disposições, (i) a extensão por mais dois anos da

⁷⁶ Como informado no fato relevante, a renúncia ocorreu no bojo da operação de alienação de parcela da participação detida indiretamente por José Seripieri na Qualicorp à Rede D’Or São Luiz S.A. A alienação compreendeu parcela da referida participação acionária que excedia aquela vinculada à obrigação de Lock-up prevista no Contrato.

⁷⁷ Na oportunidade, também foi comunicada a renúncia de L. P. G. P. e Raul Rosenthal a seus cargos de conselheiros de administração e membros do Comitê de Remuneração da Companhia.

⁷⁸ Doc. SEI 1216499 (doc. 4).

⁷⁹ Vale registrar que a liberação parcial objeto do Aditamento não afetou os demais termos do Contrato (inclusive o montante pago a José Seripieri a título de indenização), que foram expressamente ratificados, como se verifica da Cláusula 3.1 do Aditamento: “3.1. As Partes ratificam todos os demais termos e condições do Contrato que não foram expressamente alterados por meio deste Primeiro Aditamento, ficando delegado à administração da Companhia tomar quaisquer medidas para a implementação, o acompanhamento e a gestão do Contrato, incluindo a realização de eventuais ajustes contratuais aplicáveis.” (Doc. SEI 1216499 – doc. 4, p. 109).

⁸⁰ Doc. SEI 1216499 (doc. 4, pp. 107-111).

⁸¹ Doc. SEI 1216499 (doc. 5).

⁸² Doc. SEI 1216499 (doc. 8).

⁸³ Doc. SEI 1216499 (doc. 7).

⁸⁴ Aprovado na RCA realizada em 01.12.2020 (Doc. SEI 1216499 – doc. 6).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

obrigação de não competição assumida por José Seripieri no Contrato e respectivo Aditamento; (ii) a obrigação, por José Seripieri e suas controladas, de alienação de sua participação societária na Qualicorp; e (iii) como contrapartida pela extensão do prazo da obrigação de não competição e para viabilizar a execução da obrigação de alienação de participação acionária, previstas nos itens (i) e (ii) anteriores, a dispensa da obrigação de Lock-up.

Argumentos apresentados quanto aos fatos supervenientes

92. Inicialmente, José Seripieri repisou os argumentos de sua defesa. Em particular, reiterou suas alegações de que (i) a tomada de decisão acerca da celebração do Contrato deveria ser aferida sob a ótica da *business judgment rule*, uma vez que não haveria parcialidade na atuação de nenhum dos Conselheiros envolvidos no processo decisório, que não contou com a participação ou intervenção de José Seripieri, e (ii) o Contrato foi firmado no melhor interesse da Companhia, em condições equitativas.

93. Em seguida, José Seripieri elencou as razões pelas quais os fatos supervenientes corroborariam sua tese de defesa no sentido de que o Contrato atenderia, à época de sua celebração, os requisitos do art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

a) Aprovação do Aditamento na AGE de 30.01.2020

94. Sobre esse ponto, afirmou que, por meio do Aditamento, os acionistas deliberaram a novação da obrigação de não competição prevista no Contrato e a ratificação dos seus demais termos, incluindo o valor da indenização, o que configuraria o reconhecimento de que as condições previstas no Contrato estavam alinhadas ao interesse social, sendo, portanto, equitativas.

95. Essa conclusão seria reforçada pelo fato de que a AGE considerou adequado o valor da contraprestação previsto no Contrato mesmo diante da redução da abrangência da obrigação de não concorrência por meio do Aditamento, em decorrência da alienação do controle da QSaúde no âmbito da Transação.

b) Aprovação das DFs referentes aos exercícios de 2018 e 2019

96. José Seripieri sustentou que, tendo em vista a ampla divulgação do Contrato e seus reflexos patrimoniais nas DFs da Companhia referentes aos exercícios de 2018 e 2019, a aprovação sem ressalvas desses documentos demonstraria que, na percepção dos acionistas, teria havido o cumprimento por parte dos administradores de todos os seus deveres legais e estatutários nos exercícios correspondentes.

c) A celebração do Instrumento de Transação

97. Em primeiro lugar, o defendente aduziu que a celebração do Instrumento de Transação



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

demonstraria que a obrigação de Lock-up, diferentemente do que foi alegado pela SEP, seria de grande valor para a Companhia.

98. Isso porque a extensão por mais dois anos da obrigação de não competição, que se pactuou por meio do Instrumento de Transação, estava prevista no Contrato e era condicionada ao pagamento de nova indenização a José Seripieri, que, à época da celebração do Instrumento de Transação, corresponderia ao montante de R\$ 37.500.000,00, corrigidos pela variação do INPC desde a data da celebração do Contrato⁸⁵.

99. Porém, ao invés do pagamento de nova indenização, a extensão do prazo da obrigação de não competição foi estabelecida no Instrumento de Transação tendo como contrapartida a extinção da obrigação de Lock-up, de modo que se poderia inferir que ao Lock-up teria sido atribuído pela Qualicorp o valor de R\$ 37.500.000,00, corrigidos pela variação do INPC.

100. Por fim, o defendente alegou que o fato de o Instrumento de Transação ter sido aprovado por CA com composição diversa daquele que aprovou a celebração do Contrato demonstraria o reconhecimento de que a obrigação de não competição continuaria sendo economicamente vantajosa à Companhia, justificando a prorrogação do seu prazo de vigência por mais dois anos, o que corroboraria a conclusão de que o Contrato e o valor da indenização nele previsto teriam atendido o interesse da Companhia.

X. PAUTA DE JULGAMENTO

101. Em 12.11.2021, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM⁸⁶, em cumprimento ao disposto no art. 49 da Resolução CVM nº 45, de 31.08.2021.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2021.

FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.12.13 14:10:50 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁸⁵ Nos termos da Cláusula 6.4 do Contrato.

⁸⁶ Doc. SEI 1386742.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/7872

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.010505/2018-49)

Reg. Col. 1455/19

Acusados: Alexandre Silveira Dias
Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri

Assunto: Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152, *caput*, 154, *caput*, e 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. BREVE INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP para apurar responsabilidades de administradores da Qualicorp por alegadas irregularidades relativas à aprovação e à celebração, em 28.09.2018, de contrato entre partes relacionadas, envolvendo, de um lado, a Qualicorp e, de outro, José Seripieri Filho, acionista fundador e, à época, também Diretor-Presidente e membro do CA da Companhia.
2. Como relatado, o Contrato de Assunção de Obrigação de Não Alienação de Ações e Não Competição de Negócios (“Contrato”) previa o pagamento de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) a José Seripieri, em contrapartida à assunção de obrigações de (i) não competição; (ii) não alienação de ações de emissão da Companhia (“Lock-up”)²; e (iii) não solicitação a qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou qualquer pessoa a deixar seu emprego ou deixar de prestar serviços para a Companhia. O prazo de vigência das obrigações era de seis anos contados da assinatura do Contrato, extensível por mais dois anos, a exclusivo critério da Companhia e mediante o pagamento de indenização adicional a José Seripieri. Em caso de

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² O Lock-up abrangia, na data de celebração do Contrato, 13.652.913 ações ordinárias de emissão da Companhia, quantidade essa sujeita a ajustes ao longo do tempo, a fim de que a quantidade de ações correspondesse a valor de mercado equivalente a até 150% do valor da indenização, ou seja, até R\$ 225.000.000,00, sujeita ainda a liberações parciais escalonadas, nos termos do Contrato, a partir de 48 meses da sua celebração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

descumprimento das obrigações assumidas por José Seripieri, o Contrato previa aplicação de multa, a ser paga em favor da Companhia, de até 150% do valor da indenização recebida.

3. Tendo analisado o Contrato e o processo decisório que resultou em sua aprovação, a SEP concluiu³ pela responsabilização (i) dos conselheiros Alexandre Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal e Wilson Olivieri (referidos em conjunto como “Conselheiros”), por violação (A) ao art. 154, *caput*⁴, da LSA, por entender que esses aprovaram a celebração do Contrato em condições não equitativas, representando benefício a José Seripieri em desfavor da Qualicorp, e (B) ao art. 152, *caput*⁵ c/c art. 154, *caput*, da LSA, por reputar que aprovaram o Contrato prevendo o pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos administradores da Companhia aprovado na AGO de 27.04.2018; e (ii) de José Seripieri, por infração ao art. 156, §1º⁶, da LSA, por ter celebrado o Contrato, em condições reputadas não equitativas, em desfavor da Qualicorp.

4. Entendeu a SEP que os Conselheiros aprovaram a celebração do Contrato em condições não equitativas que beneficiavam “*singularmente uma parte relacionada*”⁷ que figura como diretor presidente”, destacando que as obrigações assumidas por José Seripieri se confundem, em certa medida, com alguns dos deveres a que ele já estava sujeito em razão da sua posição de administrador da Companhia. Além disso, para a Acusação, o valor devido pela Qualicorp em razão do Contrato tem natureza remuneratória (e não indenizatória) e, assim, o montante pago deveria estar abarcado pelo montante global da remuneração dos administradores aprovado pela assembleia geral de acionistas da Companhia, o que não ocorreu.

5. Regularmente intimados, os Acusados apresentaram suas Defesas, que, como relatado,

³ O Termo de Acusação original foi apresentado em 26.11.2018 e, como relatado, aditado em 31.12.2018 para retirar o §1º do art. 154 da primeira imputação feita em face dos Conselheiros, passando a se referir ao *caput* do artigo.

⁴ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.

⁵ Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

⁶ Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros.

⁷ Trata-se, sem dúvida, de transação com parte relacionada, como dispõe o item 9 do Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 642, de 07.10.2010: “9. (...) *Parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis (neste Pronunciamento Técnico, tratada como “entidade que reporta a informação”). (a) Uma pessoa, ou um membro próximo de sua família, está relacionada com a entidade que reporta a informação se: (...) (iii) for membro do pessoal chave da administração da entidade que reporta a informação ou da controladora da entidade que reporta a informação*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

trazem argumentos que põem em xeque o mérito da análise realizada pela SEP, além de certas questões preliminares que passo a analisar a seguir.

II. PRELIMINARES

II.1. Inépcia do Termo de Acusação e *Non Bis in Idem*

6. Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri arguíram a inépcia da acusação, tendo em vista que “a PFE recomendou a retirada da acusação contra os membros do Conselho de Administração da Qualicorp pela alegada violação ao Art. 154, §1º, da Lei das S.A., porque não se demonstrou que eles teriam sido eleitos por José Seripieri Filho”, porém, a SEP aditou o TA apenas para substituir as referências ao §1º do art. 154, por menções ao *caput* do mesmo dispositivo. Segundo a Defesa, isso também teria provocado a ocorrência de *bis in idem*, uma vez que o TA, conforme aditado, imputa aos Conselheiros infrações: (i) ao **art. 154, caput**, da Lei nº 6.404/1976, em razão da aprovação do Contrato em condições não equitativas; e (ii) ao art. 152, *caput*, **combinado com o art. 154, caput**, ambos da Lei nº 6.404/1976, “na medida em que o pagamento previsto no Contrato tem natureza remuneratória e excede o montante global previamente aprovado pela assembleia geral”.

7. A propósito, entendo que a leitura do parecer da PFE feita pelos referidos acusados não deve prevalecer. Por um lado, o Parecer nº 00179/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de fato, apontou uma falha da Acusação ao imputar aos Conselheiros infração ao §1º do artigo 154, que, como bem destacou a PFE, “exige uma qualificação especial do Administrador, qual seja, a de ter sido eleito por grupo ou classe de acionistas”, sem que isso tivesse sido respaldado pela SEP. O parecer recomendou a retirada da imputação de infração ao art. 154, §1º, ou, *alternativamente*, que a SEP comprovasse que os Conselheiros teriam sido eleitos por José Seripieri.

8. Após revisar as conclusões do parecer, a Subprocuradora-Chefe acrescentou, no Despacho n. 00384/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, uma terceira *alternativa* para o referido saneamento: a inclusão do *caput* do art. 154, em substituição ao §1º. A recomendação da Subprocuradora-Chefe foi, em seguida, endossada pelo Procurador-Chefe, no Despacho n. 00680/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, que, no caso, aduziu ser “*mais acertada a imputação por infração ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/76, do que por infração ao art. 154, §1º*”⁸.

9. A SEP seguiu, assim, uma das alternativas apresentadas pela PFE, inclusive tendo em vista que a referida acusação não tratou da indicação ou eleição dos Conselheiros, de todo modo, não havendo que se falar em inépcia da peça acusatória.

⁸ Doc. SEI 0640190, pp. 500 a 506.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Quanto ao alegado *bis in idem*, observo que o TA explicitou o entendimento da área técnica de que as infrações ao art. 152 e ao art. 154, referidas nos itens (i) e (ii) do §6º deste voto, **são autônomas**, uma vez que “*o ato de liberalidade poderia ter existido ainda que observado o limite global fixado pela assembleia, assim como esse limite poderia ter sido ultrapassado ainda que o Contrato tivesse uma contrapartida justa para a Companhia*”. Contudo, no que tange à segunda acusação, seguindo a linha adotada no âmbito do PAS CVM nº 2011/5211, a SEP optou por imputar aos Conselheiros que aprovaram o pagamento (que, ao ver da SEP, tinha caráter remuneratório) em valor superior ao montante global de remuneração fixado pela assembleia geral, infração combinada dos arts. 152, *caput*, e 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

11. Note-se que, no PAS CVM nº 2011/5211, consoante proposição do Relator, foi adotada redefinição jurídica das infrações originalmente apontadas pela SEP para imputar aos administradores da Eletro Aço Altona S.A. violação combinada dos artigos 152 e 154. Naquele caso, segundo o Relator, “*o estabelecimento de uma remuneração acima daquela que se estabeleceria se os parâmetros legais tivessem sido respeitados – e é essa a tese da acusação objeto [do] processo –, se de fato existiu, definitivamente não é compatível com o dever de os membros do conselho de administração da [companhia] exercerem suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, tal como previsto no art. 154 da lei acionária*”⁹.

12. A meu ver, as conclusões alcançadas no referido precedente não se aplicam a este caso. No PAS CVM nº 2011/5211, os administradores da Eletro Aço Altona S.A. foram acusados de aprovar remuneração expressivamente desproporcional e fora dos padrões de mercado ao presidente do conselho de administração daquela companhia. A aprovação da remuneração e o alegado ato de liberalidade se confundiam, uma vez que, para avaliar se a decisão dos administradores teria sido tomada no interesse da companhia, e, portanto, em linha com os preceitos erigidos no art. 154, seria necessário, ao mesmo tempo, rever o mérito da decisão à luz dos critérios que balizam a fixação da remuneração dos administradores previstos no art. 152, por isso a infração combinada.

13. No presente caso, tem-se situação diferente. Aqui a SEP identificou duas condutas alegadamente irregulares, relacionadas a fundamentos legais distintos. A primeira irregularidade diz respeito à suposta prática do que a SEP reputou ter se “*aproximado*” de um ato de liberalidade: a aprovação do Contrato em condições alegadamente não equitativas. A prática desse ato teria representado uma violação ao dever dos administradores de atuar de acordo com o interesse da Companhia, ensejando a análise dos fundamentos que levaram os Conselheiros a tomar a decisão de aprovar a celebração do Contrato, independentemente de seu valor superar ou não o montante global de remuneração aprovado pela assembleia. A outra irregularidade está relacionada ao fato

⁹ A recapitulação das infrações foi aprovada na Reunião do Colegiado de 17.12.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de o pagamento feito no âmbito do Contrato ter, na visão da SEP, natureza remuneratória, independentemente de se aproximar, ou não, de ato liberalidade. Essa infração teria ocorrido em razão da inobservância do referido montante global da remuneração dos administradores, em alegado descumprimento ao previsto no art. 152, *caput*, tendo a SEP considerado que tal inobservância também se deu em desvio de finalidade (art. 154, *caput*), o que justificaria a combinação dos referidos dispositivos legais quanto à segunda imputação.

14. Assim, se procedentes as acusações, isso não implicaria em dupla responsabilização pela mesma irregularidade. Conforme reconhecido em diversos precedentes da CVM¹⁰, o princípio do *non bis in idem* veda a dupla punição pela mesma conduta e que a caracterização de duplicidade de acusações pressupõe a identidade de (i) sujeitos, (ii) fatos, e (iii) fundamentos jurídicos. No caso, apesar de coincidirem os sujeitos, e, em certa medida, existir uma interligação de fatos, entendendo haver distinção entre os fundamentos jurídicos que embasam as duas linhas de acusação e que a SEP foi clara quanto aos diferentes fundamentos jurídicos que acompanham as imputações.

15. Ademais, as Defesas apresentaram argumentos para rebater tanto as acusações de que o Contrato teria sido aprovado em condições não equitativas, notadamente por contemplar sobreposição de parte das obrigações contratuais e com certos deveres legais, quanto de que o pagamento previsto no Contrato teria natureza remuneratória e teria excedido o montante da remuneração global previamente aprovado pela assembleia geral. A procedência ou não dessas acusações por infrações autônomas e suas capitulações são questões de mérito e não de preliminar.

16. Voto, portanto, pelo indeferimento dessas preliminares.

II.2. Perda de objeto e ausência de justa causa

17. Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout e Wilson Olivieri suscitaram preliminar de perda de objeto do presente PAS, na medida em que, com a aprovação das contas e das DFs relativas ao exercício de 2018, os acionistas da Companhia teriam dado quitação aos Acusados, desonerando-os de suas responsabilidades, nos termos do art. 134, §3º, da LSA. Em sentido semelhante, a defesa conjunta de Alexandre Dias, Arnaldo Curiati e Nilton Molina sustentou que a acusação carece de justa causa, uma vez que *“eventuais questões relativas à negociação e celebração do Contrato nos termos em que foi assinado (...) foram devidamente superadas pelo órgão máximo de expressão da vontade da Companhia”* quando as contas dos administradores foram aprovadas.

18. Esses argumentos também não merecem prosperar. Destaco que, em nosso ordenamento

¹⁰ Por exemplo, PAS CVM nº 02/2009, Dir. Rel. Eli Loria, j. em 01.12.2010; PAS CVM nº RJ2012/1670, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 29.07.2014; PAS CVM nº 04/2010, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em 23.09.2014; PAS CVM nº 06/2012, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 20.08.2018; PAS CVM nº RJ2016/7961, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2020; e PAS CVM nº 19957.000671/2020-51, de minha relatoria, j. em 10.11.2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

jurídico, um mesmo ato ilícito pode ser gerador de responsabilidade no âmbito civil, penal e administrativo. O referido dispositivo da LSA regula a exoneração de responsabilidade dos administradores cuidando, apenas, da responsabilidade civil¹¹. Assim, a atuação sancionadora da CVM subsiste independentemente da exoneração dada pela assembleia geral nos termos do art. 134, §3º, da Lei nº 6.404/1976. Como inclusive reiterado pelo Colegiado em precedente recente¹²:

O poder disciplinar da CVM não se confunde com o regime de responsabilidades da Lei Societária. A toda evidência, a assembleia geral não pode dispor da pretensão punitiva da CVM. O artigo 9º, VI, da Lei nº 6.385/1976 deixa claro que eventuais pretensões indenizatórias da companhia ou de seus acionistas não se confundem com a pretensão punitiva da CVM, quando prevê que “[a] Comissão de Valores Mobiliários (...) poderá (...) aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior as penalidades previstas no artigo 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal”. (grifos no original)

19. Pelo exposto, voto pela rejeição dessas preliminares.

III. MÉRITO

20. De início, cabe ressaltar que se trata de caso complexo, a envolver o exame de um vasto conjunto de fatos e provas (inclusive indiciárias) que desafia a caracterização dos elementos objetivos e subjetivos das infrações em questão, com base no qual pontuo, desde já, que formei convicção pela absolvição dos Acusados, pelos fundamentos que passo a detalhar.

III.1. Aprovação do Contrato em alegada infração ao art. 154, *caput*.

21. Como relatado, a SEP acusou os Conselheiros de terem aprovado a celebração do Contrato em condições não equitativas, em benefício de José Seripieri, em detrimento do interesse da Qualicorp, consubstanciando violação ao disposto no art. 154, *caput*¹³, da LSA.

22. Segundo a SEP, a revisão da conduta dos administradores neste caso deve ser feita sob o prisma do chamado teste de *entire fairness* (ou “justiça integral”), uma vez que a decisão negocial de celebração do Contrato teria sido tomada no intuito de “*beneficiar singularmente uma parte relacionada que figura como diretor presidente*”. Nos moldes do direito norte-americano, a aplicação do teste de *entire fairness* permite ao julgador analisar se o negócio foi ou não “justo”,

¹¹ Nesse sentido, Luiz Antonio Sampaio Campos observa que “o sistema de responsabilidade da LSA resulta apenas a responsabilidade no plano civil. Não é, todavia, a única responsabilidade a que podem estar sujeitos os administradores. Estes poderão, ainda, conforme o caso, sujeitar-se a responsabilidade criminais e administrativas, em que os conceitos não são necessariamente iguais aos previstos para a responsabilidade, especialmente no tocante ao regime da formação de culpa, entre outros”. CAMPOS, Luiz Antonio Sampaio. “Deveres e responsabilidades dos administradores”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). Direito das Companhias. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1.203.

¹² PAS CVM nº RJ2014/13977, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 30.01.2020. No mesmo sentido, PAS CVM nº RJ2018/8378, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 21.07.2020.

¹³ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (grifos adotados)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a demandar que tenha sido “(i) realizad[o] por preços e condições que seriam praticados entre partes independentes (aspecto material); (ii) resultado de um processo que garantiu a tomada de decisão no interesse da companhia (aspecto procedimental)”, consoante apontado pela Acusação.

23. Quanto ao aspecto material, a SEP sustentou que os termos e condições do Contrato não eram justos, “[n]a extensão em que o pagamento previsto no Contrato se sobrepõe à remuneração recebida diretamente em razão do exercício do cargo por José Seripieri”, ficando, assim, “clara a existência de uma vantagem indevida suportada pela Companhia” e tendo em vista que “o preço previsto no Contrato em contrapartida ao dever de não competição foi inadequado seja no parâmetro utilizado para determiná-lo – a remuneração anual do diretor presidente – seja no valor específico da remuneração considerado”.

24. Quanto ao aspecto procedimental, a Acusação aduziu que, apesar de terem sido adotadas medidas que visavam conferir robustez ao processo decisório (como a contratação de consultores, a discussão da matéria durante um extenso período e o não envolvimento da parte interessada no processo decisório), as circunstâncias do caso demandavam um “*grau elevado de cautela*” e a adoção de medidas adicionais, tal como a “*submissão do tema à prévia aprovação dos acionistas*”.

25. As Defesas, por sua vez, contestaram as colocações e conclusões da SEP, opondo-se, ao uso do teste de *entire fairness* como padrão de revisão mais adequado para o caso. Nessa linha, a Defesa de José Seripieri apresentou parecer de escritório de advocacia norte-americano que conclui que, tal como desenvolvida nas cortes americanas, a doutrina da *entire fairness* não deveria ser aplicada a este caso, devendo o julgador se ater à aplicação da *business judgment rule*.

26. Os Conselheiros sustentaram que agiram de forma desinteressada, não havendo qualquer indício de que teriam atuado sob a influência ou para atingir o interesse individual de José Seripieri, bem como que a decisão também foi refletida e informada, pois seguiu todos os procedimentos internos e legais então aplicáveis, além de ter tido amparo na orientação de consultores externos.

Breves considerações sobre o padrão de revisão aplicável

27. No contexto de que se trata, entende-se por padrão (ou *standard*) de revisão a expressão que descreve o exercício feito pelos julgadores (ou aplicadores do direito) para avaliar se dada conduta viola ou não os deveres fiduciários dos administradores. Em outras palavras, os *standards* de revisão são uma espécie de teste (padrão de revisão) a ser aplicado pelo julgador para determinar se um administrador cumpriu ou não seus deveres fiduciários (padrão de conduta).

28. Nos PAS CVM nº RJ2019/0878 e nº RJ2019/3679, julgados em 31.08.2021, teci breves considerações sobre os deveres fiduciários dos administradores de companhias e os padrões de revisão aplicáveis, ressaltando a cautela necessária para a adoção, pela CVM, de conceitos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

desenvolvidos com base em experiência estrangeira, devendo-se considerar as diferenças fundamentais dos regimes jurídicos subjacentes, sob pena de esgarçamento ou distorção de institutos alheios à nossa realidade ou fora do contexto de aplicação em que estruturados, como, por exemplo, o teste de *entire fairness*, construído no âmbito do direito norte-americano, a permitir que o julgador, em análise com foco nos termos do negócio, avalie se este foi ou não “justo”¹⁴.

29. Quanto à aplicação do teste de *entire fairness*, destaquei, naquela ocasião, que o ex-Diretor Gustavo Borba havia defendido a aplicação de tal padrão de revisão em caso em que se discutia decisão negocial tomada por membros de conselho de administração que tinham interesse pessoal na aprovação de uma determinada matéria, acusados de infração ao art. 154 da LSA¹⁵. Tal posição, porém, não foi acompanhada pela maioria do Colegiado, tendo o ex-Diretor Gustavo Gonzalez se manifestado no sentido de que “[o] exame substantivo imposto pelo artigo 154 não envolve, contudo, uma avaliação invasiva como a do *entire fairness*, mas a verificação da existência de elementos que indiquem o desvio de poder, ou seja, que os atos praticados pelos administradores visavam a outros fins que não a lograr os interesses da companhia”. Prevaleceu, naquele caso, o entendimento de que o teste de *entire fairness* não seria propriamente o padrão de revisão aplicável quando diante de decisões negociais que infringem o dever previsto no art. 154 da LSA, cuja violação se traduz em desvio de poder ou finalidade.

30. Note-se que este PAS não trata de alegado descumprimento de dever de diligência (art. 153 da LSA), como ocorreu no âmbito dos PAS CVM nº RJ2019/0878 e nº RJ2019/3679, e sim de acusação de desvio de poder ou finalidade, por alegada atuação que visaria beneficiar certo administrador/acionista em detrimento do interesse social (art. 154). A propósito, vale destacar o seguinte trecho do voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez:

[A]legados episódios de desvio de poder (art. 154) devem ser analisados com uma **lente distinta** daquela que usualmente se emprega para apurar falhas de diligência (art. 153). Enquanto as análises de diligência focam, no mais das vezes, nos procedimentos adotados na tomada de decisões, a revisão em casos **de suspeita de desvio** requer um **olhar diferente** e uma **sindicância mais abrangente**, que busque apurar **se atos**

¹⁴ Com esclarecido pelo Justice Moore no caso Weinberger v. UOP, Inc., em que a Suprema Corte de Delaware sistematizou os contornos do conceito de *entire fairness*: “The concept of fairness has two basic aspects: fair dealing and fair price. The former embraces questions of when the transaction was timed, how it was initiated, structured, negotiated, disclosed to the directors, and how the approvals of the directors and the stockholders were obtained. The latter aspect of fairness relates to the economic and financial considerations of the proposed merger, including all relevant factors: assets, market value, earnings, future prospects, and any other elements that affect the intrinsic or inherent value of a company's stock. However, the test for fairness is not a bifurcated one as between fair dealing and price. All aspects of the issue must be examined as a whole since the question is one of entire fairness. However, in a non-fraudulent transaction we recognize that price may be the preponderant consideration outweighing other features of the merger.” [Citações internas omitidas] Weinberger v. Uop, Inc, 457 A.2d 701 (Del. 1983), citado em Andrade de Sá, Rafael Vieira de. *O Entire Fairness Test no Direito Norte-Americano*, Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 79/2018, p. 99 – 125, Jan-Mar 2018, DTR\2018\9066, p. 7.

¹⁵ PAS CVM nº RJ2013/11703, j. em 31.07.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

praticados pelos administradores, ainda que formalmente corretos, visavam em essência a atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da companhia.¹⁶ (grifos adotados)

31. Embora não me pareça que o embate acerca do padrão de revisão a ser adotado seja chave para o deslinde dessa imputação, esclareço que não concordo com a alegação das Defesas de que o padrão de revisão aplicável seria o da *business judgment rule*. Com efeito, não se poderia admitir que decisões negociais de administradores que sejam alegadamente lesivas ao interesse social¹⁷ estivessem resguardadas de qualquer grau de exame quanto ao seu mérito, ainda que tenham sido tomadas por administradores desinteressados e de modo refletido e informado.

32. Ademais, independentemente da diligência com que foi conduzido o processo decisório, a apreciação quanto à existência ou não de desvio de poder ou finalidade, a meu ver, enseja certa apreciação de mérito quanto ao alinhamento da decisão à lei e aos interesses da companhia. Como tive a oportunidade de me manifestar no âmbito do PAS CVM nº RJ2016/5733¹⁸, o exame do mérito de decisão negocial pela CVM é justificável quando o processo decisório, ainda que regular, não refletir termos razoavelmente compreensíveis e racionais, permitindo concluir pela atuação com desvio de finalidade ou apontando para uma atuação desleal dos administradores.

33. Isso não significa que o julgador esteja autorizado a ditar termos e condições ideais em que considere que o negócio deveria ter sido tomado a fim de estabelecer o alinhamento ao interesse social, no que estaria indevidamente se substituindo em atribuição do administrador.

34. Em casos como o enfrentado neste PAS, como bem explanado pelo Presidente Marcelo Barbosa, em voto no precedente já citado¹⁹:

[O] exame dessa questão envolve a análise da conduta dos administradores, **inclusive do conteúdo das decisões** tomadas no âmbito dos órgãos colegiados (conselho de administração e diretoria), com o objetivo de **aferir se elas se conciliam com o objeto social e os interesses da companhia**. Trata-se, assim, de **exame de mérito**, cabendo aos administradores, quando em face da acusação por **desvio de poder**, lançar mão de elementos aptos a demonstrar o alinhamento de seus atos aos interesses da companhia. (...) 9. No entanto, é importante frisar, **o exame de mérito que o art. 154**

¹⁶ PAS CVM nº RJ2017/5122, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 30.04.2020.

¹⁷ Como ressalvei em meu voto vista no âmbito do PAS CVM nº SP2017/500 (PAS SEI nº 19957.010032/2017-07), j. em 27.04.2021: “(...) a fim de avaliar se determinado ato foi praticado com desvio de finalidade não basta que se verifique a regularidade formal do ato em si e o alcance de fins aceitos pelo ordenamento jurídico. Tais elementos, embora relevantes, não levam, necessariamente, à conclusão de que tal ato, em essência, foi praticado no melhor interesse da companhia.”

¹⁸ PAS RJ2016/5733, j. em 03.12.2019, de minha relatoria. Nesse caso, concluí que a ofensa ao art. 154 verificou-se “porque restou demonstrado que os Conselheiros dispunham de todas as informações acerca do preço exorbitante, o qual, por sua vez, compromet[ia] a racionalidade da operação, sob a ótica do interesse da Companhia, e conscientemente se pautaram pela premência de viabilizar a saída do (...) ao preço pactuado (...). Não obstante a excessiva onerosidade da [operação], os Conselheiros optaram por validá-la (...).” (grifos adotados)

¹⁹ PAS CVM nº RJ2013/11703, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 31.07.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

impõe não envolve um juízo de adequação da conduta ou decisão do administrador no sentido de avaliar se foram ideais para a companhia. (grifos adotados)

35. Neste caso, entendo que a alegada infração ao art. 154 não deve ser analisada sob o crivo do teste de *entire fairness*, tampouco sob a ótica da *business judgment rule*, cabendo sim avaliar, no mérito, o racional adotado e, assim, a finalidade pretendida com a decisão para aferir se visava “*lograr os fins e interesses da companhia*”, como preceitua o art. 154, *caput*, da LSA.

O interesse da Companhia na celebração do Contrato

36. Passo a analisar os elementos apontados pela SEP para demonstrar que a decisão de aprovar a celebração do Contrato, nos termos e condições propostos, não teria sido tomada com vistas a atender a um legítimo interesse da Companhia, bem como os apresentados pelos Conselheiros para infirmar a tese acusatória.

37. De início, cabe reconhecer que a celebração de contratos de *non-compete* é bastante disseminada no âmbito empresarial²⁰, e tem como principal objetivo a proteção do interesse social contra o desvio de clientela ou a transmissão de informações confidenciais²¹, bem como na preservação do capital intelectual²². A SEP não contesta que a celebração de pacto de não-competição representaria, a princípio, um benefício para a Companhia. Com efeito, a Acusação não coloca em xeque o entendimento dos Conselheiros de que era do interesse da Qualicorp definir regras contratuais a assegurar potencial “saída ordenada” do acionista fundador da Companhia e à época, sem dúvida, seu principal executivo.

38. Admitida a existência de um interesse, em tese, legítimo para a celebração do Contrato, o que se discute é (i) se a decisão dos Conselheiros de aprovar o Contrato nos termos em que celebrado foi tomada em desvio de finalidade com vistas a beneficiar José Seripieri e (ii) se tais termos contratuais seriam condizentes com uma operação dessa natureza representando efetivo alinhamento com os interesses da Companhia.

39. Como dito, na avaliação da SEP, o Contrato foi celebrado em condições não equitativas

²⁰ Tendo em vista a função econômica que lhes é subjacente, tais cláusulas vem sendo frequentemente empregadas em operações de reorganização societária, *joint-ventures* e negócios similares. Nos casos de alienação de estabelecimento comercial (trespasse), a vedação à concorrência encontra expressa previsão legal (art. 1.147 do Código Civil). Cf. FORGIONI, Paula A. *Contratos Empresariais: Teoria Geral e Aplicação*. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 300.

²¹ KESAN, Jay P.; HAYES, Carol Mullins. *The Law and Policy of Non-Compete Clauses in the United States and Their Implications* (2011). Comparative Business Innovation: A Legal Balancing Act, Marilyn Pittard, ed., Edward Elgar Publishing, 2013, Illinois Public Law Research Paper No. 11-07, p. 384. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1948593>.

²² THOMAS, Randall S. et al. *An Empirical Analysis of Non-Competition Clauses and Other Restrictive Post-Employment Covenants* (2014). Vanderbilt Law Review, Vol. 68, No. 1, 2015, Vanderbilt Law and Economics Research Paper No. 14-11, pp. 9-10. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2401781>.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

que visavam beneficiar “singularmente” José Seripieri. Nesse sentido, em síntese, destacou que:

- i. as obrigações assumidas por José Seripieri no âmbito do Contrato se confundiam, em parte, com o dever de lealdade imposto por lei a este acusado, o que, para a Acusação, não foi considerado pelos Conselheiros quando da aprovação das condições do acordo;
- ii. o valor da remuneração anual utilizado para calcular a contraprestação a ser paga pela Companhia em razão da celebração do Contrato teria sido sugerido sem considerar as evidências apresentadas por consultores externos que sinalizavam um valor bastante inferior àquele usado como referência;
- iii. considerando que parte das obrigações assumidas por José Seripieri em razão do Contrato já decorria dos deveres fiduciários assumidos na qualidade de administrador da Qualicorp, as obrigações “inéditas” previstas no Contrato em decorrência do Lock-up não representariam benefício suficiente para a Companhia que justificasse o desembolso da contrapartida assumida pela Qualicorp; e
- iv. para garantir o alinhamento do Contrato com os interesses da Companhia, os Conselheiros deveriam ter submetido tal negócio à aprovação dos acionistas.

40. Para afastar as conclusões da SEP, os Conselheiros sustentaram, em linhas gerais, que:

- i. não existem provas que corroborem a afirmação da SEP de que eles teriam agido de forma a beneficiar José Seripieri em detrimento da Qualicorp ou que sugerissem que sua atuação se deu de forma não independente ou desinteressada;
- ii. atuaram nos estritos limites da boa-fé, buscando atender aos interesses da Companhia ao evitar possíveis prejuízos decorrentes da saída de um dos seus principais executivos para um negócio concorrente, em linha com as orientações de consultores externos contratados;
- iii. o valor e as condições do Contrato foram baseados nas orientações e nos estudos realizados por consultores externos contratados pela Qualicorp e se fiaram em tais orientações para a tomada da decisão;
- iv. o processo decisório não contou com a interferência de José Seripieri e as discussões dos termos do Contrato foram conduzidas com o intermédio de assessores externos, havidas em pelo menos 14 reuniões, realizadas ao longo de quase oito meses;
- v. as obrigações assumidas por José Seripieri no Contrato, embora se assemelhem, em certa medida, aos deveres fiduciários deste administrador, superam o regime de “não-competição” previsto em lei, de modo que não seria correto dizer que o pagamento previsto no Contrato se sobrepõe à remuneração recebida diretamente por José Seripieri; e
- vi. todos os procedimentos de governança aplicáveis foram respeitados, não sendo cabível exigir que a matéria seja submetida à aprovação de outro órgão societário quando a lei ou o estatuto social da Companhia assim não o determina.

41. Os argumentos e contra-argumentos resumidos acima abrangem três grupos de questões primordiais para o deslinde deste caso, que abordarei na seguinte sequência: (i) a sobreposição entre algumas das obrigações referidas no Contrato e certos deveres fiduciários e vedações legais a que José Seripieri já estava sujeito enquanto administrador da Qualicorp; (ii) as circunstâncias subjacentes e o modo como se deu o processo de negociação e aprovação do Contrato e seus fundamentos; e (iii) a independência dos Conselheiros e os objetivos do Contrato.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

As obrigações contratuais e os deveres fiduciários e vedações legais

42. Inicialmente, destaco que o prazo de vigência das obrigações estabelecidas no Contrato (de seis anos) teve início a partir de sua assinatura, em 28.09.2018, quando José Seripieri ainda estava no exercício das funções de Diretor-Presidente e conselheiro de administração da Companhia, que ocupou até 12.11.2019, quando renunciou aos referidos cargos na administração²³. Tanto a vigência das obrigações contratuais quanto o termo final do Contrato independiam de José Seripieri estar, ou não, no exercício de qualquer função ou cargo de administrador na Qualicorp.

43. Ressalto que, em geral, os contratos de não-concorrência visam restringir a atuação do executivo após o seu desligamento da companhia²⁴, quando não mais estará sujeito ao cumprimento de deveres fiduciários inerentes ao exercício de cargo na administração. Nesse aspecto, concordo com a Acusação que o Contrato tinha certas características peculiares.

44. Em específico, enfrenta-se a questão quanto a se (e em que medida) as obrigações contratuais pactuadas estariam abrangidas pelo dever fiduciário do administrador de agir com lealdade para com a Companhia. Afinal, o dispêndio de recursos como contrapartida de uma obrigação que a contraparte já tenha em decorrência de obrigação legal não seria necessário para atendimento do interesse da companhia, eis que existente, mesmo que não contratada.

45. No caso concreto, os Acusados apontaram que as obrigações contratadas têm um espectro bem mais amplo, tanto do ponto de vista (i) temporal, já que subsistiriam se José Seripieri deixasse de ser administrador da Companhia²⁵, quanto (ii) objetivo, uma vez que (A) não se limitavam às de não-competição, abrangendo também as de não-solicitação e o Lock-up, e (B) mesmo as obrigações de não-competição propriamente ditas tinham uma abrangência bem maior em relação às restrições decorrentes do disposto nos arts. 155, I²⁶, e 147, §3º²⁷, da LSA.

²³ Conforme fato relevante divulgado em 12.12.2019 (Doc. SEI 1216499, doc. 2).

²⁴ “A empresa normalmente negocia a inclusão dessa cláusula no contrato de trabalho do executivo para garantir que eventuais técnicas de produção, métodos de trabalho, conhecimentos ou informações estratégicas que serão transmitidas ao executivo durante o contrato de trabalho, não sejam repassadas a um concorrente após o término da relação de trabalho com o executivo. A ideia é proteger o negócio da empresa, restringindo apenas parcialmente a liberdade de trabalho do executivo.” (grifo aditado) (RABAY, Dario Abrahão. “A Cláusula de Não Concorrência no Contrato de Trabalho do Executivo”. In: Brasil M&A: Guia para Fusões e Aquisições de Empresas Brasileiras (Coord.: Marcelo Siqueira et al). Rio de Janeiro: Donnelley Financial Solutions do Brasil Ltda, 2017, p. 111).

²⁵ Observo que a cláusula 2.1. do Contrato expressamente dispõe que as obrigações pactuadas vigoram “independentemente de estar o Acionista em exercício, ou não, de qualquer função ou cargo de administrador na Companhia e/ou subsidiárias durante a vigência das obrigações do Contrato” (grifos aditados).

²⁶ Art. 155. O administrador **deve servir com lealdade** à companhia e **manter reserva sobre os seus negócios**, sendo-lhe vedado: I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as **oportunidades comerciais** de que **tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo**. (grifos aditados)

²⁷ Art. 147. Quando a lei exigir certos requisitos para a investidura em cargo de administração da companhia, a assembleia-geral somente poderá eleger quem tenha exibido os necessários comprovantes, dos quais se arquivará



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

46. De fato, na perspectiva temporal, a questão, a meu ver, não desperta maiores dificuldades, pois o Contrato é expresso ao dispor que as obrigações pactuadas estavam desvinculadas do exercício do cargo de administrador. A relevância desta questão “temporal” ficou ainda mais evidente com a renúncia de José Seripieri, em 12.11.2019, aos cargos que exercia na administração da Qualicorp, observando-se que o Contrato continuou em vigor, tendo inclusive sido posteriormente aditado, com extensão de vigência por mais dois anos, como consta do Relatório.

47. A análise torna-se mais complexa, porém, quando diante do referido aspecto objetivo do Contrato, ou seja, quanto às obrigações contratadas. Nesse ponto, ressalto, em primeiro lugar, que concordo com os Acusados quanto a que o escopo do Contrato extrapola as obrigações de não-competição. Ainda que se possa considerar a obrigação de não-solicitação como componente das obrigações de não-competição (como se infere das Cláusulas 2.1 e 4.1 do Contrato), não se pode dizer o mesmo da obrigação de Lock-Up. Afora a proibição à negociação de valores mobiliários com base em informações relevantes ainda não divulgadas ao mercado, não há disposição legal que imponha ao administrador, também acionista, uma restrição à negociação de sua participação acionária. Por isso, entendo que não há sobreposição entre a obrigação de Lock-up assumida em razão do Contrato e os deveres fiduciários de José Seripieri.

48. A dificuldade reside em cotejar as obrigações de não-concorrência nos termos contratados com os deveres fiduciários a que se sujeitam os administradores por força de lei. Para maior clareza, começo por reproduzir a disposição contratual em comento²⁸:

4. NÃO COMPETIÇÃO DE NEGÓCIOS E NÃO SOLICITAÇÃO

4.1. O Acionista, diretamente ou por intermédio de qualquer pessoa física ou jurídica ou qualquer Parte Relacionada, nos termos dos itens (i) a (iv) abaixo, obriga-se, pelo prazo de 6 (seis) anos contados da data de assinatura deste Contrato, a:

(i) abster-se de possuir, investir, administrar, operar, assessorar, associar-se, prestar serviços, colaborar, dar informações ou fornecer documentos, prestar consultoria, ter participação societária, controlar, participar da propriedade, administração, operação ou controle, ou ser vinculado como sócio, acionista, investidor, credor, empregado, conselheiro, diretor, prestador de serviços, consultor ou de qualquer outra qualquer forma atuar em qualquer Negócio;

(ii) não estabelecer ou manter qualquer relação comercial com quaisquer empregados e/ou fornecedores e/ou clientes e/ou distribuidores e/ou parceiros comerciais e/ou consultores da Companhia e de suas controladas, que possa prejudicar estas e/ou as relações e os negócios havidos entre estas e aqueles;

cópia autêntica na sede social. (...) § 3º O **conselheiro deve** ter reputação ilibada, **não podendo ser eleito, salvo dispensa da assembleia-geral**, aquele que: I - ocupar **cargos em sociedades** que possam ser **consideradas concorrentes no mercado**, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal; e II - tiver interesse conflitante com a sociedade. (grifos aditados)

²⁸ O termo “Negócios” é definido, nos termos do Contrato, como “qualquer atividade relacionada à gestão e corretagem de planos de saúde; consultoria, gestão de risco e outras atividades ligadas à promoção de saúde e assistência na administração de benefícios de planos de saúde, estipulantes, administradores de estipulantes e outras atividades correlatas, administradoras de benefícios, corretoras de seguros, intermediadoras de negócios na área de saúde, operadoras privadas de planos de saúde, administradoras de planos de saúde, TPA (*Third Part Administrator*) e PPO (*Preferred Provider Organization*), e quaisquer negócios atualmente integrantes do objeto social da Companhia relacionados a seguros e planos de saúde.” (Doc. SEI 0640190, p. 55).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(iii) não solicitar, aliciar, incitar, desviar, retirar ou tentar solicitar qualquer cliente, fornecedor, distribuidor ou negócios da Companhia ou de suas controladas, nem de qualquer forma interferir no relacionamento mantido entre a Companhia e seus clientes e/ou fornecedores e/ou distribuidores, atuais ou futuros;

(iv) não celebrar compromissos e/ou acordos definitivos com finalidade equivalente ou similar ao Negócio da Companhia ou de suas controladas.

4.1.1. O Acionista, nos termos dos itens (i) e (ii), obriga-se, pelo prazo de 6 (seis) anos contados da data de assinatura deste Contrato, a:

(i) não solicitar ou encorajar qualquer pessoa a deixar seu emprego ou deixar de prestar serviços para a Companhia ou suas controladas, seja tal pessoa um empregado ou prestador de serviços; e/ou

(ii) não contratar qualquer dos empregados da Companhia, exceto mediante processo de seleção e contratação dirigido indistintamente a qualquer candidato apto a preencher as especificações do cargo.

4.2. As obrigações previstas nas cláusulas 4.1 e 4.1.1 acima serão denominadas obrigações de “Não Competição de Negócios” e são válidas e aplicáveis exclusivamente para Negócios em todo o território nacional.

49. Como a lei não atribui ao administrador, de forma expressa, o dever de “não-concorrência”, ao menos não sob essa denominação nem com alcance definido, a controvérsia gira em torno, mais especificamente, da extensão do dever de lealdade sob o prisma concorrencial.

50. Nesse tocante, ressalto que o *caput* do art. 155 da LSA impõe genericamente aos administradores a obrigação de “servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios”. Os administradores não podem, portanto, tendo em vista a posição de confiança que ocupam, praticar condutas nocivas ao interesse social, cabendo-lhes, ao revés, agir com boa-fé para “fazer o interesse da companhia sobrepor-se ao seu”²⁹.

51. Os incisos do referido dispositivo enunciam, em elenco meramente exemplificativo, determinados comportamentos explicitados pela lei como desleais, dentre os quais se destaca, para os fins deste processo, aquele contido no inciso I, consistente na utilização de oportunidade comercial da companhia. Esse preceito consagrou a chamada *corporate opportunity doctrine* do direito norte-americano, que veda ao administrador se apropriar das oportunidades comerciais de que tenha conhecimento no exercício do seu cargo.

52. A lei societária não detalha a maneira de se aferir, *in concreto*, a ocorrência do ilícito, mas doutrina e jurisprudência pátrias vêm, com inspiração no assentado no direito norte-

²⁹ CAMPOS, Luiz Antônio de Sampaio. “Deveres e responsabilidades dos administradores”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). *Op. Cit.*, p. 1137.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

americano, adotando alguns parâmetros para tanto. Como bem sintetizado por Nelson Eizirik³⁰:

Há alguns testes para se caracterizar a ilicitude do ato, desenvolvidos no direito societário norte-americano e aplicáveis em nosso sistema jurídico:

- (i) a possibilidade de utilização da oportunidade por parte da companhia; se ela não tem condições financeiras ou patrimoniais de aproveitar a oportunidade, não há usurpação;
- (ii) o fato de estar, tal oportunidade, inserida na linha de negócios da empresa, fazer parte de seu objeto social ou, pelo menos, ser de utilidade para o desenvolvimento de suas atividades empresariais; e
- (iii) o fato de poder acarretar, tal oportunidade, um benefício ou vantagem para a companhia.

53. Neste caso, tem-se que as obrigações de não-concorrência consoante previstas no Contrato independem de a Qualicorp ter recursos ou interesse para usufruir a oportunidade comercial. Nesse ponto, concordo com o entendimento exarado no parecer jurídico da lavra do Dr. Paulo Cezar Aragão, trazido aos autos pela defesa de Raul Rosenthal, no sentido de que a não-competição prevista no Contrato tem alcance mais amplo do que o dever legal decorrente do disposto no inciso I do art. 155 da Lei nº 6.404/1976. Como bem destacou o douto parecerista:

A hipótese prevista no **inciso I do art. 155** – usurpação de oportunidade comercial – **pode ser entendida como uma forma de concorrência** com a companhia, **tal como** compreendido na Não Competição. Porém, para que a vedação legal se aplique, é necessário, no mínimo, que (i) a oportunidade seja de interesse da Companhia; (ii) essa esteja compreendida em seu objeto social; e (iii) a Companhia tenha os recursos para explorar tal oportunidade comercial.

Portanto, não atendidos esses requisitos, o administrador poderia, **sem infringir seus deveres** para com a Companhia, se apropriar da oportunidade comercial. De forma oposta, **contudo, pela Não Competição contratada, a vedação independe da capacidade e do interesse da Companhia para explorar a oportunidade comercial**, bastando que essa esteja compreendida no Negócio. (grifos adotados)

54. Por outro lado, cabe também reconhecer que a competição, em sentido amplo, não se esgota na questão da apropriação de oportunidade comercial³¹. Afinal, o administrador não pode perseguir a promoção de interesses pessoais que sejam incompatíveis com o interesse da companhia, tendo em vista o seu dever de agir com lealdade e boa-fé.

55. Ressalvo, ainda, que, ao se lançar em atividade concorrente, o administrador se coloca em situação de potencial conflito de interesses, independentemente de uma análise quanto à capacidade financeira ou interesse da companhia. Tanto é assim que a Lei nº 6.404/1976, em seu art. 147, § 3º, inciso I³², em princípio veda a eleição, para o cargo de conselheiro de administração

³⁰ A Lei das S/A Comentada, Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 367.

³¹ Nas palavras de Luiz Antonio de Sampaio Campos, “o conceito de que o administrador **não deve concorrer** com a companhia [...] **se infere do sistema da LSA**.” (grifos adotados) (“Deveres e responsabilidades dos administradores”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). *Op. Cit.*, p. 1137).

³² Vale lembrar que a regra do § 3º do art. 147 foi introduzida no âmbito da reforma promovida pela Lei nº 10.303/2001.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de companhia aberta³³, de pessoa que também ocupe “cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal”. Trata-se, porém, de impedimento relativo, pois pode ser dispensado pela assembleia.

56. A esse respeito, são pertinentes duas considerações. A primeira é que eventual dispensa concedida pela assembleia geral tem efeitos para fins de elegibilidade do candidato vinculado a sociedade concorrente, porém não representa um salvo-conduto para que, uma vez eleito, esse possa atuar de forma a perseguir seus interesses pessoais em detrimento do interesse social.

57. A segunda diz respeito à extensão do impedimento. Como aponta Nelson Eizirik³⁴:

O impedimento por vinculação a concorrente não se caracteriza apenas com relação aos cargos nos conselhos de administração, consultivo ou fiscal, uma vez que qualquer cargo ou função na concorrente acarreta o impedimento. **O fundamento do impedimento está na proteção do segredo empresarial**, entendido como a formulação de políticas e de métodos competitivos, **assim como dos segredos dos negócios**, que compreendem **carteiras de clientes, listas de fornecedores, campanhas de marketing e de vendas**.

(...) Adicionalmente, nos termos da legislação concorrencial, o **acesso a informações sensíveis** por parte de empresa concorrente direta pode caracterizar ato ilícito, por facilitar a colusão e resultar em cartel. (...) Assim, participações societárias minoritárias em concorrente direto, que permitam a eleição de membro do conselho de administração ou do conselho fiscal, seja pelo eventual incentivo à colusão, seja pelo acesso a informações estratégicas, podem gerar preocupações concorrenciais. (grifos aditados)

58. Assim, percebe-se que a verificação do impedimento pela assembleia geral vai requerer uma análise das **circunstâncias fáticas** presentes no caso, na qual deverão ser sopesados aspectos como a real incompatibilidade da atividade concorrente e a posição ocupada pelo administrador³⁵. O que se busca evitar, como visto, é uma “atuação cruzada” do administrador, que o possa levar a colocar em segundo plano o interesse social que deveria proteger.

59. Tem-se, portanto, que o grau de interferência do administrador no negócio concorrente deve ser levado em consideração. Nessa linha, investimentos meramente passivos, a princípio, não se enquadrariam na proibição legal³⁶. Portanto, considero igualmente acertada a conclusão do

³³ Não obstante constar do dispositivo referência apenas ao conselheiro de administração, entende-se que sua aplicação se estende aos diretores. vide EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada*, vol. II. *Op. Cit.*, p. 321. Nesse sentido também é expresso o art. 4º da Instrução CVM nº 367/2002.

³⁴ *A Lei das S/A Comentada*, vol. II. *Op. Cit.*, pp. 326-327.

³⁵ Mais uma vez, cite-se Luiz Antônio de Sampaio Campos: “*Embora o conceito [de que o administrador não deve concorrer com a companhia] seja único e aplicável a todos os administradores, sua extensão e rigidez deverão sofrer gradações, de acordo com o cargo que o administrador exercer, considerando o órgão da administração a que pertence – se Diretoria ou Conselho de Administração –, a eventual área que lhe é afeta, e, ainda, a participação dos chamados membros externos do Conselho de Administração.*” (“Deveres e responsabilidades dos administradores”. In: LAMY FILHO, Alfredo; BULHÕES PEDEREIRA, José Luiz (Org.). *Op. Cit.*, p. 1137).

³⁶ Uma visão mais tradicional da doutrina, já superada, desconsidera o efeito de determinada aquisição de participação minoritária sobre a concorrência para fins do disposto no art. 147. Nesse sentido, ao comentar o referido dispositivo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

parecer do Dr. Paulo Cezar Aragão no sentido de que a não-competição prevista no Contrato também vai “além da vedação legal do art. 147, § 3º, pois inclui o simples investimento passivo” em sociedade concorrente.

60. Entretanto, a redação da cláusula 4.1 do Contrato revela que algumas das obrigações ali assumidas por José Seripieri, em relação ao período temporal em que esse ainda atuasse como Diretor-Presidente ou conselheiro de administração da Companhia, podem ser interpretadas como inerentes ao dever fiduciário de lealdade ou decorrentes de vedação legal imposta. É o caso, por exemplo, das obrigações de não “dar informações ou fornecer documentos”, de não “administrar” ou “operar” negócio concorrente, de não estabelecer ou manter relação comercial “que possa prejudicar” a Companhia, de não “aliciar” ou “desviar” cliente, fornecedor ou distribuidor da Companhia; enfim, ações que me parecem incompatíveis com uma conduta leal de administrador, que, como dito, deve atuar sempre no interesse da companhia.

61. Por outro lado, há outras das obrigações de *non-competite* estabelecidas no Contrato em caráter bem mais restritivo do que poderia se extrair das disposições legais, inclusive obrigações não necessariamente vinculadas a uma participação ativa de José Seripieri no negócio concorrente (como abster-se de “investir”, “ter participação societária”, “ser vinculado como sócio, acionista, investidor, credor ou consultor”). Outras, por sua vez, estão compreendidas em uma zona cinzenta, que, a rigor, a meu ver, permitiriam tanto uma quanto outra interpretação.

62. Levando em consideração que a vigência do Contrato teve início enquanto ele ainda era administrador da Qualicorp, entendo que tem razão a Acusação quando aponta que há obrigações assumidas por José Seripieri que se confundiam com obrigações decorrentes de deveres e vedações legais a que ele estava sujeito em razão dos cargos que ocupava.

63. Tal fato, porém, não é suficiente para concluir que a aprovação do Contrato se deu com desvio de finalidade nem que esse teria se aproximado de mera liberalidade, como se disso se pudesse extrair que o negócio jurídico foi celebrado com o propósito de beneficiar *singularmente* a contraparte e não para atender o interesse social. Ademais, por se tratar de acusação de infração ao art. 154 da LSA, portanto, de atuação em alegado desvio de finalidade, não seria suficiente aferir potencial lesividade do Contrato, mas necessário avaliar se a finalidade almejada se desviou

legal, pronuncia-se Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto: “A lei não proíbe o administrador de exercer outras atividades empresariais ou profissionais, nem exige dedicação exclusiva. O administrador não está impedido de participar de outras sociedades como mero sócio ou acionista. O que a lei veda é apenas que o membro do conselho de administração ocupe cargos de administração em sociedades concorrentes (art. 147, § 3º, I).” (Lei das S.A. Comentada e Anotada, 6ª Edição. São Paulo: Quartier Latin, 2020, p. 585) (grifos adotados). De qualquer forma, mesmo que se adote a visão contemporânea que leva em consideração esses efeitos, fato é que não se trata de análise simples, que possa ser feita aprioristicamente, independentemente das circunstâncias presentes no caso, sendo, dessa forma, possível afirmar-se que a realização de investimentos passivos, em tese, não daria ensejo à vedação legal.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

do atendimento aos interesses da Companhia, direcionando-se a beneficiar José Seripieri.

64. Dito isto, passo ao exame do conjunto fático-probatório a fim de apurar se a conduta dos Conselheiros se reveste do elemento subjetivo necessário à responsabilização por violação ao art. 154, *caput*, da LSA. Tendo em vista que não encontro nos autos provas diretas a indicar com clareza a intenção de aprovar operação lesiva aos interesses da Companhia, cabe analisar o processo decisório com vistas a ponderar indícios e contraindícios quanto à prática do ilícito.

As circunstâncias do caso, o processo decisório e seus fundamentos

65. Em primeiro lugar, cabe recapitular certos fatos incontroversos e circunstâncias subjacentes deste caso concreto, detalhados no Relatório:

- i. as discussões que culminaram na celebração do Contrato tiveram início em março de 2018 após a comunicação de José Seripieri ao CA quanto à sua **intenção de deixar** a administração da Qualicorp, o que deu ensejo a uma série de trabalhos e estudos realizados pelas Consultorias (**Spencer Stuart e Mercer**), contratadas pela Companhia em **abril de 2018**, direcionados à celebração de acordo de não competição. Em junho de 2018, o diretor comercial (não estatutário) saiu da Companhia, não tinha acordo de não competição, recusou-se a celebrar contrato da espécie e lançou-se em negócio concorrente, o que acentuou a preocupação com o tema;
- ii. meses depois, em **agosto de 2018**, José Seripieri informou ao CA sua **intenção de permanecer** na gestão da Companhia. Nesse contexto, o CA determinou às Consultorias a revisão de seus trabalhos para que a análise fosse feita na **perspectiva de continuidade** de José Seripieri na gestão; tendo os relatórios finais das Consultorias sido apresentados em **setembro de 2018**. A partir dessa mudança de intenção de José Seripieri se passou também a debater e negociar novos termos para o exercício do cargo de CEO;
- iii. o processo decisório foi conduzido pelo CA ao longo de meses, sem a participação ou intervenção de José Seripieri, o que foi reconhecido pela própria Acusação;
- iv. a RCA em que aprovada a celebração do Contrato teve início em 12.09.2018, foi suspensa e encerrada em dia 25.09.2018, com aprovação unânime. O Contrato foi celebrado em 28.09.2018 (sexta) e a divulgação por meio do fato relevante ocorreu em 01.10 (segunda);
- v. em 28.09.2018 também foi celebrado o Contrato de Diretor Estatutário, passando a disciplinar as condições de exercício do cargo de Diretor-Presidente por José Seripieri e valor de sua remuneração anual (R\$ 24 milhões), condicionada à aprovação pela assembleia geral a cada exercício social, tomando por base estudo realizado pela **McKinsey** em **março de 2017**.

66. Quanto ao processo decisório, esclareço, de início, que não concordo com a Acusação quando afirma que o Contrato deveria ter sido aprovado pelos acionistas da Qualicorp para que fosse, assim, evitada qualquer suspeita sobre a higidez do negócio. Tem razão os Acusados quando asseveram que a submissão da referida deliberação à assembleia de acionistas não é um procedimento exigido pela lei ou por qualquer normativo editado pela CVM.

67. Não deixo de reconhecer que, como apontado pela SEP, por se tratar de operação entre



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

partes relacionadas, espera-se que a preocupação dos administradores com a tutela do interesse da companhia seja ainda mais acentuada, impondo-se um cuidado especial que vai além da diligência e atenção exigidas em negócios realizados com terceiros.

68. E, ainda, à luz da magnitude do valor da contrapartida devida a José Seripieri (R\$ 150 milhões), entendo que as melhores práticas de governança corporativa apontavam para a submissão da matéria à assembleia geral de acionistas, após a apreciação pelo Conselho de Administração, ainda que não se tratasse de competência a essa atribuída estatutariamente.

69. Aliás, diante da repercussão negativa inicial reverberada no mercado e da acentuada queda na cotação das ações da Companhia no dia da divulgação do aviso de fato relevante sobre o Contrato³⁷, fica evidente que a própria Qualicorp passou a reconhecer que cabia aprimorar sua governança. Tanto que, em 02.10.2018, divulgou comunicado com esclarecimentos acerca do Contrato e, em 07.10.2018, publicou fato relevante, complementado em 10.10.2018, informando sobre medidas de governança corporativa a serem implementadas em transações com partes relacionadas, dentre as quais, a alteração do Estatuto justamente para prever a submissão dessas transações à aprovação da assembleia geral e a criação do Comitê de Governança Corporativa.

70. De todo modo, o fato de que a aprovação do Contrato poderia ter sido submetida à aprovação ou ratificação assemblear – e, à época, não o foi – não se presta a caracterizar qualquer infração, tendo em vista que, como dito, não havia exigência legal, regulamentar ou estatutária.

71. Isso posto, ressalto que os Conselheiros, de fato, adotaram diversos procedimentos e precauções com vistas a garantir a higidez do processo decisório. Vale mencionar, por exemplo, que restou amplamente comprovado nos autos o fato de o Contrato ter sido debatido entre os Conselheiros, sem a participação de José Seripieri, e com a presença de assessores e consultores externos em, pelo menos, 14 reuniões, ao longo de quase oito meses. Evidenciou-se que não houve açodamento, que uma série de estudos foram contratados pela Companhia e realizados por consultorias de primeira linha, especializadas na matéria, bem como que houve negociação, tendo o valor inicialmente sinalizado sido reduzido³⁸ até atingir os R\$ 150 milhões ao final contratados.

72. A SEP chegou a reconhecer elementos de cuidado na condução do processo decisório, o que levou alguns dos Acusados a argumentar que a acusação da área técnica seria, em certa

³⁷ Como apontado pela SEP, o aviso de fato relevante sobre o Contrato foi divulgado às 7h do dia 01.10.2018, assim os efeitos do Contrato puderam ser refletidos nas cotações das ações no pregão do próprio dia 01.10.2018, em que essas abriram cotadas a R\$13,49, uma queda de 18,14% em relação ao fechamento anterior e, ao fim do dia, estavam cotadas a R\$11,64, refletindo queda de 29,37% em relação ao fechamento anterior, enquanto, naquele mesmo dia, o índice Ibovespa registrou desvalorização de apenas 0,91%. Apontou o TA que, em termos de valor de mercado, a perda da Qualicorp foi de aproximadamente R\$1,370 bilhão, pela cotação de fechamento das ações.

³⁸ Segundo informações prestadas pela Companhia, a proposta inicial discutida pelos Acusados considerava “que o pacote total poderia chegar a R\$ 250/300 milhões” (Doc. SEI 0640190, p. 440).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

medida, contraditória. Não cabe, entretanto, falar em contradição, pois, além de não ter sido formulada qualquer acusação por falta de diligência (art. 153 da LSA), é possível que, por meio de procedimentos formalmente corretos, sejam praticados atos com desvio de poder ou finalidade.

73. Assim, entendo que cabe aferir não apenas os aspectos procedimentais adotados com vistas à tomada de decisão, mas também o conteúdo do que foi debatido e ponderado, o que passo a fazer, começando pela questão da aprovação da remuneração anual de José Seripieri que, como relatado, foi utilizada como parâmetro de referência para definição do valor do Contrato.

74. Quanto a este ponto, começo por esclarecer que embora as Consultorias contratadas pela Companhia tenham usado a remuneração anual do CEO para balizar a avaliação da contrapartida definida no Contrato, foram trazidos aos autos elementos que demonstram que a negociação da remuneração anual de José Seripieri ocorreu paralelamente à discussão dos termos do Contrato, tendo dado ensejo à celebração do Contrato de Diretor Estatutário. A propósito, em que pese o ponto de conexão relativo à utilização do novo patamar de remuneração como parâmetro de referência, não enxergo no Contrato, à luz do referido conjunto fático-probatório, uma tentativa de disfarçar ou mascarar remuneração adicional sob manto de indenização.

75. Restou evidenciado que o valor da remuneração de José Seripieri estava em linha com o resultado dos estudos da McKinsey, que foram finalizados em março de 2017, portanto muito antes da aprovação do Contrato, e, para tanto, os Conselheiros consideravam, entre outros fatores, o interesse da Qualicorp em incentivar a permanência de José Seripieri como seu executivo, bem como o de adequar sua remuneração como CEO à prática de mercado³⁹.

76. Segundo o relatório apresentado pela McKinsey de março de 2017, José Seripieri, como CEO, teria recebido, nos 36 meses anteriores à elaboração do referido relatório, remuneração fixa anual média de R\$ 1,2 milhões, além de outros R\$ 6 milhões por ano a título de proventos pagos em razão das ações detidas. A McKinsey destacou que o Comitê de Remuneração da Companhia propôs o aumento da remuneração total do CEO para R\$ 24 milhões (presumindo o atingimento de 100% das metas estabelecidas)⁴⁰, sendo que tal remuneração poderia chegar à marca de R\$ 45 milhões caso tais metas fossem ultrapassadas⁴¹.

77. Munido desse relatório, o CA aprovou, em 27.03.2018, proposta de remuneração dos administradores que contemplava o aumento do limite anual da remuneração *global* dos

³⁹ Com efeito, o trabalho desenvolvido pela McKinsey tinha como um dos objetivos expressos “*definir e alinhar o melhor modelo de incentivos para o Conselho de Administração e os principais executivos, de forma a reforçar a motivação, o valor agregado e a retenção*” (Doc. SEI 0640190, pp. 87 e 89).

⁴⁰ A remuneração anual “base” seria dividida da seguinte forma: (i) R\$ 6 milhões de remuneração fixa; (ii) R\$ 6 milhões em proventos pagos em razão das ações detidas; e (iii) R\$ 12 milhões em remuneração variável.

⁴¹ Doc. SEI 0640190, p. 164.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

administradores da Companhia para até R\$ 28.548.436,52. Tal proposta foi aprovada pela maioria dos acionistas presentes (representantes de cerca de 46,9% do capital social total) na AGO realizada em 27.04.2018⁴².

78. Como apontaram os Conselheiros, “a proposta da administração para remuneração de administradores submetida para a AGO contemplou um valor de remuneração base para CEO de até R\$ 17 milhões”⁴³ e, em 2018, o próprio José Seripieri optou por abdicar de parte da sua remuneração variável em razão da incerteza de sua permanência na Companhia⁴⁴⁻⁴⁵.

79. Em 28.09.2018, mesma data em que foi celebrado o Contrato, a Companhia e José Seripieri também assinaram o Contrato de Diretor Estatutário, em que se estabeleceu que sua remuneração como diretor obedeceria a proposta apresentada pelo Comitê de Remuneração e que, para o exercício de 2018, tal remuneração seria ajustada para respeitar o “limite de remuneração da administração aprovado pela AGO de 2018”⁴⁶. Posteriormente, em 29.04.2019, a assembleia de acionistas da Qualicorp aprovou, por maioria dos votos dos presentes, o limite máximo de remuneração de R\$ 42.765.808,00.

80. A propósito, cabe abordar o argumento da SEP de que existem certas inconsistências entre o asseverado pelos Conselheiros e pela McKinsey. A primeira é que a McKinsey, ao contrário do que afirmam os Conselheiros, diz não ter sugerido qualquer cifra para a fixação da remuneração global de José Seripieri⁴⁷. Pelo contrário, apontou, em seu relatório, que tal cifra teria sido indicada por alguns dos Conselheiros e que se encontrava acima da média de mercado. A origem da cifra inicial, de todo modo, não me parece ser, em si, um forte indício de que os Conselheiros pretendiam beneficiar José Seripieri, à luz dos estudos que foram posteriormente realizados.

81. O segundo ponto que chamou a atenção da área técnica foi a diferença entre a remuneração aprovada para José Seripieri e a remuneração média de profissionais que ocupam o

⁴² Doc. SEI 0640190, p. 348.

⁴³ Doc. SEI 0640190, p. 445.

⁴⁴ Nesse sentido, a ata da RCA de 14.03.2018 (Doc. SEI 0762236) aponta que “[o] conselheiro José Seripieri Filho, atual CEO e Fundador da Companhia, solicitou formalmente a manutenção de sua remuneração no formato e valores anteriores, sem considerar qualquer alteração da sua remuneração atual”.

⁴⁵ Constaram dos fatos relevantes divulgados pela Qualicorp, respectivamente, nos dias 7 e 10.10.2018, informações acerca do recebimento de comunicação de José Seripieri por meio da qual ele renunciou à totalidade da remuneração variável a que teria direito como CEO para o exercício de 2018, no valor máximo de R\$ 7,2 milhões, e assumiu a obrigação de investir na Companhia o valor recebido a título de indenização no âmbito do Contrato (Doc. SEI 0640190, pp. 19-20 e doc. SEI 0640190, pp. 26-28).

⁴⁶ Doc. SEI 0640190, p. 59.

⁴⁷ A McKinsey ressaltou, contudo, que “não participou de qualquer indicação e percentuais de gastos com remuneração e patamares de remuneração individual os quais foram realizados e/ou apresentados pelo Comitê de Remuneração da Qualicorp”, composto à época por Raul Rosenthal, Cláudio Bahbout, Wilson Olivieri e R.M.S. (Doc. SEI 0640190, pp. 87 e 89).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mesmo cargo em companhias que atuam no mesmo setor⁴⁸. A esse respeito, entretanto, considero consistentes com os fatos, as alegações dos Conselheiros no sentido de que a decisão quanto ao valor da remuneração do CEO da Companhia (i) levou em conta a *expertise* e a importância estratégica de José Seripieri para a Qualicorp, o que era mesmo notório para o mercado, e (ii) espelhava uma tentativa de equiparar a remuneração do então CEO àquela que já havia sido paga, em anos passados, a ex-diretores da Qualicorp⁴⁹, ainda que não constantemente.

82. Não vislumbro, portanto, indícios robustos e suficientes que pudessem levar à conclusão de que a remuneração anual de José Seripieri teria sido definida de forma a propiciar o incremento do valor a ser pago pela Companhia no âmbito do Contrato. Pelo contrário, os documentos apresentados nos autos demonstram que a definição do montante da remuneração levou em conta a importância de José Seripieri enquanto CEO da Companhia e o interesse em tentar retê-lo em tal qualidade, estando, ainda, compatível com valores pagos a ex-CEOs da Qualicorp⁵⁰⁻⁵¹.

83. Superada essa questão, passo a analisar o contexto em que se deu o processo de negociação e aprovação do Contrato.

84. Como visto, em março de 2018, o CA foi informado por José Seripieri sobre sua intenção de deixar a administração da Qualicorp. Em razão do papel exercido por José Seripieri na condução dos negócios da Qualicorp e na esteira da “saída de outros executivos-chave”⁵², foram então

⁴⁸ Segundo a McKinsey a remuneração total *média* de CEOs de companhias comparáveis à Qualicorp variava entre R\$ 3,6 milhões e R\$ 7,1 milhões, enquanto a remuneração *média* dos CEOs que trabalham para as companhias que oferecem as maiores remunerações no mercado chegava a R\$ 15 milhões por ano (Doc. SEI 0640190, p. 119).

⁴⁹ Sobre o argumento de que os Conselheiros apenas repetiram a remuneração do antigo Diretor-Presidente, destaco o seguinte trecho de voto lançado pelo ex-Diretor Pablo Renteria: “Ora, essa alegação não me parece aceitável. Se, como alegado, a remuneração do presidente do Conselho de Administração da Companhia já vinha sendo fixada ao arrepio da lei, competia, então, aos membros do Conselho presentes na reunião realizada em 6.1.2009 corrigir de uma vez por todas tal irregularidade e definir corretamente a remuneração da acusada (...), tomando por base o disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/76. Tendo em vista os deveres fiduciários que os vinculavam à Companhia, não vejo como poderiam ter consentido com a perpetuação de uma prática ilegal.” PAS CVM nº RJ2011/5211, j. em 01.07.2015. No caso de inadequação de remunerações anteriores não se pode admitir que o balizamento no referido parâmetro corrigisse irregularidades. Note-se, porém, que a acusação feita neste PAS em relação ao art. 152, *caput*, é diferente, tendo por fundamento não o valor da remuneração do CEO, mas sim da extrapolação do limite global aprovado em AGO, considerando o valor da contrapartida pelo non-compete e demais obrigações objeto do Contrato

⁵⁰ A McKinsey também apontou o histórico discrepante entre os proventos dos CEOs anteriores da Qualicorp: embora a média da remuneração fixa tenha variado entre R\$ 2 e R\$ 4 milhões anuais, a remuneração global anual (incluindo, portanto, a remuneração variável) fora de R\$ 1,6 milhões em 2010 e chegou a atingir a cifra de R\$ 29 milhões em 2014 (Doc. SEI 0640190, p. 162), sendo que outras pessoas (que não José Seripieri) ocupavam o cargo em tais anos.

⁵¹ Ainda, consoante o item 13.11 dos Formulários de Referência da Companhia, os valores das maiores remunerações da diretoria estatutária nos anos de 2015 e 2016 (que, naqueles anos, eram referentes à remuneração global anual de M.C, diretor presidente da Qualicorp à época) superavam, respectivamente, R\$ 27 milhões e R\$ 21 milhões.

⁵² Doc. SEI 0640190, p. 33. O próprio José Seripieri explicou, em esclarecimentos prestados durante as investigações, que “[p]reocupações dessa natureza ficaram ainda mais acentuadas com a saída do antigo diretor comercial da Qualicorp, [LG], que comunicou em junho de 2018 que decidiu pelo seu desligamento da Companhia. Tal movimento representou saída de executivo importante, ainda que não estatutário, para a condução dos negócios da Companhia, e que não havia assumido, e não assumiu no momento em que ele pediu o seu desligamento, qualquer obrigação de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

contratadas as mencionadas Consultorias para que avaliassem o “*risco de desalinhamento*” entre a Qualicorp e seu Diretor-Presidente, e para que fosse feito um estudo “*sobre remuneração e retenção de CEO*” que viria a ser usado como base “*para discutir proposta de indenização por não competição em um cenário que contemplava a saída de José Seripieri*”⁵³. Em agosto de 2018, porém, José Seripieri informou ao CA que estaria disposto a permanecer e a “*assumir significativas obrigações destinadas a reforçar esse compromisso*”⁵⁴.

85. Não obstante José Seripieri tivesse mudado de ideia, naquela oportunidade, sobre a sua permanência na administração da Companhia, restava evidente, inclusive pelos resultados dos trabalhos das Consultorias conduzidos até então, a importância para a Companhia de estar resguardada dos riscos que o Contrato almejava tratar⁵⁵, para que, independentemente da permanência ou não do CEO, esse não pudesse surpreendê-la como concorrente.

86. Como descrito no relatório preparado pela Spencer Stuart, a análise passou a ser focada no potencial “*risco de perda do executivo*” e na preparação de “*uma proposta de retenção, non-compete, non-solicitation e motivação*”, partindo da premissa “*de que não existe (...) qualquer tipo de cláusula de non-compete*”⁵⁶, não tendo sido feita qualquer referência à legislação. Em sua conclusão, a Spencer Stuart destacou que sua “*recomendação inicial seria reter e motivar* [José Seripieri] (...) Caso não seja viável fazê-lo, a sua eventual saída deveria ser feita de forma organizada. Em qualquer dos casos, deveriam ser tratadas questões como non-compete, non-solicitation, parcerias possíveis (...) *Dos and Don'ts da relação renovada*”⁵⁷ (grifos adotados).

87. Já a Mercer preparou seu relatório assumindo que José Seripieri “*não possuía, em seu contrato de trabalho, uma proteção específica para a situação de ‘não competição’*” (grifei), e que a aplicação de tal obrigação teria o potencial de prevenir “*perdas substanciais*” caso José Seripieri optasse por atuar em “*funções não contempladas junto aos objetivos da Qualicorp*”, também não tendo sido feita qualquer referência a deveres ou obrigações legais.

88. Para a Mercer, “*considerando os riscos levantados pelo jurídico pela ausência de uma proteção específica de não competição* (...)” (grifei), seria recomendável a adoção de um

não competição (...)” (Doc. SEI 0640190, p. 451.)

⁵³ Doc. SEI 0640190, p. 33.

⁵⁴ Doc. SEI 0640190, pp. 33, 449 e 450.

⁵⁵ Note, quanto a essa afirmação, que, de acordo com o informado pelos Acusados durante o processo de investigação, a avaliação feita pelas Consultorias em 15.05.2018 (portanto antes de José Seripieri anunciar sua intenção de permanecer à frente da Qualicorp) era de que a contrapartida para um contrato de *non-compete* com vigência de 5 anos “*poderia chegar a R\$250/300 milhões*” (grifei). Na reunião de 22.08.2018, a Mercer considerou o pagamento de “*R\$300 milhões, composto por ações e dinheiro, em 3 anos, além da remuneração de executivo, tendo como contrapartida permanência de 6 anos*” (Doc. SEI 0640190, pp. 439 - 440) (grifos adotados).

⁵⁶ Doc. SEI 0640190, p. 68.

⁵⁷ Doc. SEI 0640190, p. 71.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

programa de não-competição que obedecesse às características e melhores práticas de mercado listadas em seu relatório, dentre as quais (i) o pagamento do equivalente à compensação total anual do Acusado para cada ano em que vigorar a obrigação de não competição; (ii) a vigência da obrigação de não competição pelo prazo seis anos; (iii) a fixação de multas em caso de não cumprimento da obrigação de não competição; e (iv) o bloqueio de ações de propriedade de José Seripieri (Lock-Up) em “garantia” ao pagamento da multa supracitada⁵⁸.

89. Vê-se que tanto a Spencer Stuart quanto a Mercer destacaram o “elevado risco” relacionado à saída de José Seripieri da administração da Companhia, risco esse que, até então, estava inteiramente descoberto, visto que nada impedia que ele, a qualquer momento, deixasse a Companhia para passar a concorrer com os negócios da Qualicorp. Em especial, cabe reconhecer que, além de ser seu principal executivo, José Seripieri fora o responsável pela criação da empresa, décadas antes, em moldes muito inovadores no respectivo mercado de atuação, e era reconhecido por sua estratégica rede de relacionamentos e extraordinária capacidade empreendedora. A necessidade de proteger a Companhia, nesse cenário, se tornara, aliás, ainda mais premente uma vez que José Seripieri já havia anteriormente sinalizado a sua intenção de deixar a Qualicorp e que outro diretor recém-saído (em julho/2018) se recusara a celebrar acordo de *non compete*.

90. Parece-me, portanto, legítima a preocupação dos Conselheiros de buscar, o quanto antes, e independentemente de José Seripieri ter concordado em continuar na administração, eliminar a possibilidade de tê-lo como concorrente. Assim, mesmo considerando a referida sobreposição parcial de obrigações contratuais e legais, que poderia perdurar ou não, a depender de se concretizar ou não o cenário de saída, não entendo que o objetivo dos Conselheiros ao aprovarem a celebração do Contrato foi o de garantir a José Seripieri um pagamento que “*se sobrepõe à remuneração recebida diretamente em razão do exercício do cargo*”, como se estivesse sendo duplamente remunerado como administrador, como entendeu a Acusação, mas sim o de proteger interesses legítimos da Qualicorp nas circunstâncias que à época se apresentavam e diante da sucessão de eventos que culminaram com a celebração do Contrato em 28.09.2018.

91. A meu juízo, a análise do contido nos relatórios preparados pelas Consultorias corrobora os argumentos das Defesas de que (i) a assinatura do Contrato era necessária para proteger a Companhia contra o risco de José Seripieri decidir competir com os negócios da Qualicorp, o que poderia resultar em grandes prejuízos para a Companhia, considerando a relevância desse acusado no setor de atuação da Companhia e a sua proximidade com muitos dos então clientes; e (ii) que as condições do Contrato espelhavam lógica de mercado, como respaldado pelas Consultorias.

92. Ambos os relatórios das Consultorias também deixam claro que as conclusões

⁵⁸ Doc. SEI 0640190, pp. 78 a 84.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apresentadas pressupunham a inexistência de *cláusulas* com obrigações *específicas* de não-concorrência assumidas contratualmente por José Seripieri, conforme informado pelo setor jurídico da Companhia. Não há menção a que as Consultorias tenham feito uma análise sobre a possível sobreposição entre certas obrigações propostas para o Contrato e deveres fiduciários dos administradores ou vedações legais⁵⁹, o que parece configurar, no mínimo, uma incompletude de análise. De todo modo, entendo que isso não chega a retirar a robustez dos estudos em relação ao efetivo problema que se apresentava para a Companhia e que, com efeito, apontava para a necessidade de assegurar, desde então, proteção contratualmente estabelecida, pois não restaria resolvido por força das limitações das referidas disposições legais já abordadas.

93. Cabe repisar que este PAS não trata de eventual falha de diligência que pudesse ter levado a incompletude de informações necessárias para a tomada de decisão pelos Conselheiros, e sim de imputação mais grave, quanto à suposta atuação intencionalmente lesiva ao interesse social.

94. Além disso, como também apontado, o padrão de revisão da conduta dos Conselheiros neste PAS não implica em avaliação invasiva quanto aos termos ideais de contratação, mas em análise de mérito que busque aferir se houve ou não atuação com desvio de poder ou finalidade.

A independência dos Conselheiros e os objetivos do Contrato

95. Considerando todos os aspectos detalhados acima, resta examinar os fundamentos da Acusação quanto ao elemento subjetivo da alegada infração. Para a SEP, os Conselheiros não eram desinteressados na medida em que não se encontravam em “posição imparcial”, uma vez que a aprovação do Contrato beneficiaria singularmente José Seripieri.

96. Contudo, a Acusação não apontou qualquer interesse pessoal dos Conselheiros ou mesmo indícios de que José Seripieri teria exercido influência sobre eles ou que teriam sido instruídos ou motivados a agir para atender a interesse outro que não o da Qualicorp. De certo modo, a lógica foi invertida: a SEP buscou provar que as condições do Contrato não eram equitativas para disso extrair que a decisão foi tomada para beneficiar José Seripieri, em detrimento da Companhia, e, ao amparo do entendimento de que seria aplicável o teste de *entire fairness*, reputou ser ônus das Defesas comprovar que os Conselheiros teriam atuado de maneira desinteressada.

97. Como explanado, entretanto, entendo que não cabe adotar neste caso o teste de *entire fairness* (e, mesmo que fosse adotado, a sobreposição parcial de certas obrigações contratuais e legais não seria elemento suficiente para concluir que houve desvio de finalidade). Assim, a meu ver, cabia à Acusação comprovar que a finalidade almejada pelos Conselheiros, ao aprovar o

⁵⁹ Como visto, tal análise acabou sendo feita pelo Dr. Paulo Cezar Aragão após a celebração do Contrato (em Parecer datado de 22.11.2018), pouco antes de ter sido finalizado o TA inicial (de 26.11.2018).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Contrato nos termos pactuados, era a de beneficiar o CEO e ex-controlador da Companhia.

98. A propósito, observo que a prova direta da intenção dos Acusados, como já reconhecido por este Colegiado, é considerada “diabólica”, e, por isso, se admite que a Acusação faça uso de provas indiciárias, desde que “*múltipl[a]s, veementes, convergentes e graves, que autoriz[em] uma conclusão robusta e fundada acerca do fato que se quer provado*”⁶⁰. Não foram, porém, assim apresentadas neste caso.

99. Em que pese José Seripieri tenha sido o fundador da Qualicorp e, em período que antecede aos fatos objeto deste PAS, tenha sido seu acionista controlador, já em 2017, portanto, antes do início das tratativas relativas ao Contrato, a Companhia contava com base acionária pulverizada e inexistência de controlador definido⁶¹.

100. Noto, ainda, que ao tempo da deliberação de que trata este PAS, alguns dos Conselheiros se enquadravam na definição de “conselheiros independentes”⁶² e mesmo os que não ostentavam tal enquadramento não tinham sido eleitos por José Seripieri (o que, inclusive, motivou a alteração de capitulação consoante proposta da PFE, como relatado).

101. Embora alguns dos acusados também tivessem sido eleitos para o CA da Companhia em anos anteriores, com o voto do ex-controlador, tal período precede os fatos apurados neste PAS e nem mesmo a Acusação se debruça sobre tais informações para amparar a tese acusatória.

102. Ainda que não me convença o argumento apresentado por alguns dos Conselheiros de que pelo fato de se enquadrarem, à época, na definição de “conselheiros independentes” estariam necessariamente livres de qualquer influência ou parcialidade para deliberar qualquer matéria em relação a José Seripieri, entendo que tais circunstâncias, se presentes, seriam matéria de prova, e que era ônus da Acusação demonstrá-las a fim de amparar a alegação de que teriam agido com intenção e finalidade de lesar a Companhia.

103. Ademais, por todo o decorrido nas subseções anteriores, dadas as especificidades deste

⁶⁰ PAS CVM 22/94, j. em 15.04.2004, Dir. Relator Luiz Antonio de Sampaio Campos. No mesmo sentido e quanto ao uso de provas indiciárias em processos que envolvem alegado descumprimento ao art. 154, o voto do ex-Diretor Gustavo Gonzalez, no já citado PAS CVM RJ2013/11730.

⁶¹ v. Item 12.5/6 do Formulário de Referência da Companhia do ano de 2017.

⁶² Nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado: Art. 16 O enquadramento do conselheiro independente deve considerar sua relação: I - com a companhia, seu acionista controlador direto ou indireto e seus administradores; e II - com as sociedades controladas, coligadas ou sob controle comum. §1º Para os fins da verificação do enquadramento do conselheiro independente, não é considerado conselheiro independente aquele que: I - é acionista controlador direto ou indireto da companhia; II - tem seu exercício de voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à companhia; III - é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do acionista controlador, de administrador da companhia ou de administrador do acionista controlador; e IV - foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da companhia ou do seu acionista controlador.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

caso, estou convencida de que a conduta dos Conselheiros foi norteada pela intenção de proteger a Companhia contra riscos efetivamente existentes de possível concorrência com os negócios da Qualicorp, notadamente em cenário de súbita saída “desordenada” de José Seripieri, que poderia ocorrer independentemente de ter sido também celebrado o Contrato de Diretor Estatutário, uma vez que não havia qualquer obrigação de José Seripieri de permanecer na gestão da Companhia.

104. Pelo exposto, entendo que não restaram comprovados os elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração do ilícito, não cabendo responsabilizar os Conselheiros por infração ao art. 154, *caput*, da LSA, em razão de terem aprovado o Contrato nas condições pactuadas.

III.2. Celebração do Contrato em alegada infração ao art. 156, *caput*.

105. Essa acusação constitui, por assim dizer, o “outro lado da moeda” no que tange à celebração do Contrato e, por isso, aproveito aqui tudo o quanto já abordado em relação aos fatos e as circunstâncias subjacentes no que tange à negociação e ao processo decisório da Companhia de que resultou a aprovação do Contrato. Não mais se trata, porém, de acusação de desvio de poder ou finalidade, mas de celebração do Contrato em condições reputadas como não equitativas.

106. A Acusação imputou a José Seripieri violação ao disposto no art. 156, §1º⁶³, da LSA. Segundo a SEP, o processo decisório que resultou na aprovação do Contrato foi falho e o conteúdo do instrumento, “objetivamente considerado, é repleto de elementos que convergem rumo à conclusão de ter se tratado de uma transação lesiva à Qualicorp”.

107. Aduziu a SEP que cabia ao acusado, como “[u]m administrador que toma conhecimento de uma transação lesiva à companhia”, não apenas *abster-se* de votar na deliberação, como o fez (e como exigido pelo *caput* do art. 156), mas também *abster-se* de ter “firmado com a Qualicorp o Contrato, que lhe assegura benefícios financeiros não equitativos”.

108. Em sua Defesa, José Seripieri sustentou que, na verdade, as condições do Contrato teriam sido definidas de acordo com métricas e modelo compatíveis com o praticado pelo mercado, não havendo de se falar, portanto, em condições não equitativas. Além disso, ao amparo de parecer preparado pelo Professor José Alexandre Tavares Guerreiro, apontou que contratos *personalíssimos* como o de não-competição, por criarem relações *singulares*, são *incomparáveis*. Nesse sentido, não haveria que se falar em condições *idênticas* às que prevalecem no mercado ou

⁶³ Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de RCA ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

§ 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. (grifos aditados)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

em que a companhia contrataria um outro contrato de não-competição com terceiro. Quanto ao procedimento, o acusado apresentou argumentos similares àqueles lançados pelos Conselheiros.

109. A propósito, cumpre ressaltar que o art. 156 da LSA dispõe sobre tratamento específico para as contratações entre a companhia e seus administradores. Com efeito, além de impedir que o administrador conflitado intervenha nos atos relativos à operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, o artigo determina que o negócio celebrado pela companhia com administrador conflitado o seja em condições razoáveis ou equitativas.

110. O legislador criou, assim, uma dupla filtragem para as transações celebradas com administradores⁶⁴, antevendo que, nessas circunstâncias, a independência do gestor pode ser, em boa medida, prejudicada, tornando-se natural que possa ter seus interesses desalinhados com os da companhia. De um lado, o negócio deve ser submetido a um processo bem estruturado e sem a influência das partes interessadas e, de outro, deve necessariamente ser firmado em condições razoáveis ou equitativas, em linha com as de mercado ou que prevaleceriam com terceiros.

111. A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do parecer do Professor José Alexandre Tavares Guerreiro, acostado aos autos, acerca da avaliação pelo julgador quanto a se um contrato foi firmado em condições equitativas ou não:

(...) qual é o valor do Contrato para a Companhia? Como verificar se, de fato, prestação e contraprestação são razoáveis e equitativas?

Pode-se analisar a contratação entre [José Seripieri] e Companhia **sob duas perspectivas**, a fim de identificar se há elementos de convencimento de que os parâmetros legais foram atendidos. (...).

Sob o ponto de vista negocial é possível avaliar **como ocorreu a tomada de decisão na Companhia e negociação do Contrato** (como o Contrato foi proposto, estruturado, como sua aprovação foi deliberada e divulgada). (...)

Ao passo que sob o ponto de vista material (art. 156, §1º, Lei das S/A) **pode-se analisar determinados elementos fáticos e jurídicos que revelam a valoração dada pela Companhia ao Contrato, de modo a confirmar a existência de elementos de convencimento quanto à razoabilidade e equidade da prestação e contraprestação do Contrato** (relação entre prestação e contraprestação, critério de precificação, benefícios econômicos envolvidos). (grifos adotados)

112. O fato de o administrador não participar da deliberação de aprovação de negócio a ser celebrado com a companhia, por si só, não faria com que esse deixasse de se caracterizar como lesivo ao interesse social⁶⁵, se assim o fosse. Caberia, ainda, ao administrador balizar-se por

⁶⁴ Veja-se o PAS CVM nº RJ2011/14269, Rel. Dir. Ana Dolores Carneiro de Novaes, j. em 26.03.2013.

⁶⁵ “Alterando o quadro, o art. 156 da lei atual fez incluir, em seu § 1º, regra estabelecendo (ou esclarecendo) a obrigação de equitatividade mesmo que o administrador se abstenha de votar (como deve, na forma do caput) e, coerentemente, inquinando de anulável o contrato celebrado com infração dessa regra do § 1º. Assim, será (e somente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

elementos aptos a confirmar sua razoabilidade e equidade. Como pontuou o ex-Diretor Gustavo Gonzalez, no PAS CVM nº RJ2017/5122, “[a]o exigir que tais transações sejam equitativas, a lei impõe aos administradores uma verdadeira obrigação de resultado”. Cabe, portanto, análise de mérito quanto à configuração, ou não, de tais elementos.

113. Quanto aos aspectos procedimentais (ou “negociais”, como definiu o Professor Tavares Guerreiro), entendo, pelos fundamentos já apresentados na Seção anterior, que não restou demonstrada irregularidade na conduta do acusado, não apenas porque ele não participou de nenhuma das reuniões do CA em que foram discutidos pela Companhia os termos do Contrato, mas, notadamente, em razão de não ter restado evidenciado que o processo decisório conduzido em relação à aprovação do Contrato pelo CA da Qualicorp se deu sob influência de José Seripieri ou para beneficiá-lo, em detrimento do interesse social.

114. A meu juízo, a robustez do processo de negociação e decisão pelos Conselheiros reverbera a favor de José Seripieri, à luz das negociações entre as partes e dos trâmites adotados pelo CA, em seu processo decisório, que evidenciaram que o valor da indenização não foi imposto por José Seripieri, e sim negociado e balizado por parâmetros compatíveis com os de mercado, amplamente discutidos com consultores externos especializados.

115. Nesse sentido, tem-se que o valor pactuado resultou de longo e debatido processo, o qual, como dito, não apontou para circunstâncias que almejassem o favorecimento de José Seripieri.

116. Em relação aos aspectos materiais apontados pela SEP, faço referência às considerações já tecidas em relação à amplitude das obrigações contratuais assumidas por José Seripieri, nos termos em que pactuadas, além de acrescentar as seguintes considerações sobre a referida sobreposição parcial com obrigações legais a que o acusado estava sujeito enquanto administrador.

117. A cronologia dos fatos que culminaram na celebração do Contrato e as circunstâncias subjacentes evidenciaram, a meu ver, que, em um primeiro momento, a Companhia avaliava oferecer a José Seripieri um pacote de remuneração que lhe incentivasse a permanecer à frente da Companhia. Nesse intuito, havia sido contratado o estudo da McKinsey que ajudou a balizar a decisão da Qualicorp quanto à definição da remuneração de seus executivos. Após cientificados de que José Seripieri pretendia deixar a administração da Qualicorp, as preocupações se voltaram

será) anulável o contrato quando celebrado com lesão aos interesses da companhia, quer o administrador vote, quer não. Dir-se-á — e na verdade é o que basicamente diz boa parte da doutrina pátria — que este fato comprova que o administrador pode votar. A meu sentir, a conclusão é excessiva. O que a Lei fez, e muito bem, foi eliminar a errônea impressão de que a abstenção do administrador legitimaria a deliberação, ainda que por esta se aprovasse celebrar contrato lesivo. Deixou a lei claro que o que motiva a anulação é a lesão aos interesses da companhia, quer o administrador impedido participe, quer não.” (PAS CVM nº RJ2004/5494, voto do Presidente Marcelo Trindade, j. em 14.12.2004).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

à necessidade de assegurar uma saída ordenada, para que a Companhia não se visse subitamente diante de um novo concorrente de peso, de modo que o Contrato foi, inicialmente, pensado *sem* contemplar um lapso temporal de vigência das obrigações contratuais no qual José Seripieri ainda atuaria na administração da Qualicorp.

118. Em agosto de 2018, após a mudança de intenção de saída do CEO, os termos e condições pertinentes à sua continuidade na gestão da Companhia passaram, novamente, a ser debatidos para constar no outro contrato, que regeria sua remuneração enquanto diretor estatutário da Qualicorp. Os planos de preparar a Companhia para potencial saída do CEO, contudo, não foram interrompidos, pelo contrário, cientes de que o maior risco para a Companhia estava relacionado a tal saída desordenada, os Conselheiros passaram a negociar o Contrato partindo da premissa de que, independentemente de permanecer como CEO, José Seripieri poderia, a qualquer tempo, voltar a decidir sair da gestão da Qualicorp.

119. Embora isso ajude a entender a estrutura contratual adotada e a ausência de segregação de etapas no Contrato, isso não soluciona a dúvida, que remanesce, quanto a se o valor da contrapartida prevista no Contrato teria sido mantido exatamente o mesmo (i.e. R\$ 150 milhões), caso tivesse sido de algum modo eliminada (ou ao menos explicitada e segregada no Contrato), ainda que com eficácia modulada, a sobreposição parcial existente entre algumas das obrigações contratuais e certas obrigações legais pertinentes ao exercício do cargo de administrador.

120. Esse, aliás, é o ponto central da controvérsia no que tange à alegação de que o Contrato não teria sido celebrado em condições equitativas, em benefício de José Seripieri.

121. Entretanto, no meu entender, pelas razões apontadas na Seção anterior, os elementos trazidos pela Acusação não foram suficientes para demonstrar que o Contrato, por contemplar, em alguma medida, tal sobreposição, previa contrapartida financeira em condições não equitativas.

122. Enquanto a lógica da Acusação focou-se no fato de que, pelo período em que o acusado viesse a permanecer na administração da Companhia, parte das obrigações contratuais não deveria ser passível de qualquer indenização, o racional que ampara as Defesas está centrado na possível materialização do risco de saída a qualquer tempo, ao longo da vigência do Contrato, uma vez que não havia como submetê-lo a obrigação de permanecer na gestão da Qualicorp, mas apenas de tentar incentivá-lo a ficar por meio do Contrato de Diretor Estatutário.

123. E, de fato, caso não tivesse sido celebrado o Contrato, os impedimentos decorrentes do dever de lealdade e vedações legais já referidas cessariam pela renúncia aos cargos de Diretor-Presidente e conselheiro de administração, sem trazer qualquer limitação à atuação de José Seripieri após sua eventual saída. De outro lado, uma vez celebrado, a eficácia das obrigações



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pactuadas perduraria até o término do Contrato, independentemente de qualquer decisão que ele viesse a tomar no sentido de deixar a administração da Companhia.

124. Ao contestar a caracterização das condições como equitativas, a Acusação não só considerou, equivocadamente, que a única obrigação contratual “inédita” era o Lock-up, como não levou em consideração que o Contrato não poderia impedir nem limitar a liberdade de José Seripieri de decidir deixar a Companhia, a qualquer tempo, dali em diante. Porém, uma das funções primordiais do Contrato era vedar a possibilidade de concorrência, com a máxima amplitude, independentemente de qualquer decisão que José Seripieri viesse a tomar após a celebração do pacto de *non-compet*e com a Companhia, e o valor indiviso da contrapartida era também um reflexo disso, dada a impossibilidade de prever se e quando ele viria a deixar a Companhia.

125. Ressalto que o Contrato não segregou valores em relação a tais ou quais obrigações, tratando a contrapartida devida pela Qualicorp no âmbito do Contrato como um todo indivisível. Tampouco o fez a Acusação quando colocou em xeque o valor total pago a José Seripieri em razão do Contrato, dirigindo suas críticas ao parâmetro utilizado para determinar o montante total (de R\$ 150 milhões), bem como ao valor específico da remuneração contratada pelo exercício do cargo executivo (de R\$ 24 milhões).

126. Observo que, diante de todo o contexto de repactuação da remuneração de CEO e de negociação de contrapartida pelas obrigações de *non-compet*e e as demais previstas no Contrato, não há qualquer clareza de que, expurgada tal sobreposição parcial, o valor pactuado teria sido diferente, ainda que tampouco haja comprovação efetiva de que tal valor permaneceria inalterado.

127. De todo modo, embora os Acusados não tenham demonstrado que a sobreposição parcial teria sido expressamente considerada (ou ao menos questionada) pelo CA ao longo do processo de negociação e definição do preço do Contrato⁶⁶, o conjunto fático-probatório, a meu juízo, evidencia que preponderava a avaliação e negociação de contrapartida necessária para assegurar a “saída ordenada”, caso essa viesse a se materializar⁶⁷.

128. Nesse sentido, a contrapartida do Contrato foi negociada para proteger a Companhia de modo muito mais amplo, tanto temporalmente quanto objetivamente, do que lhe seria assegurado por lei, inclusive porque o intangível gerado para a Companhia com a celebração do Contrato estava notoriamente associado ao fato de que José Seripieri havia sido o fundador da Companhia,

⁶⁶ Esse aspecto estaria associado à questão do devido cumprimento do dever de diligência dos Conselheiros no processo decisório relativo à aprovação do Contrato, mas não chegou a ser especificamente apontado neste PAS, tendo em vista o entendimento da Acusação de que houve intencional desvio de finalidade.

⁶⁷ Cabe considerar que os Conselheiros avaliavam que a perda para a Qualicorp, em caso de saída de José Seripieri, sem obrigação contratual de não competição e com falta de alinhamento de longo prazo em razão de possível venda das ações de emissão da Companhia por ele detidas, seria muito superior ao valor da indenização paga a José Seripieri.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

concebendo modelo de negócios inovador, fora ex-controlador, ainda era titular de participação indireta relevante⁶⁸ e não apenas conhecia o negócio como ninguém, como tinha ampla rede de relacionamentos e forte vínculo e influência sob clientes, fornecedores e outros *stakeholders*.

129. Ainda sobre o valor atribuído ao Contrato, além do já abordado na Seção anterior, cabe repisar que a SEP reputou que esse não poderia tomar como parâmetro de referência a remuneração anual pactuada para o exercício do cargo de CEO (R\$ 24 milhões), aduzindo que, caso ele não se desligasse da administração da Qualicorp, a Companhia estaria lhe remunerando em dobro, e, se ele saísse, a Companhia teria de contratar outro CEO presumidamente pelo mesmo valor. Alegou, também, como dito, que o próprio valor da remuneração anual seria inadequado na medida em que entendeu haver evidências objetivas de que seria excessivo⁶⁹.

130. A argumentação falha, a meu ver, ao não dissociar (i) a indenização no âmbito do Contrato (em contrapartida às obrigações de não fazer) da (ii) remuneração prevista no Contrato de Diretor Estatutário (pela atuação como CEO). Como dito, o Contrato e o Contrato de Diretor Estatutário tratam de obrigações distintas, sendo o primeiro destinado a restringir a atuação de José Seripieri, independente da sua condição de administrador ou acionista, para que não pudesse, em nenhuma medida e independentemente de qualquer outra decisão que viesse a tomar, competir com os negócios da Qualicorp, enquanto o segundo trata da sua remuneração por serviços prestados enquanto CEO, portanto, não havendo que se falar em pagamento em dobro.

131. Da mesma forma, não cabe correlacionar o montante da indenização paga a José Seripieri em razão do Contrato com o que, no futuro, a Companhia teria de dispendar para remunerar um novo CEO, uma vez que o pagamento no âmbito do Contrato não correspondia a contraprestação devida em função de sua atuação como Diretor-Presidente da Companhia.

132. Como já detalhado, quanto ao valor da remuneração de CEO, foram trazidos aos autos elementos que fundamentaram a decisão do CA, pelos estudos e relatórios externos, não tendo tal decisão (i.e. de fixá-la em R\$ 24 milhões/ano) sido objeto de acusação por qualquer irregularidade, bem como tais documentos evidenciaram que sua utilização como referência para balizar a contrapartida do *non-compete* não destoava do praticado pelo mercado em outras operações.

133. Por fim, cabe reconhecer que a indenização também abarcava a obrigação de Lock-up,

⁶⁸ Noto que, de modo consistente, o Contrato se refere a José Seripieri como “Acionista”, ainda que as obrigações tenham sido assumidas a qualquer título, e independentemente de ser ou não também mantido cargo na administração.

⁶⁹ Segundo a SEP, embora o valor da maior remuneração paga pela Qualicorp a membro de sua diretoria nos exercícios de 2015 e 2016 estivesse próximo do referido patamar, isso não teria ocorrido nos exercícios de 2017 (em que o valor da maior remuneração foi de aproximadamente R\$ 8 milhões) e de 2018 (em que os acionistas da Companhia aprovaram uma remuneração global de cerca de R\$28,5 milhões, para todos os sete conselheiros e três diretores).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

objetivando assegurar o alinhamento de interesses com a Companhia a longo prazo⁷⁰, bem como podendo vir a servir de lastro patrimonial em caso de cobrança de eventual multa no âmbito do Contrato, se e quando José Seripieri viesse a descumprir as obrigações contratadas.

134. A propósito, a SEP sugere que o Lock-up assumido não justificaria o preço pago, em qualquer medida, ressaltando que “o valor marginal, para a Qualicorp, da obrigação de José Seripieri não alienar suas ações (...) é muito reduzido, se é que existe”. Entretanto, como visto, a obrigação de Lock-up não era a única obrigação contratual “inédita”, evidenciando-se equívoco nessa premissa adotada pela Acusação.

135. Ademais, fatos subsequentes acabaram por colocar em xeque o entendimento da SEP de que a obrigação de Lock-up representaria valor marginal muito reduzido ou inexistente e de que, mesmo que o Lock-up permita um alinhamento de longo prazo, tal alinhamento “*por si só não gera benefício econômico à Qualicorp*”. Como detalhado no Relatório, em 2020, no âmbito do Instrumento de Transação celebrado pela Companhia⁷¹, houve a extinção da obrigação de Lock-up, que foi acordada em contrapartida à prorrogação do prazo de vigência das obrigações de não-competição por mais dois anos, em substituição ao pagamento da indenização adicional originalmente pactuada no Contrato (que, à época da celebração do Instrumento de Transação, corresponderia ao montante de R\$37.500.000,00, corrigidos pela variação do INPC desde a data da celebração do Contrato)⁷², a corroborar o fato de que o Lock-up efetivamente agregava valor ao contratado em benefício da Companhia⁷³.⁷⁴

136. Vale mencionar, ainda, que a venda da QSaúde pela Qualicorp para José Seripieri tinha

⁷⁰ Doc. SEI 0640190, pp. 34-35; 451.

⁷¹ Consoante relatado, o Instrumento de Transação, celebrado entre a Qualicorp e José Seripieri em 01.12.2020, teve por objetivo pôr fim às divergências havidas entre as partes, inclusive no âmbito de arbitragem, relativas ao preço de aquisição das cotas da QSaúde. No referido instrumento, foram acordadas, dentre outras disposições, (i) a extensão por mais dois anos da obrigação de não competição assumida por José Seripieri no Contrato e respectivo Aditamento; (ii) a obrigação, por José Seripieri e suas controladas, de alienação de sua participação societária na Qualicorp; e (iii) como contrapartida pela extensão do prazo da obrigação de não competição e para viabilizar a execução da obrigação de alienação de participação acionária, previstas nos itens (i) e (ii) anteriores, a dispensa da obrigação de Lock-up (Doc. SEI 1216499 – doc. 7).

⁷² Nos termos da cláusula 6.4 do Contrato, como detalhado no Relatório.

⁷³ Note-se que o próprio Contrato era expresso no sentido de que, na hipótese de exercício da Opção de Extensão da Vigência (consoante definida no Contrato), não seria estendido nem alterado o prazo de seis anos do Lock-up (cláusula 6.4.2 do Contrato). Entretanto, como a liberação feita em 2020 ocorreu dois anos após a celebração do Contrato e sua liberação parcial e paulatina apenas teria se operado, nos termos contratados, a partir do quarto ano de vigência do Contrato, cabendo, portanto, reconhecer que houve, de fato, uma novação objetiva com relação à obrigação de Lock-up em contrapartida ao acréscimo de mais dois anos em relação às obrigações de non-competite.

⁷⁴ Observe que, mesmo que a expressiva desvalorização no valor das ações que sucedeu a divulgação sobre o Contrato possa ser tida como um indicativo de que o mercado, naquele momento, entendeu que o benefício gerado para a Companhia era inferior ao valor da indenização, os fatos e medidas subsequentes detalhados neste voto vieram a evidenciar um reconhecimento de que o Contrato atendia aos interesses da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

sido aprovada em janeiro de 2020, tanto pelo CA⁷⁵, quanto pela assembleia de acionistas da Companhia, contexto em que foram ratificados os termos do Contrato⁷⁶. De mesma forma, a prorrogação do *non compete* por mais dois anos foi aprovada pelo CA da Qualicorp em dezembro de 2020 (ocasião em que todos os conselheiros eram inclusive diferentes daqueles que aprovaram o Contrato em 2018). Ainda que em 2020 José Seripieri não mais fizesse parte da administração da Qualicorp, não seria de se esperar que, se o Contrato tivesse sido celebrado em condições não equitativas, teria sido ratificado pelos acionistas e prorrogado pelos novos membros do CA, sem qualquer discussão quanto ao valor da contrapartida anteriormente contratada e paga⁷⁷.

137. Portanto, constata-se que a própria assembleia de acionistas da Companhia, em momento subsequente, não reputou que o Contrato constituísse negócio lesivo ao interesse social nos termos em que pactuado, tampouco assim entenderam os novos conselheiros de administração.

138. Observo, também, que as DFs e as contas dos administradores de 2018 foram aprovadas, por unanimidade, na AGO de 29.04.2019, nas quais o custo total do Contrato foi registrado e sua natureza e termos gerais devidamente explicitados em notas explicativas, sem que tenha havido qualquer ressalva quanto a tal pagamento. Ainda que, como visto, isso não seja fundamento a exonerar os administradores de responsabilidade administrativa, cabe reconhecer que os acionistas respaldaram o acordado, o que inclusive é significativo tratando-se de companhia com capital pulverizado e sem controlador definido.

139. Não se trata, contudo, de julgar o ocorrido no passado com base em fatos que ocorreram

⁷⁵ A ata da RCA iniciada em 08.01.2020 e encerrada em 13.01.2010 reflete decisão unânime (e sem quaisquer ressalvas) pela totalidade dos membros do CA, cuja composição, à época, contava com apenas dois dos Acusados neste PAS: Alexandre Dias e Wilson Olivieiri. Nessa RCA, considerando, entre outros fatores, as discussões estratégicas da Companhia de não dar prosseguimento ao projeto QSaúde, a inexistência de outros interessados na potencial aquisição e que o preço e condições ofertados foram considerados adequados, decidiu-se (i) pela aprovação da descontinuidade do Projeto QSaúde e consequente alienação das suas operações; (ii) pela submissão à aprovação da AGE em função da relevância do tema da alienação da QSaúde para o Sr. José Seripieri Filho (incluindo a alteração, por meio de aditivo próprio, da obrigação de não competição e não aliciamento do Sr. José Seripieri Filho para com a Companhia para permitir a atuação de operadora de planos privados de assistências à saúde (exceto na modalidade de administradora de benefícios), e a celebração de acordo de parceria comercial entre a Companhia, sua controlada Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e a QSaúde.

⁷⁶ Consoante ata da AGE de 30.01.2020, que contou com a presença de acionistas representando 42,81% do capital social total votante da Companhia, a Transação (i.e. alienação da QSaúde pela Companhia para José Seripieri) e a liberação parcial e restrita das obrigações assumidas por José Seripieri no âmbito do Contrato (necessárias para viabilizar a Transação) foram aprovadas, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, pela maioria de votos dos presentes (representando 68,94% dos votos válidos), com votos contrários de outros acionistas.

⁷⁷ Vale registrar que a liberação parcial objeto do Aditamento não afetou os demais termos do Contrato (inclusive o montante pago a José Seripieri a título de indenização), que foram expressamente ratificados, como se verifica da Cláusula 3.1 do Aditamento: “3.1. As Partes ratificam todos os demais termos e condições do Contrato que não foram expressamente alterados por meio deste Primeiro Aditamento, ficando delegado à administração da Companhia tomar quaisquer medidas para a implementação, o acompanhamento e a gestão do Contrato, incluindo a realização de eventuais ajustes contratuais aplicáveis.” (Doc. SEI 1216499 – doc. 4, p. 109).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

apenas posteriormente, mas tão somente de reconhecer que tais fatos corroboram, em alguma medida, o quanto já havia sido identificado com base nos demais elementos trazidos aos autos.

140. Ante ao exposto, não estou convencida de que o Contrato foi celebrado em condições não equitativas, a beneficiar José Seripieri, em detrimento da Companhia e, por essa razão, entendo que não cabe responsabilizá-lo por infração ao disposto no art. 156, §1º, da LSA.

III.3. Inobservância do limite global de remuneração dos administradores em alegada infração ao art. 152, *caput* c/c art. 154, *caput*

141. Como relatado, a SEP também acusou os Conselheiros de terem infringido o disposto no art. 152, *caput* c/c art. 154, *caput*, da LSA⁷⁸. Segundo a Acusação, “o pagamento previsto no Contrato se sobrepõe à remuneração recebida diretamente em razão do exercício do cargo por José Seripieri”, tendo entendido que “o pagamento previsto no Contrato tem natureza *remuneratória* e excede o montante global previamente aprovado pela assembleia geral” (grifei).

142. As Defesas, por sua vez, argumentam, em síntese, que (i) os valores pagos a José Seripieri em razão do Contrato têm natureza *indenizatória*, uma vez que constituem contrapartida a uma limitação ao exercício de direitos, não podendo, dessa forma, ser considerados remuneração ou benefício pago *em razão de serviços prestados*, para fins do disposto no art. 152 da LSA⁷⁹; e (ii) o Contrato prevê a assunção de obrigações mais amplas do que aquelas assumidas por José Seripieri em razão do seu vínculo fiduciário com a Companhia, não sendo correto afirmar, portanto, que a Companhia estaria pagando duas vezes pela mesma contrapartida.

143. A questão da maior amplitude das obrigações contratuais *vis-à-vis* às legais já foi exaurida neste voto, restando, contudo, analisar em maior detalhe a questão da natureza do pagamento feito pela Companhia como contrapartida no âmbito do Contrato.

144. Quanto a isso, a meu ver, também são procedentes os argumentos trazidos pelas Defesas no sentido de que a natureza da referida contrapartida devida é indenizatória⁸⁰, notadamente por

⁷⁸ Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, **inclusive benefícios de qualquer natureza** e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. (grifos aditados)

⁷⁹ Com efeito, na lição de Lamy Filho: “*remuneração, nos termos da lei de anônimas, é a contraprestação devida pela sociedade ao administrador pelos serviços e responsabilidades a que se obriga ao aceitar a investidura*” (LAMY Filho, Alfredo; BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. A Lei das S.A (pressupostos, elaboração, aplicação). 2ª ed. Vol III. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 402).

⁸⁰ Também aponta a doutrina: “[o] valor pago decorrente de pacto de não concorrência pode ser considerado indenização. O termo *indenização* corresponde ao ato de fazer cessar o prejuízo causado a alguém e que deve ser suportado pelo causador, podendo ainda ser entendido como equivalente pecuniário do dever de ressarcir o prejuízo. Na hipótese do pacto de não concorrência, o prejuízo que se verifica é a redução da liberdade de estabelecimento, ou ainda a redução da liberdade de estabelecer relação de emprego ou de trabalho, limitação esta caracterizada pela exclusão da possibilidade de concorrência ao ex-empregador, quer como empregado de concorrente, quer em trabalho



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

representar compensação pelo impedimento decorrente das obrigações de não fazer assumidas por José Seripieri, incluindo não apenas as ínsitas ao Lock-up, mas também as restrições de livre exercício do direito de praticar atividade comercial de maneira bem mais ampla do que imposto por lei aos administradores e ainda mais abrangente após o término do seu vínculo com a administração da Companhia⁸¹. Nesse sentido, destaco seguinte trecho do parecer juntado aos autos, da lavra do Professor Nelson Eizirik:

Não se trata pois de remunerar serviços prestados por administradores, mas de compensar prejuízos de acionistas nessa qualidade de acionistas, e não na qualidade de administrador.

De fato, a verba paga visa a recompor os prejuízos advindos da impossibilidade de o Acionista livremente dispor de seus bens, bem como de utilizar plenamente sua experiência profissional no mercado, inclusive em empresas concorrentes.

145. Também corrobora essa conclusão o fato de o Contrato ter sido registrado nas DFs da Companhia como “ativo intangível”, visto que a Companhia adquiriu um “recurso” incorpóreo, que garante benefício futuro (qual seja, a “proteção contra desenvolvimento de concorrente(s) por parte do Acionista”) apenas à Qualicorp; e não como uma “despesa”, que, como bem esclareceram os Professores Eliseu Martins e Vinícius Aversati Martins em parecer contratado pela Companhia, “*implicaria em o pagamento de indenização do Contrato ser considerado contrapartida a serviços recebidos ou a serem recebidos*”. Tal contabilização não foi objeto de qualquer ressalva pelos auditores da Companhia nem foi especificamente questionada pela Acusação.

146. Acerca do enquadramento das obrigações previstas no Contrato no conceito de “benefício” referido, para fins do disposto no art. 152 da LSA, não compartilho do entendimento da Acusação de que esse deve “*abranger realmente todos os pagamentos feitos em favor dos administradores*” (grifei). A propósito, o Colegiado da CVM já esclareceu que, embora este termo deva ser interpretado de forma ampla, para abranger “*quaisquer vantagens oferecidas aos administradores*”, sua interpretação deve “*se restringir aos benefícios pagos aos administradores em razão dos cargos que ocupam na administração. Em outras palavras, pagamentos feitos aos administradores a outro título, por exemplo, pela venda de um ativo ou prestação de serviço à*

por conta própria que possa ser tido como ato de concorrência do antigo empregador.” (João, Regiane Teresinha de Mello. Cláusula de não concorrência no contrato de trabalho. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 61).

⁸¹ Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.679.495 – SP, j. em 20.02.2020, atribui natureza remuneratória à contrapartida paga em razão da celebração de contrato de não-competição, tendo entendido que essa constituiu “verba paga por liberalidade do empregador, isto é, verba paga na ocasião da rescisão unilateral do contrato de trabalho sem obrigatoriedade expressa em lei, convenção ou acordo coletivo”. Trata-se, entretanto, de precedente em matéria tributária, relativa ao imposto de renda, em que há maior amplitude do que aquela prevista no art. 152 da LSA, justamente porque, como dito, para fins do referido dispositivo da LSA cabe aferir o que é pago pelo exercício do cargo de administrador. Além disso, mesmo em matéria tributária a questão envolvia intensa controvérsia com decisões divergentes e que essa decisão referida se deu apenas em 2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

*sociedade administrada, não estão sujeitos ao artigo 152 da Lei nº 6.404/1976*⁸².

147. Não deixo de reconhecer que podem integrar o pacote de remuneração benefícios pós-emprego ou benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo de administrador, bem como contrapartidas destinadas a promover a retenção de administradores no exercício do cargo na companhia⁸³. Porém, não identifico na contrapartida assumida pela Qualicorp no Contrato o caráter de benefício/indenização *decorrente ou atrelada ao exercício do cargo de administrador*. Repise-se, inclusive, que as obrigações negativas previstas no Contrato persistiam fosse ou não exercido cargo de gestão e se entrelaçavam de modo a impedir o acionista fundador e ex-controlador da Companhia, detentor de notável domínio sobre a clientela e outros intangíveis da Companhia, que constituem o verdadeiro âmagô do risco de que ele viesse a competir com os negócios da Qualicorp que se pretendeu afastar com a referida contratação.

148. Como também já visto, a celebração do Contrato partiu da recomendação da Spencer Stuart diante da conclusão de que a Qualicorp deveria se preparar para uma “saída organizada” de José Seripieri, tendo em vista a intenção manifestada (e depois retratada) por esse acusado de deixar a administração da Companhia. O parecer da Mercer também evidencia que a principal função do Contrato era evitar a atuação de José Seripieri em outros negócios “*não contemplados junto aos objetivos da Qualicorp*” e, portanto, não relacionados ao exercício do cargo de Diretor-Presidente ou de conselheiro de administração da Companhia.

149. Restou igualmente evidenciado nos autos, por meio dos documentos apresentados pelas Defesas, que, em paralelo às discussões dos termos do Contrato, os Conselheiros também contrataram assessores e estudos que visavam embasar a definição do pacote remuneratório oferecido a José Seripieri. Como resultado desses esforços, a Companhia e José Seripieri celebraram, no dia 28.09.2018, mesma data em que foi celebrado o Contrato, o Contrato de Diretor Estatutário, em que foi definida a remuneração devida “*pelo desenvolvimento das atividades de Diretor Presidente da Companhia e pelo cumprimento de todas as obrigações de Diretor*”.

150. A documentação acostada corrobora o quanto alegado pelas Defesas no sentido de que a indenização no âmbito do Contrato não tinha por objetivo disfarçar verbas remuneratórias nem

⁸² PAS CVM nº RJ2017/5122, já citado acima.

⁸³ Note-se que, no PAS CVM RJ nº RJ2008/4857, j. em 23.08.2011, diante da análise de contratos que previam a assunção de obrigações de não-competição (embora por pouco tempo) e o recebimento uma espécie de “*Indenização de Retenção, cujo valor corresponderia à somatória entre: (a) um múltiplo da remuneração fixa anual, e (b) o valor da remuneração fixa e variável total correspondente ao restante do prazo [do contrato]*”, o Colegiado da CVM reputou que verbas indenizatórias destinadas a promover a retenção de administradores devem ser enquadradas no conceito de “benefício” previsto no art. 152 da LSA. Nos termos do voto do Relator: “*repito mais uma vez, quando se está tratando de um plano pré-aprovado destinado a reter ou atrair executivos não há como ignorar que se está lidando com o “pacote” de remuneração ou de benefícios da empresa.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

regular o pacote remuneratório oferecido a José Seripieri, objeto disciplinado no âmbito do Contrato de Diretor Estatutário, mas sim impedir que este acusado competisse, de qualquer forma ou medida, com os negócios da Companhia, em atuação dissociada de suas atribuições de administrador, estivesse ele ainda dentro ou já fora da administração da empresa.

151. Assim, a meu juízo, (i) o pagamento previsto no Contrato não se enquadrava como “remuneração” ou “benefício” para fins do art. 152, uma vez que não estava atrelado à atuação do acusado como administrador; e (ii) o Contrato não foi celebrado com o intuito de burlar o limite global da remuneração aprovado pela assembleia geral, mas com o propósito de defender os interesses da Qualicorp, como já abordado nas Seções anteriores deste voto, portanto, também não havendo de se falar aqui em qualquer desvio de finalidade (art. 154).

152. Entendo, portanto, ser improcedente a acusação, feita em face dos Conselheiros, de inobservância do montante global de remuneração dos administradores aprovado na AGO da Qualicorp de 27.04.2018, em suposta violação ao arts.152, *caput* c/c 154, *caput*, da LSA.

IV. CONCLUSÃO

153. Por todo o exposto, voto pela **absolvição** (i) de **Alexandre Silveira Dias, Arnaldo Curiati, Cláudio Chonchol Bahbout, Nilton Molina, Raul Rosenthal Ladeira de Matos e Wilson Olivieri**, à época conselheiros de administração da Qualicorp, das acusações de infração (A) ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por suposta celebração do Contrato em condições não equitativas; e (B) ao art. 152, *caput* c/c 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por suposta aprovação de pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos administradores aprovado em assembleia geral ordinária; e (ii) de **José Seripieri Filho**, à época Diretor-Presidente e conselheiro de administração da Qualicorp, da acusação de infração ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976, por suposta celebração do Contrato em condições não equitativas.

154. Por fim, determino a comunicação da decisão do julgamento deste PAS ao Ministério Público do Estado de São Paulo⁸⁴, para as providências que entender cabíveis no âmbito de sua competência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738

Assinado de forma digital por FLAVIA
MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.12.14 17:49:37 -03'00'

Flávia Sant'Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

⁸⁴ Em complemento às informações solicitadas por meio do Ofício nº 93.2020/MSPS (Doc. SEI 1138572).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/7872

(Processo CVM SEI nº 19957.010505/2018-49)

Reg. Col. 1455/19

Acusados: Alexandre Silveira Dias
Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de administradores por infrações ao art. 152, *caput*; art. 154, *caput*; e art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Voto: Diretor Alexandre Costa Rangel

Manifestação de Voto

I. Introdução

1. Neste Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2018/7872 (“Processo”)¹, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) formulou termo de acusação² (“Acusação”) em face das seguintes pessoas:

(i) Alexandre Silveira Dias (“Alexandre Dias”), Arnaldo Curiati (“Arnaldo Curiati”),

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem aqui definidos, têm o significado que lhes foi atribuído no relatório da Diretora Relatora (“Relatório”).

² Docs. SEI 0640252 e 0659008.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Cláudio Chonchol Bahbout (“Cláudio Bahbout”), Nilton Molina (“Nilton Molina”), Raul Rosenthal Ladeira de Matos (“Raul Rosenthal”) e Wilson Olivieri (“Wilson Olivieri”), na qualidade de membros do conselho de administração da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), em violação ao **(a)** art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976³, por terem aprovado a celebração do Contrato em condições não equitativas, “*representando benefício a José Seripieri em desfavor da Qualicorp*”; e **(b)** art. 152, *caput*⁴; c/c art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, por terem aprovado o Contrato prevendo o pagamento de benefício financeiro superior ao montante global de remuneração dos administradores aprovado na AGO de 27.04.2018; e

- (ii)** José Seripieri Filho (“José Seripieri” e, quando em conjunto com os membros do conselho de administração, “Acusados” ou “Defendentes”), por infração ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976⁵, por ter celebrado o Contrato, em condições não equitativas, em desfavor da Companhia.

2. Acompanho a conclusão da Diretora Relatora pela absolvição dos Defendentes⁶ e concordo com os fundamentos utilizados para afastar **(i)** as alegações preliminares⁷; **(ii)** a imputação formulada pela Área Técnica, em face dos membros do conselho de administração da Companhia, de violação ao art. 152, *caput*; c/c art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976⁸; e **(iii)** a

³ “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.”

⁴ “Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.”

⁵ “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe o dever de informar-lhes do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.” (grifos meus).

⁶ Parágrafo 153 do voto da Diretora Relatora.

⁷ Parágrafos 6 a 19 do voto da Diretora Relatora, que tratam das alegações dos Defendentes de inépcia da Acusação, *non bis in idem*, perda de objeto e ausência de justa causa.

⁸ Parágrafos 141 a 152 do voto da Diretora Relatora.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

acusação apresentada em face de José Seripieri por infração ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

3. Minha divergência restringe-se aos fundamentos adotados pela Diretora Relatora para justificar as absolvições dos membros do conselho de administração da acusação de violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, em virtude da aprovação do Contrato em supostas condições não equitativas.

4. Nada obstante, ao final, tecerei breves considerações complementares acerca de peculiaridades que vislumbro importantes sobre a acusação de violação ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976, formulada em face de José Seripieri.

5. É o que passo a expor a seguir.

II. Mérito

6. Divido esta seção do mérito em duas partes:

- (i) na primeira, compartilho considerações sobre os requisitos necessários para que, de acordo com o arcabouço legal brasileiro, as tomadas de decisão não ensejem responsabilizações dos administradores, ressaltando a importância de que o regime de proteção das decisões negociais continue a ser aplicável também no contexto de acusações que digam respeito a eventual descumprimento do art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976; e
- (ii) na segunda, referente ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976, apresento observações adicionais acerca da acusação de violação ao comando em questão, explicando meu entendimento sobre a forma como o dispositivo deve ser interpretado quando o administrador se declara impedido e não participa da deliberação pela Companhia.

A aplicação das regras de proteção de decisão negocial a acusações de violação ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976; business judgment rule; e as possibilidades de responsabilização de administradores

7. Como explicado com maior profundidade abaixo, esta minha divergência está amparada na Lei nº 6.404/1976, no histórico de manifestações que têm prevalecido em julgamentos pelo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Colegiado⁹⁻¹⁰⁻¹¹, bem como em jurisprudência e doutrina, nacionais e estrangeiras¹², que

⁹ No PAS CVM nº RJ2016/5733, julgado em 03.12.2019, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro (Caso Gerdau), prevaleceu a aplicação do *business judgment rule*, especificamente com relação à acusação de violação ao art. 154, caput, da Lei nº 6.404/1976. Segundo o Diretor Carlos Rebello, “reitero o cuidado que se impõe na revisão de decisões negociais, não somente em reconhecimento às limitações do julgador em matéria de gestão social, como também em razão dos efeitos negativos que podem decorrer da imposição de um regime de responsabilização especialmente gravoso ao administrador que, de boa fé e agindo no interesse social, comete erros. Toda a lógica que orientou a jurisprudência norte americana a respeito dos padrões de revisão a serem adotados no exame da conduta dos administradores – fonte importante de orientação em discussões sobre o tema – busca prestigiar a discricionariedade dos administradores que, atuando nos limites da lei e do estatuto social, assumem riscos em busca do melhor interesse social e, ao fazê-lo, estão, inclusive, sujeitos às incertezas do negócio”. No mesmo sentido, nas palavras do Diretor Henrique Machado, “ao avaliar decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas, deve ser adotado o padrão de revisão da *business judgment rule*, segundo a qual, ante a inexistência de pressupostos que demonstrem má-fé, fraude, interesse, ou conflito do administrador, e diante da inexistência de qualquer falha procedimental no respectivo processo decisório, as decisões de um administrador devem, em princípio, ser consideradas regulares. Por essas razões, acompanhou o voto do Diretor Carlos Rebello de absolvição dos membros do conselho de administração da Gerdau, da acusação de infração ao art. 154 da Lei nº 6.404/76”.

¹⁰ No PAS CVM nº RJ2013/11703, julgado em 31.07.2018, Diretor Relator Gustavo Borba (Caso HRT), o Diretor Gustavo Gonzalez pontuou que “[j]á o artigo 154 exige que o administrador adote não “apenas uma conduta formalmente de acordo com os preceitos da LSA, mas, sim, materialmente em linha com os seus preceitos”. Por tal motivo, o exame de desvio de poder não se esgota em uma análise acerca da independência e do interesse do administrador. Com efeito, para que o artigo 154 cumpra com a sua finalidade, a revisão em casos de suspeita de desvio requer um olhar diferente e uma consulta mais abrangente, que busque apurar se atos praticados pelos administradores, ainda que formalmente corretos, buscavam de fato atingir fins ilegais, contrários à ordem pública ou aos interesses da companhia. Essa abrangência deve, contudo, ser delimitada com temperança, sob pena de se transformar uma obrigação de meio em uma de resultado. O caput do artigo 154 não dá ao julgador um poder indiscriminado para rever as decisões dos administradores. Em especial, não autoriza sindicatizar se a decisão tomada era a “melhor” ou mesmo a “mais adequada” dentre as possíveis. O exame acerca do exercício desviado do poder-função atribuído aos administradores não constitui, destarte, um juízo de razoabilidade ou de adequação. O que se exige é um exame das justificativas apresentadas para aquela decisão e de eventuais indícios de que o administrador exerceu os poderes que lhe foram atribuídos em função para satisfazer interesses outros que não os da companhia. (...) É fácil perceber a importância que a prova indiciária (que não se confunde com indícios isolados) tem em casos que buscam apurar o desvio de poder, dado a natureza insidiosa do ilícito. Cretella Jr. assinala, contudo, que os indícios devem ser manejados com cautela, resguardando as medidas administrativas de “abusos que, a qualquer pretexto, poderiam verificar-se por parte dos administrados ou de terceiros interessados. Do contrário, todos os atos editados pelos agentes administrativos correriam o risco de serem impugnados por espírito de chicana política”. Com essa ressalva, Cretella Jr. destaca, a partir das experiências francesa e italiana, os principais sintomas (ou indícios) do desvio de poder no direito administrativo, dentre os quais destaco, como exemplos: (i) contradição do ato com atos posteriores ou anteriores; (ii) motivação exagerada, contraditória ou insuficiente; (iii) alteração dos fatos; (iv) ilogicidade manifesta; (v) disparidade de tratamento; e (vi) precipitação com que o ato foi editado. Feitas as adaptações necessárias, parece-me que tais indícios podem também ser utilizados no âmbito do direito societário.” (grifos meus).

¹¹ No PAS CVM nº RJ2007/4476, julgado em 12.03.2008, Diretor Relator Eli Loria (Caso Bellows), o Diretor Marcos Pinto, acompanhado pela maioria, manifestou-se no seguinte sentido: “O art. 154 da lei determina que o administrador deve exercer suas funções “para os fins e no interesse da companhia”. E, na minha opinião, as provas contidas nos autos não permitem concluir que a conduta da acusada não foi pautada pelo interesse social. (...) Não custa lembrar – pois os controladores costumam esquecer – que a *business judgment rule*, acatada em diversos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

consagram as regras da *business judgment rule* como padrão de revisão aplicável para a análise da regularidade das tomadas de decisões negociais por parte de administradores de sociedades anônimas. Observadas as ressalvas de praxe sobre o cuidado e rigor com que institutos e construções de direito comparado podem ser utilizados no Brasil, trata-se aqui, primordialmente, de uma defesa da relevância do regime, vigente no ordenamento jurídico nacional, de proteção das decisões negociais tomadas por administradores de companhias abertas no mercado de valores mobiliários.

8. A *business judgment rule* funciona como um mecanismo de presunções aplicáveis às decisões negociais, desde que atendidos determinados critérios e observados certos parâmetros. Trata-se de uma construção plenamente válida e compatível, de forma literal e sistemática, com o regime jurídico de responsabilidade dos administradores previsto na Lei nº 6.404/1976¹³.

precedentes desta autarquia, também vale para os administradores independentes ou eleitos pelos acionistas minoritários. Digo mais: ela vale com mais força para eles.”

¹² A propagação ao redor do mundo de conceitos intrínsecos às regras de *business judgment rule*, regime jurídico nascido nos Estados Unidos da América, mais especificamente no estado de Delaware, atinge também o direito alemão de regulação do mercado de valores mobiliários. Confira-se: “*Standard of care and fault. A member of the management body is liable for breaches of duties based on the standard of care set out in section 43(1) dGmbHG, section 93(1) dAktG, section 25(1) öGmbHG, section 84(1) öAktG. The ‘prudent’ business man or manager referred to in these provisions orients himself – again inspired by the function of a ‘mandatary’ (...) – on the standard for managing the assets of a third party, i.e. an independent, fiduciary safeguarding of third-party property interests. In the event the company suffers damage as a result of conduct of the manager within the scope of his responsibility, the breach of a duty and the fault of the manager will be subject to rebuttable presumption. Of course, the members of the management body have a degree of entrepreneurial discretion which is why not every incorrect decision or every mistake must be viewed as a breach of the standard of care (‘business judgment rule’; cf. section 93(1) second sentence AktG). However, the exemption from liability on the part of the manager within the scope of business judgment to which he is entitled presumes that a business decision is based on a careful investigation of the bases for the decision. This requires that he exhaust all available sources of information, factual and legal, regarding the specific decision to be made and carefully weigh the advantages and disadvantages of the available options based on such information and take identifiable risks into account. As a result, within the scope of business judgment, only plainly indefensible management decisions give rise to an obligation for damages, e.g. an irresponsible assumption of risk.*” (grifos meus) (ROTH, Günter H; KINDLER, Peter. The Spirit of Corporate Law: Core Principles of Corporate Law in Continental Europe. Munich; Oxford: Hart Publishing, 2013. pp. 101).

¹³ “(...) não se quer defender que a menção à *business judgment rule* ou a decisões estrangeiras deve ser evitada nos julgamentos ocorridos no Brasil. A referência à regra facilita a transmissão do entendimento de que administradores não devem ser julgados com base no resultado e no mérito de seus atos. Além disso, a utilização do direito comparado é útil naqueles temas em que os estrangeiros já possuem ampla experiência e serve de apoio ao julgador brasileiro em suas reflexões sobre a melhor forma de lidar com o caso concreto. (...) em casos que tratam da responsabilidade de administradores, a discussão a ser travada deve ser restrita ao texto da legislação nacional, tal como debatida e aprovada nos termos do processo legislativo. (...) Quanto à frente de alegações de infração ao art. 154 da Lei das S.A., deverá verificar se o administrador deixou de, nas palavras do dispositivo,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

9. Em suma, as decisões desinteressadas, refletidas e informadas – se tomadas de forma independente, com diligência e de boa-fé – gozam da presunção de regularidade e aderência aos deveres impostos aos administradores¹⁴.
10. Um dos mais relevantes objetivos desse entendimento consiste em proteger os atos regulares de gestão que busquem, de forma legítima, a consecução dos objetos sociais das respectivas companhias, agentes relevantes que são para geração de riqueza, empregos e pagamento de impostos. É com isso em mente que o sistema legal de responsabilidade de administradores existente na Lei nº 6.404/1976 – conforme a regra da *business judgment rule* – impede que decisões desinteressadas, refletidas e informadas deem margem à responsabilização indevida dos administradores, em virtude, por exemplo, de eventuais insucessos empresariais no curso regular das atividades desenvolvidas pela companhia.
11. Possíveis flexibilizações desse regime de proteção das decisões negociais, em última análise, podem gerar externalidades negativas sensíveis¹⁵, tais como (i) o afastamento de

“exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) Fato é que, com a aplicação da legislação brasileira, resguardar-se-á o administrador que atuar diligentemente, no interesse da companhia e de boa-fé. Em razão das normas de atribuição do ônus da prova no processo cível e no processo administrativo sancionador, a regra é que nenhuma responsabilidade lhe será imputada até que o autor da ação ou a área técnica da CVM, conforme o caso, comprove irregularidades em sua atuação. É extremamente similar ao que ocorre com a aplicação da business judgment rule pelas cortes norte-americanas. Não há, portanto, necessidade de se discutir a incidência dessa regra às particularidades de casos concretos aqui julgados. Isso pode trazer mais incertezas do que segurança (afinal, deveria o administrador brasileiro acompanhar o que dizem os tribunais de Delaware?). Incumbe aos julgadores, sim, aplicar o estruturado regime de responsabilidade de administradores de sociedades anônimas previsto no ordenamento jurídico nacional”. (grifos meus) (FILHO, Caio Machado; BRIGAGÃO, Pedro. A (des)necessidade de aplicação da business judgment rule no direito brasileiro. In: *Novos Temas de Direito e Corporate Finance*. Orgs. BARBOSA, Henrique; Botrel, Sérgio. São Paulo: Quartier Latin, 2019. pp. 619-620).

¹⁴ “Conclui-se, com isso, que não poderá ser responsabilizado o administrador que tiver agido diligentemente (artigo 153 da Lei das S.A.), dentro de suas atribuições e poderes (artigo 154), de boa-fé e com lealdade à companhia (artigo 155), no interesse da companhia (artigos 154, 155 e 156) e sem desprezar os demais dispositivos do ordenamento jurídico. O principal fundamento desse raciocínio, registre-se, é o fato de que as obrigações contraídas por diretores e conselheiros são de meio, e não de resultado: eles não respondem somente por causarem prejuízos, mas sim por causarem prejuízos em razão da má execução de suas funções.” (BRIGAGÃO, Pedro Henrique Castello. A administração de companhias e a business judgment rule. São Paulo: Quartier Latin, 2017. p. 53).

¹⁵ “*Authority and accountability are in constant tension. Seeking to hold directors accountable for their decisions necessarily reduces the efficiency of corporate decision making. Conversely, deference to the board’s authority necessarily entails a risk of opportunism and even plain carelessness. Choosing the appropriate balance between authority and accountability is the central problem of business judgment jurisprudence. (...) The thesis of this article*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

administradores competentes de um mercado de trabalho que pressupõe elevada diligência e capacidade técnica, a partir do fundado receio de que seus atos regulares de gestão possam vir a ser posteriormente questionados, com o efeito reverso de atração de aventureiros ou profissionais menos diligentes; **(ii)** uma influência indevida no comportamento dos administradores, que poderiam passar a evitar a tomada de decisões que envolvam algum risco¹⁶, ainda que tais decisões tenham seguido todas as regras aplicáveis e que tenham sido tomadas de boa-fé, no melhor interesse da companhia¹⁷; e **(iii)** o incremento dos custos dos seguros de responsabilidade de administradores, arcados pelas próprias companhias, o que, indiretamente, acaba penalizando toda a sua base de acionistas.

12. Um ponto importante para o presente caso consiste em frisar que o regime de presunções

is that, except to verify that the relevant preconditions for review are not met, courts should simply abstain from reviewing operational decisions. (...) Operational decisions are a species of what economists refer to as repeat transactions. Where parties expect to have repeated transactions, the risk of self-dealing by one party is constrained by the threat that the other party will punish the cheating party in future transactions. To be sure, shareholder discipline is not a very important check on directorial self-dealing. Yet, as we have seen, it is just one of an array of extrajudicial constraints that, in totality, give directors to exercise reasonable care in decision making. True, these constraining forces do not eliminate the possibility of director error. The directors will still err from time to time. It is precisely this sort of error, however, that this Article has argued courts traditionally—and appropriately—abstain from reviewing.” (grifos meus) (BAINBRIDGE, Stephen Mark. The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine (2004). 57 Vanderbilt Law Review 83 (2004), UCLA, School of Law, Law and Econ. Research Paper nº 03-18, disponível em <https://ssrn.com/abstract=429260>, acesso em 13.12.2021).

¹⁶ Nos termos da exposição de motivos da Lei nº 6.404/1976: “Os artigos 154 a 161 definem, em enumeração minuciosa, e até pedagógica, os deveres e responsabilidades dos administradores. É Seção da maior importância no Projeto porque procura fixar os padrões de comportamento dos administradores, cuja observância constitui a verdadeira defesa da minoria e torna efetiva a imprescindível responsabilidade social do empresário. (...) As normas desses artigos são, em sua maior parte, meros desdobramentos e exemplificações do padrão de comportamento dos administradores definido pela lei em vigor - o do "homem ativo e probo na administração dos seus próprios negócios" (§7º do art. 116 do Decreto-lei nº 2.627) e, em substância, são as que vigoram, há muito tempo, nas legislações de outros povos; formuladas, como se encontram, tendo presente a realidade nacional, deverão orientar os administradores honestos, sem entorpecê-los na ação, com excessos utópicos. Servirão, ainda, para caracterizar e coibir abusos.” (grifos meus).

¹⁷ “(...) a responsabilização dos administradores por danos causados no exercício de suas atribuições encontra dificuldades práticas importantes: como pode o juiz, presumivelmente sem qualquer expertise empresarial, avaliar o mérito das decisões gerenciais, contando ainda com o viés da passagem do tempo? A responsabilidade dos administradores por erros ou más decisões não teria por efeito inibir a assunção de risco empresarial, via de regra benéfica aos acionistas e ao funcionamento do sistema capitalista como um todo? Seria possível atrair os melhores talentos para a administração das companhias, responsabilizando-os pelos erros cometidos, quando os acertos se revertem preponderantemente em benefício alheio?” (grifos meus) (PARGENDLER, Mariana. Responsabilidade Civil dos Administradores e Business Judgment Rule no Direito Brasileiro. Revista dos Tribunais. vol. 953, 2015, p. 5).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

estabelecido pela *business judgment rule* não se aplica de forma irrestrita e absoluta. Como dito acima, existem diversos critérios e parâmetros que, se não atendidos, derrubam a proteção das decisões negociais tomadas pelos administradores, permitindo uma avaliação de mérito sobre as ações ou omissões dos administradores, acompanhada, conforme o caso, das respectivas responsabilizações. Com efeito, em algumas situações específicas, os termos da regra da *business judgment rule* não serão aplicáveis e caberá adentrar, de algum modo, na análise da decisão em si¹⁸ – por exemplo, se for constatado que **(i)** se está diante de uma decisão incompreensível, contraditória ou manifestamente irracional; **(ii)** algum procedimento societário ou arranjo de governança previamente estabelecido não foi observado; **(iii)** há elementos consistentes que sinalizem que atos fraudulentos, ilegais ou simulados tenham sido praticados com o intuito de conferir aparente regularidade formal a uma decisão que, em substância, se revela contrária às obrigações dos administradores e aos interesses da companhia.

13. Caso qualquer dos exemplos acima seja verificado em um caso concreto, a partir daí, os atos de gestão deixam de usufruir da presunção de regularidade e não apenas podem, como devem ser apurados com alguma profundidade, inclusive de mérito, para checar se os deveres e obrigações impostos aos administradores foram plenamente atendidos.

14. Passo agora ao caso concreto, objeto do Processo.

15. A Diretora Relatora, em seu voto, manifestou-se no sentido de que “a alegada infração

¹⁸ “First, without the [business judgment] Rule, the raw power of equity could conceivably require all challenged Board decisions to undergo an entire fairness review. The Rule is the tool used by a court to restrain itself from implementing such a review. This is the most important function of the Rule. Second, as a result of equity needing to be restrained, there is no room in the Rule formulation for fairness; fairness and fiduciary duties must be mutually exclusive. Third, there are three policy drivers that underlie the use of the Rule. Protecting the Board’s statutory authority to run the company without the fear of its members being held liable for honest mistakes of judgment; respect for the private ordering of corporate governance arrangements which almost always grants extensive authority to the Board to make decisions on behalf of the corporation; and the recognition by the courts that they are not business experts, making deference to Board authority a necessity. Fourth, the Rule is an abstention doctrine not just in terms of precluding duty of care claims, but also by requiring the courts to abstain from an entire fairness review if there is no evidence of a breach in fiduciary duties or taint surrounding a Board decision. Fifth, stockholder wealth maximization (SWM) is the legal obligation of the Board and the Rule serves to support that purpose. The requirement of SWM enters into corporate law through a Board’s fiduciary duties as applied under the Rule, not statutory law. In essence, SWM is an equitable concept.” (grifos meus) (SHARFMAN, Bernard S.; SHARFMAN, Bernard S.. The Importance of the Business Judgment Rule. 14 New York University Journal of Law and Business 27 (Fall 2017), disponível em <https://ssrn.com/abstract=2888052>, acesso em 13.12.2021).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

ao art. 154 não deve ser analisada, neste caso, sob o crivo do teste de entire fairness, tampouco sob a ótica da business judgment rule, cabendo sim avaliar, no mérito, o racional adotado e, assim, a finalidade pretendida com a decisão para aferir se visava “lograr os fins e interesses da companhia”, como preceitua o art. 154, caput, da LSA” (grifos meus).

16. Tenho opinião diversa, com a devida vênia.

17. Alinhado com precedente mais recente da Autarquia sobre o assunto¹⁹, entendo que a proteção das decisões negociais dos administradores aplica-se, também, a imputações de violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, de modo que, quando se está diante de uma decisão negocial, desinteressada, refletida e informada, não cabe qualquer análise de mérito sobre o racional adotado pelos acusados²⁰.

18. O dispositivo em questão pode abarcar, perfeitamente, acusações de desvio de poder ou violação dos interesses da companhia, que busquem questionar ações ou omissões de administradores que carregam, de forma preponderante, aspectos inequívocos de decisões negociais – como verificado neste Processo, aliás. São atos de gestão carregados de elementos valorativos, percepções de conveniência e oportunidade comercial, avaliações de risco e retorno, vantagens e desvantagens, cujo mérito apenas os administradores têm condições de avaliar, respeitadas as regras legais e estatutárias aplicáveis.

¹⁹ PAS CVM nº RJ2016/5733, julgado em 03.12.2019, conforme nota de rodapé nº 9, acima.

²⁰ “(...) como já dito, a função dos administradores de sociedades anônimas configura uma obrigação de meio, e isso não se altera com o standard de conduta positivado no caput do art. 154 da Lei das S.A. Não é porque os administradores devem observar os interesses sociais quando da tomada de decisões negociais que eles se obrigam à obtenção de um resultado. Eles comprometem-se, na verdade, com o cumprimento de seus deveres legais, o que é muito diferente. Consequentemente, a avaliação da conduta de um diretor ou um conselheiro sob a ótica do referido dispositivo não implica a reavaliação do mérito de sua decisão. Isto é, o fato de o julgador entender, a posteriori, que outra decisão, diferente daquela que foi tomada, teria atendido melhor aos interesses da companhia não deve levar, automaticamente, ao entendimento de que o caput do art. 154 foi violado. (...) Uma decisão simplesmente ruim, do ponto de vista negocial, não constitui indício de desvio de finalidade. Decisões infelizes são comuns na rotina das sociedades anônimas, na medida em que administradores são impelidos a tomar riscos e a agir em cenários de incerteza e imprevisibilidade. É da própria essência de sua atividade. Tais decisões, portanto, não são capazes, por si só, de inspirar qualquer dúvida quanto à sua higidez ou aos interesses verdadeiramente perseguidos pelos administradores, e não indicam o cometimento de alguma irregularidade. (...) Por outro lado, pode ocorrer de uma decisão negocial se mostrar, no seu mérito, ininteligível ou irracional, carente de fundamento ou lógica econômica”. (grifos meus) (LOPES, Marília; BRIGAGÃO, Pedro. O Mérito de Decisões Negociais como Prova de Violação do art. 154 caput da Lei das S.A. In: Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários. São Paulo: Almedina, 2021, no prelo, pp. 306-307).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

19. Caso a acusação não apresente qualquer elemento probatório consistente que demonstre **(i)** alguma falha na higidez do processo decisório; **(ii)** algum tipo de fraude ou má-fé – que poderia, por hipótese, tentar travestir de aparente conformidade um processo de decisão eivado de irregularidades, ao cabo destinado a não atender os interesses sociais; ou **(iii)** que a decisão não foi tomada de forma desinteressada, refletida e informada, entendo que os atos negociais dos administradores das sociedades anônimas, inclusive quando apontados como possíveis violadores do art. 154, §1º, da Lei nº 6.404/1976, permanecem protegidos pelo regime jurídico de presunção de regularidade da *business judgment rule*²¹.

20. O presente caso, a meu ver, enquadra-se com precisão na abordagem proposta acima.

21. Em resumo, a análise das possíveis irregularidades descritas na Acusação passa por avaliar se as decisões tomadas por conselheiros de administração – especificamente quando negociaram e se manifestaram favoravelmente à celebração do Contrato pela Companhia com José Seripieri – poderiam representar uma infração aos deveres dos administradores de exercerem suas atribuições, nas palavras do art. 154, *caput*, da lei do anonimato, “*para lograr os fins e no interesse da companhia*”.

22. Nesse sentido, é importante assentar que as ações dos acusados mencionadas na Acusação, além de serem decisões negociais, seguiram os procedimentos societários, legais e de governança aplicáveis, observando as regras estabelecidas no estatuto social da Companhia. A competência de aprovação do Contrato era do conselho de administração, cujos membros efetivamente negociaram e deliberaram sobre o assunto. Ausente à época dos fatos – tanto na lei, quanto no estatuto social – qualquer outra instância de aprovação, não há que se falar que o tema

²¹ “Dessa maneira, o mérito de uma decisão negocial somente poderá ser utilizado como prova de infração ao caput do art. 154 se for inexplicável, do ponto de vista econômico, e estiver acompanhado de outros indícios que apontam nessa mesma direção (por exemplo, o administrador auferir ganhos pessoais com a decisão; a pessoa por ela beneficiada ter relações próximas com o administrador; a burla dos controles internos da companhia; a ausência de um processo decisório; evidências de interferência do controlador nas decisões tomadas). Com efeito, vale esclarecer que a análise do mérito da decisão negocial à luz do comando do caput do art. 154 – insista-se nessa distinção – não deverá envolver um juízo de razoabilidade. Não poderá o julgador examinar se a decisão tomada no calor dos acontecimentos foi, de fato, a mais adequada ou a que melhor atendia aos interesses sociais, sob pena de se transfigurar a obrigação de meio, conferida pela lei aos administradores, em uma obrigação de resultado.” (op. cit., pp. 315).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

deveria ter sido deliberado em qualquer outra esfera. Muito menos, como pontuado pela Acusação, em assembleia geral de acionistas²², que já havia aprovado, de forma soberana, as atribuições e competências do conselho de administração, por meio das regras estatutárias então vigentes. Também por esse motivo, a derrubada do regime de proteção das decisões negociais não poderia ocorrer em decorrência de atos *ultra vires*, pois as instâncias competentes e com poderes para tratar do Contrato foram respeitadas.

23. Além disso, não consta dos autos qualquer sinalização, nem prova, no sentido de que a celebração do Contrato tenha contado com qualquer participação ou envolvimento por parte de José Seripieri pelo lado da Companhia, seja como administrador, seja como acionista. Em sentido diametralmente oposto, o referido acusado posicionou-se com clareza exclusivamente como contraparte da Companhia nas negociações relativas ao Contrato, abstendo-se de se manifestar nas oportunidades em que o tema foi discutido e deliberado em reuniões do conselho de administração, dando cumprimento ao comando do *caput* do art. 156 da Lei nº 6.404/1976. Também chama atenção que os membros do conselho de administração que deliberaram favoravelmente ao Contrato sequer foram indicados por José Seripieri²³, não tendo sido sustentado pela Acusação qualquer tipo de vínculo ou relacionamento porventura existente entre os membros do conselho de administração e José Seripieri – hipótese que poderia, em tese, desde que em conjunto com outras provas, insinuar alguma forma de interferência indevida ou irregularidade no exercício das atribuições dos administradores “*para lograr os fins e no interesse da companhia*”, nas palavras da lei.

24. Ainda, a Companhia envolveu diversos assessores externos especialistas nos temas; os termos e condições do referido instrumento foram objeto de intensas negociações, que se arrastaram por quase 8 meses; o assunto foi discutido em mais de uma dezena de reuniões do

²² De todo modo, cabe a referência ao fato de que, posteriormente, os termos e condições do Contrato foram corroborados em assembleia geral extraordinária de acionistas da Companhia realizada em janeiro de 2021.

²³ Ainda que tivessem sido eleitos com o voto favorável de José Seripieri em assembleia geral de acionistas, esse fato, por si só, não seria capaz de demonstrar qualquer tipo de influência ou interferência, considerando que o §1º do art. 154 da lei da anonimato dispõe que “[o] administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

conselho de administração; e, como dito, a contraparte do Contrato não participava das referidas reuniões.

25. Diante da deliberação do Contrato em reunião do conselho de administração²⁴, os referidos acusados tinham a possibilidade de aprovar, rejeitar ou se abster a respeito. Uma decisão claramente subjetiva, relacionada às percepções dos administradores acerca do que lhes parecia ser a melhor decisão “*para lograr os fins e no interesse da companhia*”.

26. Está comprovado nos autos, como resumido acima, que os procedimentos legais e estatutários foram seguidos e que, em complemento, foram adotadas diversas diligências para validação dos termos, condições, prazos e valores do Contrato, sendo irretocável a higidez do processo decisório no caso concreto. Mas não apenas isso. Não identifiquei, no Processo, elementos probatórios que sugiram fraude, má-fé ou alguma modalidade de decisão irracional.

27. Por tais motivos, não vislumbro fundamento que autorize a Autarquia a avançar no mérito de uma decisão negocial para decidir se um determinado ato de gestão regular se deu “*para lograr os fins e no interesse da companhia*” – considerando que **(i)** esse ato de gestão *(a)* foi extensamente discutido, negociado e amparado na opinião de especialistas externos; *(b)* não contou com a participação da contraparte nas instâncias decisórias da Companhia; *(c)* seguiu todas as etapas societárias e de governança exigidas pelo estatuto social e pela lei; e **(ii)** não foi apresentada qualquer evidência que pudesse sinalizar algum tipo de má-fé, fraude ou simulação.

28. Indo além, como poderíamos entrar no terreno pantanoso de opinar em qualquer grau sobre o mérito de uma decisão negocial (regular e sem vícios aparentes), para fins de apuração de aderência ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, e fazer qualquer juízo de valor sobre **(i)** o valor do Contrato, de R\$ 150 milhões; **(ii)** o prazo de vigência das obrigações assumidas por José Seripieri, de 6 anos; **(iii)** o escopo do Contrato, que incluía cláusulas de *non-compete*, *lock-up* e *non-solicitation*; **(iv)** os parâmetros utilizados pelas consultorias especializadas de renome, como McKinsey, Spencer Stuart e Mercer, para definição do valor da indenização a ser paga à contraparte da Companhia no Contrato; e **(v)** a utilização, como referência de cálculo para fins

²⁴ Conclave iniciado em 12.09.2018, suspenso no mesmo dia, e concluído em 25.09.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

do Contrato, da remuneração anual de José Seripieri como diretor presidente?

29. De que forma minimamente razoável teríamos condições técnicas e até mesmo legais de concluir que os atos dos membros do conselho de administração – que culminaram na celebração do Contrato com tais características específicas – não teriam sido praticados para lograr os objetivos e no interesse da Companhia, como prescreve o art. 154, *caput*, da lei?

30. Será que, se a indenização prevista no Contrato a ser paga a José Seripieri tivesse sido maior, ainda assim chegaríamos à conclusão de que as atribuições dos membros do conselho de administração foram exercidas para atingir os fins e no interesse da Companhia? E se as obrigações assumidas pela contraparte da Companhia tivessem sido mais restritas, com um rol menor de cláusulas restritivas de direitos impostas a José Seripieri? Se o prazo de não competição tivesse sido mais curto? Se o parâmetro adotado para fins de cálculo da indenização não fosse a remuneração anual contratada pela Companhia com José Seripieri, mas um valor ainda maior, que poderia ser equivalente, por exemplo, ao somatório da remuneração de todos os administradores da Companhia em um determinado período?

31. Entendo que não cabe à Autarquia responder a tais perguntas. Esse é o perigo, a meu ver, de deixar de lado o regime jurídico da *business judgment rule* quando se fala da aplicação do art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976 a decisões negociais hígdas, que não ostentem qualquer sinal de irregularidade, má-fé ou conteúdo manifestamente incompreensível ou teratológico. São muitas as variáveis subjetivas e negociais, todas elas sujeitas a uma dinâmica própria de mercado e dos interesses das partes em uma negociação privada legítima, no contexto de um processo estruturado de alocação de riscos, conduzido entre agentes capazes e devidamente assessorados.

32. Volto ao meu ponto central para concluir esta divergência: ausentes quaisquer provas de falhas de procedimento, má-fé ou desvios de conduta que derrubem o regime jurídico de proteção das decisões negociais dos administradores de companhias abertas no Brasil, os atos regulares de gestão continuam a usufruir da presunção de regularidade e conformidade com os ditames legais, inclusive no que diz respeito ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

33. Ante o exposto, considerando que os atos dos administradores da Companhia objeto da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Acusação neste caso consubstancia uma decisão eminentemente negocial – e não se verificando qualquer fragilidade na higidez do processo decisório, fraude, má-fé, simulação ou prova no sentido de que a decisão não teria sido desinteressada, refletida ou informada –, entendo que o regime de presunções de regularidade existente em nosso ordenamento jurídico, alinhado com as construções da *business judgment rule*, aplica-se integralmente ao caso e, com base nesse fundamento, voto pela absolvição dos acusados.

Considerações sobre o art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976, nas hipóteses em que o administrador se declara impedido e não participa da deliberação; ônus da prova para demonstração da equitatividade

34. O meu segundo ponto refere-se à acusação de violação ao art. 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976, formulada em face de José Seripieri – acionista fundador e administrador da Companhia que se absteve de participar das negociações e deliberações relativas ao Contrato, nos termos do art. 156, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.

35. Concorde com os fundamentos adotados pela Diretora Relatora, que culminaram na absolvição do acusado, no sentido de que **(i)** “*não restou demonstrada irregularidade na conduta do acusado, não apenas porque ele não participou de nenhuma das reuniões do CA em que foram discutidos pela Companhia os termos do Contrato, mas, notadamente, em razão de não ter restado evidenciado que o processo decisório conduzido em relação à aprovação do Contrato pelo CA da Qualicorp se deu sob influência de José Seripieri ou para beneficiá-lo, em detrimento do interesse social*”; e **(ii)** “[*e*]m relação aos aspectos materiais apontados pela SEP, faço referência às considerações já tecidas em relação à amplitude das obrigações contratuais assumidas por José Seripieri, nos termos em que pactuadas”.

36. Apesar disso, tenho algumas observações complementares a fazer, que me parecem oportunas.

37. A estrutura da Acusação parece adotar a premissa de que caberia a José Seripieri o ônus de provar que o Contrato se deu em condições equitativas – ainda que o acusado tenha se declarado impedido; ainda que ausente qualquer prova de que o acusado, por vias transversas,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

tenha comprometido a higidez do processo decisório conduzido pela Companhia; e ainda que o procedimento inscrito no art. 156, *caput*, tenha sido observado na íntegra.

38. A esse respeito, é importante repisar que José Seripieri não participou da negociação do Contrato como administrador (nem como acionista) da Companhia. Os autos confirmam que o acusado ocupou, em sentido diverso, exclusivamente o polo oposto ao da Companhia, no âmbito de uma negociação privada entre dois agentes capazes. Cada parte do Contrato buscou, de forma legítima, maximizar os respectivos direitos e aspectos positivos que poderiam ser extraídos da operação conduzida de acordo com o princípio da boa-fé objetiva; bem como minimizar as esperadas obrigações e contrapartidas que poderiam ser assumidas.

39. O acusado, ao considerar que possuía um interesse conflitante com o da Companhia nas tratativas relacionadas ao Contrato – como determina o art. 156, *caput*, da lei – atendeu à vedação que o impedia de intervir na operação e nas deliberações que os demais administradores tomassem a respeito, abstendo-se de atuar pela Companhia em qualquer questão relacionada ao Contrato.

40. Diante dessa abstenção e das demais circunstâncias fáticas do caso, não recai sobre o referido administrador – que se declarou impedido e não participou da tomada de decisão pela Companhia – o ônus de provar que o Contrato, conforme redação legal do art. 156, §1º²⁵, foi celebrado “*em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros*”. Esse ônus cabe ao terceiro que entenda, por qualquer motivo, que os termos do comando legal transcrito acima tenham sido descumpridos (seja alguma área técnica do regulador do mercado de valores mobiliários; a Companhia; ou qualquer terceiro interessado).

²⁵ “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe o dever de esclarecê-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse. § 1º Ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiros. § 2º O negócio contratado com infração do disposto no § 1º é anulável, e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver auferido.” (grifos meus).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

41. O acusado optou por se posicionar, exclusivamente, como contraparte da Companhia no Contrato, de forma não apenas transparente, mas também bastante assertiva²⁶. A partir desse momento, não parece razoável e nem lógico que se desloque para tal administrador, que não atuou em nome da Companhia nas discussões sobre o Contrato, o ônus da prova que assegure que as condições contratadas foram equitativas e idênticas àquelas que teriam sido celebradas pela Companhia com terceiros²⁷.

42. Como exigir do administrador que não atuou pela Companhia que seja ele o responsável por demonstrar que o negócio seguiu bases idênticas àquelas que teriam sido celebradas – pela sua contraparte – com terceiros? Considerando que não houve interferência indevida ou má-fé na condução do processo decisório da Companhia, temos que o referido administrador não acompanhou o assunto pela Companhia; ou seja, nas discussões relativas ao Contrato, ele estava de fora da estrutura social, do outro lado da negociação. Como impor ao acusado – que não esteve envolvido na negociação pela Companhia – a obrigação e o ônus de comprovar que o resultado final de uma negociação independente, longa e intensa observou condições equitativas, sob a ótica de sua contraparte? Além disso, não é razoável exigir do administrador, que se absteve de atuar pela Companhia, a obrigação de se autoimpor algum balizador ou limite às suas pretensões e possibilidades negociais. No contexto de uma negociação legítima, o alinhamento de vontades entre partes independentes foi atingido de forma hígida e procedimentalmente correta, estando ausentes elementos que sugiram a existência de sinais de alerta.

²⁶ Nas palavras da Acusação, “há registros de que as discussões se estenderam por prazo compatível com uma efetiva negociação e não com a mera homologação de um negócio cujos termos estivessem previamente acordados”.

²⁷ “(...) o desrespeito ao procedimento previsto no art. 156 da Lei das S.A. enseja a inversão do ônus da prova. Demonstrada a existência de interesse extrassocial do gestor, a ausência de comunicação e/ou a inexistência de abstenção será prova da culpa, partindo-se do pressuposto de que a decisão tomada pela companhia foi defeituosa, passando a ter, então, o administrador de fazer prova em sentido contrário, ou seja, de que a operação foi razoável, equitativa e útil à companhia, a qual não sofreu qualquer dano – o que serve como incentivo para que seja respeitada a norma procedimental. Por sua vez, ainda que respeitado o procedimento previsto no art. 156 da Lei 6.404/76, pode a operação realizada ser revisada caso não tenha sido razoável, equitativa ou útil à companhia; todavia, nesse caso, o ônus probatório sobre o fato de a operação ser unfair recai sobre quem contesta o ato de gestão. A rigor, e sem precisar entrar na discussão sobre se a responsabilidade dos administradores é contratual ou aquiliana, tal orientação vai ao encontro da interpretação majoritária dada ao art. 158, II, da Lei das S.A., no sentido de que há presunção de culpa (presunção *juris tantum*) em caso de violação da lei e do estatuto, invertendo-se, então, o ônus da prova.” (grifos meus) (SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: lealdade e conflito de interesses. São Paulo: Almedina, 2020. p. 195).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

43. Tomemos como exemplo um caso hipotético em que um administrador negocia sua remuneração e eventuais contratos de opção de compra e ações com a companhia, diretamente com o conselho de administração ou por meio de algum comitê específico – assumindo que o administrador não participa da negociação e da decisão pela companhia; e que não haja qualquer sinalização de fraude, má-fé ou desvios de conduta. Nessas circunstâncias, não soaria crível demandar do referido administrador, nos termos do art. 156, §1º, da lei, algum fator limitador ao exercício de sua autonomia privada em uma negociação legítima e de boa-fé, travada entre partes capazes e independentes. Entendo que não deveria ele – uma única pessoa natural negociando os termos e condições de um contrato com uma sociedade anônima de capital aberto – parametrizar a negociação de seus direitos, sacrificar seus interesses ou suavizar as condições propostas que estejam sendo negociadas com a companhia como contraparte. Tenho dificuldade de vislumbrar, em termos realistas, uma situação em que o administrador – que não tem a mesma estrutura patrimonial, equipe e recursos da companhia – tenha efetivas condições de se desincumbir do ônus de assegurar que o resultado das tratativas tenha atingido parâmetros equitativos, razoáveis ou idênticos àqueles que seriam contratados pela sua contraparte com terceiros.

44. Assim, entendo que o administrador que se declara impedido – desde que efetivamente não participe das discussões e deliberações referentes ao negócio conflitado, seguindo o comando do art. 156, *caput* – não se encontra na posição adequada para fazer cumprir a obrigação de assegurar que o negócio se dê **(i)** em bases equitativas; **(ii)** de acordo com padrões de mercado; ou **(iii)** em condições idênticas àquelas que teriam sido contratadas pela sua contraparte com terceiros. Esse ônus de prova, em tais casos, se desloca para quem quer que tenha interesse de discutir a regularidade da decisão negocial. A rigor – caso os trâmites de abstenção e impedimento ocorram em linha com o disposto do *caput* do art. 156 e presumindo a ausência de interferências indevidas sobre a companhia –, entendo que o administrador conflitado ocupará posição bastante similar à do terceiro independente mencionado ao final do §1º do art. 156.

45. A partir daí, por outro lado, caberá aos administradores que negociaram pela companhia uma atenção redobrada em termos de procedimentos e diligência, por estarem atuando, em nome da companhia, com um administrador conflitado. Em outras palavras, nas hipóteses em que o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

administrador conflitado se declara impedido, o comando legal (art. 156, §1º) tende a gerar consequências, de forma mais racional e sistemática, aos demais administradores que negociaram e aprovaram, em nome da companhia, o negócio objeto de conflito. São tais administradores que, em tese, têm os elementos necessários para garantir que a operação seja equitativa e esteja alinhada com padrões de mercado. São tais administradores que, de fato, participaram e estavam regularmente autorizados a defender os interesses da companhia no âmbito do negócio conflitado. São tais administradores, dessa forma, que poderiam se sujeitar, de forma combinada com o art. 153 da Lei nº 6.404/1976, à obrigação de garantir que a operação atenda às características descritas no §1º do art. 156 da Lei nº 6.404/1976²⁸.

III. Conclusão

46. Ante o exposto, acompanho a conclusão da Diretora Relatora pela absolvição dos Defendentes e concordo com os fundamentos utilizados para afastar **(i)** as alegações preliminares; **(ii)** a imputação formulada pela Área Técnica, em face dos membros do conselho de administração da Companhia, de violação ao art. 152, *caput*; c/c art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976; e **(iii)** a acusação apresentada em face de José Seripieri por infração ao art. 156, §1º,

²⁸ “(...) *tem-se certa subjetividade na definição do que é uma ‘contratação razoável ou equitativa’.* O erro do administrador nessa avaliação é perfeitamente escusável desde que ele tenha agido com diligência ou, melhor, tenha empregado o mesmo cuidado e diligência que teria na administração dos próprios negócios. (...) Se o administrador se deu por impedido, ou seja, não participou da formação da vontade da companhia, não vejo como responsabilizá-lo por eventuais danos que porventura tenham sido causados à companhia e que sejam superiores às vantagens que o administrador tenha recebido como contraparte do negócio. Por tais danos, respondem apenas os demais administradores, aqueles responsáveis pela formação de vontade da companhia, e deles se haverá de exigir o padrão de diligência do art. 153; ou seja, eles poderão ser escusados se tiverem agido com diligência, como em qualquer outro negócio. Para que o administrador que se deu por impedido se veja na situação de estar obrigado a indenizar a companhia para além das vantagens que tiver auferido, será necessário demonstrar que ele de alguma forma agiu em conluio com os demais administradores, que os influenciou indevidamente. E é claro que o ônus de tal prova recairia sobre quem estivesse pretendendo a indenização. (...) Ao se declarar impedido, o administrador que deixa de agir em nome da companhia e passa, naquele negócio, a apenas atuar em nome próprio, como contraparte, assume o risco de descumprir o §1º do art. 156, ou seja, de ver o negócio anulado se não for realizado em condições razoáveis ou equitativas e de ter que devolver os benefícios que tiver percebido em razão de tal negócio. (...) Mas ao deixar de se declarar impedido o administrador, que, repita-se, não está impedido a priori, passa a ter sobre ele o ônus de garantir – e demonstrar – que o negócio realizado com a companhia será para ela benéfico, sob pena de responder pelos eventuais danos a ela causados, ainda que estes superem os benefícios recebidos por ele, administrador, em decorrência do negócio.” (grifos meus) (CHEDIAK, Julian Fonseca Peña. O conflito de interesses do administrador de sociedade anônima: uma sugestão de alteração no enfoque do tema. In: ADAMEK, Marcelo Vieira Von (coord.). *Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 414-417).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da Lei nº 6.404/1976.

47. Minha divergência restringe-se aos fundamentos adotados pela Diretora Relatora para justificar as absolvições dos membros do conselho de administração da acusação de violação ao art. 154, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, pois **(i)** os atos dos administradores da Companhia objeto da Acusação consubstanciam uma decisão negocial; **(ii)** não se verifica qualquer fragilidade na higidez do processo decisório, fraude, má-fé, simulação ou prova no sentido de que a decisão não teria sido desinteressada, refletida ou informada; e **(iii)** por isso, entendo que o regime de presunções de regularidade existente em nosso ordenamento jurídico, alinhado com as construções da *business judgment rule*, aplica-se integralmente ao caso e, com base nesse fundamento, voto pela absolvição dos acusados.

48. Por fim, com relação ao art. 156, §1º, da lei, entendo que o administrador que se declara impedido – e efetivamente não participa das discussões e deliberações referentes ao negócio conflitado, seguindo o comando do *caput* do art. 156 – não se encontra na posição adequada para fazer cumprir a obrigação de assegurar que o negócio se dê **(i)** em bases equitativas; **(ii)** de acordo com padrões de mercado; ou **(iii)** em condições idênticas àquelas que teriam sido contratadas pela sua contraparte com terceiros. Esse ônus de prova, em tais casos, se desloca para quem quer que tenha interesse de discutir a regularidade da decisão negocial.

É como voto.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2021.

Assinado de forma digital
por Alexandre Costa Rangel
Dados: 2021.12.14 17:04:44
-03'00'

Alexandre Costa Rangel

Diretor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/7872

(Processo Eletrônico CVM SEI nº 19957.010505/2018-49)

Reg. Col. 1455/19

Acusados:

Alexandre Silveira Dias
Arnaldo Curiati
Cláudio Chonchol Bahbout
José Seripieri Filho
Nilton Molina
Raul Rosenthal Ladeira de Matos
Wilson Olivieri

Assunto:

Apuração de responsabilidades de administradores da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A., por infrações ao arts. 152, *caput*, 154, *caput*, e 156, §1º, da Lei nº 6.404/1976.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Acompanho as conclusões e fundamentos do voto da Diretora Relatora. Entretanto, gostaria de destacar um aspecto do caso que pode oferecer importante orientação sobre a conduta esperada dos administradores à luz do art. 153 da Lei das S.A..
2. Ao tratar da suposta violação ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976, um ponto ressaltado pela acusação e que me parece relevante diz respeito ao início da vigência do contrato celebrado com o acusado José Seripieri. Diferentemente do que usualmente ocorre em contratos de não concorrência que em geral passam a valer após o desligamento do executivo, o contrato em questão passou a produzir efeitos enquanto este ainda ocupava cargo na administração da Companhia e, portanto, ainda estava sujeito ao cumprimento dos deveres fiduciários a ele inerentes.
3. Para fins da imputação objeto da presente acusação, concordo com a conclusão da Diretora Relatora de que tal sobreposição parcial e temporal entre as obrigações previstas no Contrato e os deveres fiduciários exigidos dos administradores não seria suficiente para configurar, no caso, uma violação ao art. 156 da Lei nº 6.404/1976, pelas razões expostas em seu voto, particularmente, o fato de que “o conjunto fático-probatório [...] evidencia que preponderava a avaliação e negociação de contrapartida necessária para assegurar a ‘saída ordenada’, caso essa viesse a se materializar”.
4. Ademais, os elementos trazidos aos autos pela acusação não me convencem de que o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Contrato não tenha sido celebrado em condições não equitativas, especialmente porque, como também apontado pela Relatora, as obrigações assumidas por José Seripieri e o valor correspondente foram estabelecidos de uma forma global e conjunta, sem especificação de valor para cada contrapartida.

5. Porém, e ainda que o presente caso não envolva imputação de infração ao dever de diligência, considero relevante a ausência, seja pela acusação, seja pelas defesas, de considerações sobre o impacto que teria, para fins do valor devido pela Companhia ao acusado, o período em que este permanecesse no exercício de suas funções estatutárias. Trata-se de variável relevante.

6. Com efeito, e como alegado pela defesa, as negociações para um acordo de não-competição foram inicialmente concebidas na premissa de desvinculação de José Seripieri do cargo de administrador, premissa esta que foi posteriormente alterada a partir da decisão do próprio acusado de reconsiderar sua saída da Companhia. Reconheço que esta mudança, por si só, não interfere na necessidade de celebração de um compromisso de não-concorrência, e que, como pontuou a Diretora Relatora, as obrigações pactuadas eram mais amplas.

7. Por outro lado, me parece que, à luz do dever de diligência dos administradores, o potencial impacto da sobreposição entre a vigência do Contrato e o exercício do mandato de administrador sobre o valor da contrapartida financeira fixada era um ponto relevante que deveria ser discutido no processo de aprovação do Contrato, porque certamente afetaria a importância econômica do compromisso assumido. Nesse sentido, causa certa surpresa constatar que não se exigiu, por exemplo, que os assessores da Companhia analisassem se, e em que medida, tal interseção poderia impactar o valor da contrapartida financeira.

8. De todo modo, tendo em vista que não houve, neste processo, acusação de descumprimento do dever de diligência, reitero que este registro não tem por objetivo discutir qualquer irregularidade em relação ao processo decisório de aprovação do Contrato sob a ótica de tal dever. Isso demandaria, primeiro, a formulação de imputação nesse sentido e, segundo, a apreciação dos elementos de prova pertinentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por

Marcelo Barbosa

Presidente



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

FOLHA DE ASSINATURA

DO VOTO PTE

(Doc. SEI nº 1412158)

Assina o Voto PTE, nos termos do Doc. SEI nº 1412158.

MARCELO BARBOSA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 17/12/2021, às 19:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1412160** e o código CRC **ECE5C66B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1412160** and the "Código CRC" **ECE5C66B**.*